課程名稱：刑法刑法27

00:00:02 - 00:00:05
好，我們今天接著上一次殺人罪的進度，我們來看的殺人罪最後的一個問題是272條的經濟問題，殺人罪變體構成要件的錯誤。

00:00:12 - 00:00:22
這個問題，我們之所以會放在分則這邊來講，理由就是因為說，這個問題我們找不到一個統一的解決方案。

00:00:22 - 00:00:26
也就是殺人罪的各條的加重或減輕的構成要件。

00:00:26 - 00:00:34
當行為人對他的事實有發生誤認的時候，我們沒有辦法統一的用一套錯誤論的理論來處理，就沒辦法，所以我們只好解一條解決一條，這個是沒有辦法的事。

00:00:38 - 00:00:40
所以呢，這個地方

00:00:40 - 00:00:43
我們才會特別用一個專題研究來講，

00:00:43 - 00:00:46
講說殺人罪，他的各個加重減輕事由，

00:00:46 - 00:00:48
如果行為人發生誤認的話，

00:00:48 - 00:00:50
那我們應該怎麼去做。

00:00:51 - 00:01:00
好，那這裡的話，首先第一個同學可能會想到的一個做法是，有些同學可能會說，不是有所知所犯規則嗎？

00:01:00 - 00:01:02
實務上不是有這個規則嗎？

00:01:02 - 00:01:06
那我要跟各位說，如果你沒有聽過所知所犯，你很棒。

00:01:07 - 00:01:08
真的。

00:01:08 - 00:01:09
這個不是反話。

00:01:09 - 00:01:10
沒聽過所知所犯，你很棒。

00:01:10 - 00:01:12
因為那個不是這個年代的東西。

00:01:13 - 00:01:15
所知所犯規則，它是從唐律那邊來的。

00:01:16 - 00:01:17
它一點道理也沒有。

00:01:17 - 00:01:19
聽到從唐律來的，你還敢用嗎？

00:01:19 - 00:01:21
對啊，就那種東西啊。

00:01:21 - 00:01:23
2025年了，不要再用什麼「所知所犯」了，知道嗎？

00:01:24 - 00:01:27
那個是實務發黴的破東西，現在已經沒有人在用了啦，真的啦。

00:01:27 - 00:01:29
學者已經沒有人在用了，它就是一個結論，他們沒有宣稱任何的，它並沒有任何的論述過程。

00:01:34 - 00:01:41
關於這個錯誤的問題，如果同學你以前聽到的解法是「所知所犯」，把它忘掉。

00:01:43 - 00:01:45
那個已經不是現在的刑法學界會用的東西了。

00:01:46 - 00:01:49
你寫在考卷上，老師看到會想說你是從哪一個時代穿越過來的。

00:01:49 - 00:01:50
不要寫這種東西啊。

00:01:50 - 00:01:57
我們現在在處理錯誤的問題的時候，我說的已經2025年了，我們要會使用刑法的學理概念。

00:01:57 - 00:01:59
所以這裡的話呢，我們就來看一下。

00:02:00 - 00:02:02
我們要使用什麼的學理概念呢?

00:02:03 - 00:02:09
那沒辦法嘛，因為這個殺人罪當中每一條罪的加重或減輕性質都有點不太一樣。

00:02:09 - 00:02:12
所以我們只能呢，看一個條文，解決一個條文。

00:02:13 - 00:02:15
這裡我們首先來看到括號一這邊，

00:02:16 - 00:02:18
殺直系血親尊親屬罪。

00:02:19 - 00:02:20
我們先來看到這個問題,

00:02:20 - 00:02:20
272。

00:02:21 - 00:02:25
272條啊,當行為人誤認的時候怎麼辦?

00:02:25 - 00:02:30
比如說行為人要殺的人是他的爸爸,結果他認錯,殺到他的叔叔,

00:02:31 - 00:02:35
或者顛倒過來也有可能,要殺叔叔,結果殺到的人卻是爸爸。

00:02:35 - 00:02:41
這種認錯的情況啊，在272當中，我們多數的說法會認為說呢，

00:02:42 - 00:02:46
這個主觀跟客觀兩者都要有合致，這才可以。

00:02:47 - 00:02:50
也就是要成立272啊，必須主觀跟客觀兩者都合致。

00:02:51 - 00:02:56
兩者少了任何一個，行為人都只能回去論271，

00:02:56 - 00:02:57
這個是多數的說法。

00:02:57 - 00:02:59
為什麼多數會這樣講呢？

00:02:59 - 00:03:03
272的加重啊，當然跟期待可能性跟罪責有關，

00:03:03 - 00:03:03
沒有錯。

00:03:04 - 00:03:08
可是同學你也不要忘記，272它的條文寫說，你殺什麼人呢？

00:03:08 - 00:03:10
直系血親尊親屬。

00:03:10 - 00:03:16
那個直系血親尊親屬，它本身啊，也是一個跟行為客體有關的要素。

00:03:17 - 00:03:22
所以我們會說，雖然這個272它的性質上是一種罪責方面的加重，

00:03:22 - 00:03:23
沒有錯，

00:03:23 - 00:03:26
可是因為它的條文寫的是直系血親尊親屬，

00:03:26 - 00:03:33
而直系血親尊親屬這個東西，本質上當然跟客觀上所存在的行為客體是不可分的。

00:03:33 - 00:03:39
所以272這個尊親屬的要件呢,當然我們不能只有客觀上存在而已,

00:03:39 - 00:03:42
那當然也不能只有主觀上的想像而已,

00:03:42 - 00:03:45
這兩者呢,主跟客都要合致,

00:03:45 - 00:03:46
主跟客都要合致。

00:03:46 - 00:03:54
所以要殺爸爸結果認錯殺到叔叔,或者是反過來要殺叔叔結果認錯卻殺到爸爸的情形呢,

00:03:54 - 00:03:58
最後我們在結論上都只能論行為人271的犯罪,

00:03:59 - 00:04:00
只能論行為人271。

00:04:00 - 00:04:01
的既遂,這個是我講相對比較沒有疑問的。

00:04:05 - 00:04:09
好,那麼接著我們來看到253頁的括號二。

00:04:09 - 00:04:11
那生母殺嬰罪呢。

00:04:12 - 00:04:18
好，生母殺嬰罪，這邊的寫法卻說，以主觀的認知來決定，為什麼呢？

00:04:20 - 00:04:24
生母殺嬰罪的減輕，一般認為它是一種罪責的減輕。

00:04:25 - 00:04:32
也就是考量到生母在產後壓力大的那一種心理狀態，進而讓行為人享有非常優惠的刑罰。

00:04:33 - 00:04:40
那一般的說法，既然生母殺嬰罪他考量到的是行為人產後心理壓力的狀態的話。

00:04:40 - 00:04:47
那麼這一條呢，我們就只看行為人主觀上有沒有覺得這個小孩是他的嬰兒。

00:04:47 - 00:04:48
純粹看主觀。

00:04:48 - 00:04:51
至於客觀上的事實到底是什麼呢？

00:04:51 - 00:04:53
不重要，完全只看主觀而已。

00:04:54 - 00:04:58
所以我們舉例來講，以這個274來說。

00:04:59 - 00:05:00
有個產婦啊。

00:05:00 - 00:05:01
剛生完小孩之後。

00:05:02 - 00:05:04
他想殺死自己的小孩。

00:05:04 - 00:05:07
因為剛生完小孩之後，自己剛被解僱。

00:05:07 - 00:05:09
先生的公司又倒閉之類的。

00:05:09 - 00:05:10
這個覺得人生啊。

00:05:11 - 00:05:12
充滿了絕望。

00:05:13 - 00:05:14
所以他就想把他的小孩給殺掉了。

00:05:15 - 00:05:16
結果呢？

00:05:16 - 00:05:19
他要殺的時候，因為剛出生那個嬰兒看起來都差不多嘛。

00:05:19 - 00:05:20
他竟然認錯，把隔壁床的嬰兒給殺了。

00:05:22 - 00:05:24
這樣的情形，行為人怎麼論罪？

00:05:25 - 00:05:26
還是274？

00:05:27 - 00:05:29
雖然他客觀上殺的不是自己的小孩。

00:05:30 - 00:05:33
但是他主觀上確實是處於殺嬰的意思。

00:05:33 - 00:05:37
也就是他那個產後壓力大的心理狀態確實是存在的。

00:05:37 - 00:05:39
所以這種情形我們論什麼呢？

00:05:39 - 00:05:41
274的既遂，OK喔。

00:05:41 - 00:05:42
好。

00:05:42 - 00:05:43
可是顛倒過來喔。

00:05:43 - 00:05:45
這個產婦啊。

00:05:45 - 00:05:47
剛生完小孩之後。

00:05:47 - 00:05:50
因為她跟隔壁床的產婦吵了一架。

00:05:50 - 00:05:54
她憤而想殺死隔壁床產婦的嬰兒來洩憤，結果歪打正著。

00:05:54 - 00:05:57
竟然殺到自己的嬰兒，這樣的情形可不可以離婚？

00:06:00 - 00:06:00
不行，為什麼？

00:06:01 - 00:06:04
因為他並沒有產後壓力大的情況存在，知道嗎？

00:06:04 - 00:06:07
所以我們講，在274條這邊，行為人如果對行為客體發生誤認的話，我們是純粹看行為人的主觀。

00:06:13 - 00:06:17
只要行為人他覺得是在殺自己的嬰兒呢，就可以減輕啊。

00:06:17 - 00:06:19
那我這邊再講一次喔。

00:06:20 - 00:06:22
同樣都跟罪責有關。

00:06:22 - 00:06:26
為什麼272的罪責加重，要做主跟客要合致？

00:06:27 - 00:06:29
但為什麼274的罪責減輕？

00:06:29 - 00:06:31
只要主觀有符合就好了呢。

00:06:32 - 00:06:33
好，那我再講一遍，為什麼？

00:06:33 - 00:06:37
因為272他殺直系血親尊親屬，雖然那個加重跟罪責有關沒有錯。

00:06:39 - 00:06:42
可是因為條文他強調的是直系血親，很清楚。

00:06:42 - 00:06:44
他強調的是那個客體。

00:06:44 - 00:06:46
客體當然要客觀上存在，知道嗎？

00:06:46 - 00:06:48
可是反過來，生母殺嬰罪。

00:06:49 - 00:06:50
他強調的其實不是那個嬰兒。

00:06:51 - 00:06:56
生母殺嬰，所以他強調的是行為人生產之後壓力大的那個心理狀態。

00:06:56 - 00:06:58
所以我們才可以怎麼樣，只看主觀，知道吧？

00:06:58 - 00:07:00
所以這兩條我們的考量點也不太一樣。

00:07:01 - 00:07:01
好。

00:07:02 - 00:07:03
那接下來，我們來看到括號三。

00:07:05 - 00:07:09
義憤殺人跟受囑託的殺人罪，這兩條都可能會發生兩個不同的問題。

00:07:13 - 00:07:14
一個是

00:07:14 - 00:07:17
無中生有，或者是反過來，有中生無，這個東西是有可能的。

00:07:19 - 00:07:21
這邊我舉的例子是義憤殺人了，謝開平老師他書上的例子。

00:07:23 - 00:07:25
沒關係，我各舉一個例子。

00:07:25 - 00:07:27
首先我們先來講這個義憤殺人的案例。

00:07:28 - 00:07:28
好，比如說

00:07:29 - 00:07:32
有兩個男人，他們是公司的同事，他們是死對頭。

00:07:32 - 00:07:33
那有一天啊。

00:07:34 - 00:07:38
這個A男，他在路上看到B男的休旅車停在路邊。

00:07:38 - 00:07:40
兩個人關係就不好嘛。

00:07:40 - 00:07:42
A就上去找B，跟他吵架。

00:07:43 - 00:07:46
A跟B吵了以後之後，B可能辱罵他什麼的，兩個人啊。

00:07:47 - 00:07:49
情緒都很火爆嘛，所以這個A男呢。

00:07:49 - 00:07:51
在十分生氣的情況之下，就把B男的

00:07:54 - 00:07:56
就把B男持刀給殺死了。

00:07:56 - 00:07:58
那A殺死B之後，A看到B的休旅車停在那裡。

00:08:00 - 00:08:00
A就好奇看一下休旅車裡面還有誰。

00:08:03 - 00:08:05
結果A探頭進去啊，嚇傻了。

00:08:05 - 00:08:09
怎麼A自己的老婆赤身裸體在B的休旅車的後座呢。

00:08:10 - 00:08:12
原來啊，A的老婆跟那個B有一腿，他們剛剛打完砲而已。

00:08:14 - 00:08:17
B那時候在外面抽個事後菸，然後就被A給殺了。

00:08:18 - 00:08:21
這樣的案例當中，客觀上有沒有這個義憤的情形？

00:08:21 - 00:08:22
客觀上其實有，對不對？

00:08:22 - 00:08:24
但行為人主觀上有沒有認知？

00:08:25 - 00:08:25
沒有。

00:08:26 - 00:08:28
所以義憤殺人罪可能會發生這個問題喔。

00:08:28 - 00:08:32
那也就是為什麼我上個禮拜特別跟同學強調。

00:08:32 - 00:08:36
義憤殺人罪，那裡所謂的當場基於義憤。

00:08:36 - 00:08:42
他指的是客觀上有一個足以激起義憤的事實狀態。

00:08:43 - 00:08:46
我們為什麼一直強調說義憤是客觀要件，而不是主觀要件。

00:08:46 - 00:08:47
就跟這種案例有關。

00:08:48 - 00:08:50
因為這種案例我很久以前在集訓班有出過。

00:08:51 - 00:08:55
結果你知道嗎，很多同學都說，行為人主觀上不義憤，所以他不算273。

00:08:55 - 00:08:56
你這樣寫就不對了。

00:08:57 - 00:08:59
義憤不是主觀要件，義憤是客觀要件。

00:09:00 - 00:09:02
客觀上有那個情狀存在，知道嗎。

00:09:02 - 00:09:03
所以這個案例當中，

00:09:05 - 00:09:06
我們會講，

00:09:06 - 00:09:08
客觀上確實有這個義憤的情狀存在。

00:09:08 - 00:09:12
但是行為人主觀上對這個情狀的存在呢，卻完全沒有認知。

00:09:13 - 00:09:15
所以這種情形可以論273嗎，這個就是有疑問的。

00:09:17 - 00:09:21
好，或者類似的問題在275的第一項受囑託得承諾殺人罪。

00:09:22 - 00:09:24
當然也有可能會發生。

00:09:25 - 00:09:27
比如說有一個被長照的老人。

00:09:27 - 00:09:30
他久病厭世，他覺得活下去沒意思。

00:09:30 - 00:09:35
所以他寫了一封遺書，放在他的床頭，壓在他床頭的時鐘下面。

00:09:36 - 00:09:38
這個遺書的內容呢，是希望看護可以把他殺死。

00:09:41 - 00:09:45
結果他的看護本來就想解決掉這個老人了。

00:09:46 - 00:09:51
他的看護在完全不知道有遺書的情況之下，把這個老人給殺了。

00:09:51 - 00:09:53
那是不是類似的情況。

00:09:53 - 00:09:55
客觀上有主託承諾，有啊。

00:09:55 - 00:09:57
只是行為人主觀上卻沒有認識到。

00:09:58 - 00:09:59
一樣的問題嘛，對不對。

00:09:59 - 00:10:00
客觀上。

00:10:00 - 00:10:00
有，

00:10:00 - 00:10:02
但在主觀上沒有。

00:10:03 - 00:10:03
好，

00:10:04 - 00:10:06
顛倒過來也會有另外一個版本。

00:10:06 - 00:10:08
顛倒過來的版本是：

00:10:08 - 00:10:09
客觀上，

00:10:10 - 00:10:11
客觀上，

00:10:12 - 00:10:14
沒有竊機的事由存在，

00:10:14 - 00:10:16
可是行為人主觀上的，

00:10:16 - 00:10:19
卻誤以為有這樣的情狀存在。

00:10:19 - 00:10:19
好,

00:10:20 - 00:10:21
這邊的話,

00:10:21 - 00:10:22
我舉一個例子。

00:10:24 - 00:10:27
這個例子是十多年前的高考的題目。

00:10:27 - 00:10:28
這一題很有趣,

00:10:29 - 00:10:30
這一題的事實大概是這樣說的,

00:10:31 - 00:10:32
我應該把這題放回來才對,

00:10:32 - 00:10:34
因為以前都是翻題目本,

00:10:34 - 00:10:34
但那題太舊了,

00:10:34 - 00:10:36
我後來從題目本裡面刪掉了。

00:10:36 - 00:10:37
這一題的事實是這樣,

00:10:38 - 00:10:38
那個,

00:10:40 - 00:10:40
有個女生啊,

00:10:41 - 00:10:41
罹患了絕症,

00:10:42 - 00:10:42
她在住院。

00:10:43 - 00:10:45
那這個罹患絕症的女生呢,

00:10:45 - 00:10:47
有一天就寫了一封遺書,

00:10:47 - 00:10:48
要給她的男朋友。

00:10:49 - 00:10:50
遺書裡面的內容啊,

00:10:50 - 00:10:54
大致上是希望她的男朋友可以把她給殺死。

00:10:54 - 00:10:57
這個男生看了遺書的內容之後,

00:10:57 - 00:10:59
也對女朋友覺得很不捨,

00:10:59 - 00:11:01
但心想說既然這個女生不想活了,

00:11:02 - 00:11:03
那就送他女朋友最後一程吧。

00:11:03 - 00:11:04
於是這個男生呢,

00:11:05 - 00:11:07
就用枕頭把熟睡中的女生呢,

00:11:07 - 00:11:08
給悶死了。

00:11:08 - 00:11:09
結果啊,

00:11:09 - 00:11:12
事後從女生多位閨密的口中證實呢,

00:11:13 - 00:11:14
女生寫這個遺書,

00:11:15 - 00:11:16
其實他並沒有真的想死。

00:11:16 - 00:11:17
他寫這個遺書啊,

00:11:18 - 00:11:19
只是想跟男朋友撒嬌,

00:11:19 - 00:11:20
獲得多一點的關愛,

00:11:20 - 00:11:22
題目裡面是這樣說的。

00:11:22 - 00:11:23
欸，我每次看到這個題目，

00:11:24 - 00:11:25
在法律之外啦，

00:11:25 - 00:11:25
我都會有種感覺，

00:11:26 - 00:11:27
我覺得這女的死得活該。

00:11:28 - 00:11:28
真的。

00:11:28 - 00:11:29
我有一種感覺,

00:11:29 - 00:11:31
我超討厭這種講反話的人。

00:11:31 - 00:11:31
就是,

00:11:32 - 00:11:33
我覺得做人真誠一點很難吧,

00:11:33 - 00:11:35
為什麼就是要講這種反話,

00:11:35 - 00:11:37
然後去試探相對人的意思。

00:11:38 - 00:11:39
我很受不了這樣的行為。

00:11:40 - 00:11:40
對啊，

00:11:40 - 00:11:41
就好像比如說，

00:11:42 - 00:11:42
很多啦。

00:11:42 - 00:11:45
就比如說有些人就是會用這個方式去測試他的伴侶。

00:11:45 - 00:11:46
比如說，

00:11:46 - 00:11:47
明明就是，

00:11:47 - 00:11:49
或者是一般的人際關係中也有可能，

00:11:49 - 00:11:50
就故意講說：

00:11:50 - 00:11:52
哎呀你們一定不歡迎我啦什麼的,

00:11:52 - 00:11:53
就逼著對方講說,

00:11:53 - 00:11:54
沒有沒有，其實我們超歡迎你。

00:11:54 - 00:11:55
我好討厭這種人喔,

00:11:56 - 00:11:56
就是,

00:11:56 - 00:11:58
他等於是用言語來操控對方嘛,

00:11:58 - 00:12:00
逼著對方一定要

00:12:00 - 00:12:01
回答自己想要的答案,所以我看到那個題目就有一種感覺。

00:12:03 - 00:12:03
死了活該,超討厭這種人,講反話的人真的

00:12:07 - 00:12:12
如果真的啦,如果你是習慣講反話的話,我覺得你要去接受一下心理諮商,我是認真的,因為正常的人應該不會用這個方式去跟人家溝通。

00:12:16 - 00:12:17
這一題當中啊,

00:12:18 - 00:12:23
我們看喔,就275條的第一項來講,就275條第一項來講,

00:12:24 - 00:12:28
我們看喔,客觀上有沒有這個解氣的事由存在。

00:12:29 - 00:12:32
沒有,客觀上那個人沒有講死啊,對不對?

00:12:32 - 00:12:33
客觀上沒有。

00:12:33 - 00:12:35
那行為人主觀上是不是覺得有?

00:12:36 - 00:12:40
對,沒有錯,所以會變成客觀打叉,主觀打勾,變成這樣的結構。

00:12:41 - 00:12:41
來。

00:12:42 - 00:12:46
我們先處理前半段,就是我們剛剛前面講的兩個案例。

00:12:46 - 00:12:48
客觀有而主觀沒有的。

00:12:48 - 00:12:50
前面這兩個相對簡單,為什麼呢?

00:12:51 - 00:12:55
因為我們講說,故意本來就要認知到所有構成犯罪的事實。

00:12:56 - 00:12:59
所以行為人不知道客觀上有義憤的情狀。

00:12:59 - 00:13:02
行為人不知道被害人有囑託、承諾他殺。

00:13:03 - 00:13:06
這樣的情況,行為人可不可以論273、275?

00:13:06 - 00:13:06
不行嘛,對不對?

00:13:07 - 00:13:10
所以客觀上有但主觀上沒有的情形,

00:13:10 - 00:13:10
我們應該論什麼呢?

00:13:11 - 00:13:13
271的既遂,

00:13:13 - 00:13:15
沒辦法論273,OK吧,所以客觀有主觀沒有的情形,非常簡單。

00:13:19 - 00:13:21
我們只能回頭去論述271的既遂。

00:13:21 - 00:13:23
來,有問題的是版上這種。

00:13:24 - 00:13:29
那如果是客觀沒有,但主觀上有呢?像我說的嘛。

00:13:30 - 00:13:33
客觀上這個女生他根本就沒有想死。

00:13:33 - 00:13:36
他只是透過講反話的方式來獲得他男朋友多一點的關愛。

00:13:37 - 00:13:39
結果男生理解的是字面的意思。

00:13:39 - 00:13:40
男生就把這個女生給殺了。

00:13:41 - 00:13:43
這樣的情形，我們看喔，怎麼處理？

00:13:44 - 00:13:46
客觀沒有，但主觀有，所以這個叫什麼？

00:13:48 - 00:13:49
未遂。

00:13:49 - 00:13:50
對吧,這個叫未遂。

00:13:50 - 00:13:50
好,各位。

00:13:51 - 00:13:54
這一件照條文推導真的是未遂。

00:13:55 - 00:13:57
可是你會不會覺得論未遂有問題？

00:13:58 - 00:14:00
不是說人死了怎麼還可以論未遂？

00:14:00 - 00:14:00
既遂不是這個問題

00:14:01 - 00:14:03
而是這裡會形成一個輕重失衡的狀態

00:14:04 - 00:14:05
那我們再做一個對比喔

00:14:05 - 00:14:08
如果他的女朋友是真的想死呢

00:14:09 - 00:14:10
那是不是就既遂

00:14:11 - 00:14:11
對

00:14:11 - 00:14:12
既遂跟未遂哪一個重

00:14:13 - 00:14:14
既遂重

00:14:14 - 00:14:15
所以問題就在這邊

00:14:16 - 00:14:19
如果他的女朋友真的想死

00:14:19 - 00:14:23
行為人也知道而幫他的女朋友做這個傷害的行為

00:14:23 - 00:14:26
這個時候行為人對的是275條一項的既遂

00:14:27 - 00:14:28
既遂相對重

00:14:28 - 00:14:28
對不對

00:14:28 - 00:14:30
那他的女朋友沒有想死

00:14:30 - 00:14:33
他只是自以為女生想死

00:14:33 - 00:14:34
而把他女朋友殺了

00:14:34 - 00:14:35
這時候變未遂耶

00:14:36 - 00:14:38
未遂反而是可以減輕刑

00:14:38 - 00:14:40
是不是覺得很怪

00:14:40 - 00:14:43
就被害人真的想死

00:14:43 - 00:14:43
其實比較重

00:14:43 - 00:14:47
啊被害人其實沒有想死

00:14:47 - 00:14:49
只是行為人自以為被害人想死

00:14:49 - 00:14:49
這時候反而判得比較輕

00:14:49 - 00:14:50
怪沒有錯

00:14:50 - 00:14:52
所以你說這個時候該怎麼辦呢

00:14:52 - 00:14:52
於是啊

00:14:54 - 00:14:56
有幾種可能的途徑

00:14:57 - 00:14:59
第一種可能的途徑

00:14:59 - 00:14:59
是說好

00:15:00 - 00:15:01
那我們就回去論271

00:15:01 - 00:15:04
德國學者有這種說法就回去了271的既遂

00:15:04 - 00:15:07
可是學者說你回去的271的既遂也不對

00:15:07 - 00:15:08
為什麼呢

00:15:08 - 00:15:10
因為行為人主觀上沒有那麼壞

00:15:11 - 00:15:15
犯275的行為人他是覺得被害人也想死

00:15:15 - 00:15:19
他並沒有想違反被害人的意思去剝奪他的生命

00:15:19 - 00:15:20
其實這個行為人沒有很壞

00:15:20 - 00:15:21
對不對

00:15:21 - 00:15:23
所以你回去論271的話

00:15:23 - 00:15:24
不是不行啊

00:15:24 - 00:15:25
但是會怎麼樣

00:15:25 - 00:15:26
過度評價

00:15:26 - 00:15:27
這恐怕不好

00:15:27 - 00:15:29
所以你就會發現形成了一個局面嘛

00:15:30 - 00:15:33
論275的未遂變成不當的減輕

00:15:33 - 00:15:37
那你回去論271的既遂好像又變成不當的加重

00:15:37 - 00:15:38
對啊那怎麼辦兩難嘛

00:15:38 - 00:15:41
所以後來蔡老師提出了一個主張

00:15:41 - 00:15:43
我們翻到254頁這邊

00:15:45 - 00:15:46
這裡呢

00:15:46 - 00:15:48
德國刑法16條的第二項來的

00:15:48 - 00:15:49
我們來看一下圈圈二

00:15:49 - 00:15:51
德國刑法第16條第二項說

00:15:51 - 00:15:54
凡是在行為時誤以為違法的構成要件是存在者

00:15:54 - 00:15:59
其所故意違反之罪，應得依照違法去做處罰。

00:16:00 - 00:16:04
這個德國刑法第16條第二項的意思就是說，在這種情形，第一個，你不能去論271的既遂。

00:16:08 - 00:16:10
因為這個是對行為人過度的評價。

00:16:11 - 00:16:15
再來你也不能去論275的未遂，因為這個也會形成一種不當的減輕。

00:16:16 - 00:16:24
這裡所說的請得一輕法具處罰的意思，就是說這種情形要直接論行為人275的既遂。

00:16:25 - 00:16:26
知道嗎，要論行為人275的既遂。

00:16:26 - 00:16:27
所以這種情況很特殊。

00:16:28 - 00:16:31
邏輯推導下來，他原本應該是未遂犯。

00:16:31 - 00:16:36
可是我們基於法理上面的推導，基於德國刑法第16條第二項的相同法理。

00:16:36 - 00:16:38
這種情形，我們只能論行為人。

00:16:39 - 00:16:41
275的既遂犯，很特殊。

00:16:42 - 00:16:43
這個之前國考有考過。

00:16:43 - 00:16:45
大概都10年前左右的事吧。

00:16:45 - 00:16:48
那個第一次考出來是在103年的地特三等。

00:16:49 - 00:16:53
那個題目考出來之後，很多人都說是蔡聖偉老師出的。

00:16:53 - 00:16:54
因為蔡老師有寫這個文章。

00:16:54 - 00:16:57
但蔡老師後來有澄清，說那題不是他出的。

00:16:57 - 00:17:02
後來在107年還是106年的律師也有考到，而那一份是不是蔡老師出的，我就不知道了。

00:17:04 - 00:17:05
這個我就沒有特別去問老師了。

00:17:07 - 00:17:10
所以,這個考試確實有出現過。

00:17:11 - 00:17:13
好,所以這個是275的一項。

00:17:14 - 00:17:17
最後來括號四,275的二項。

00:17:19 - 00:17:20
好。

00:17:20 - 00:17:24
275的二項,如果行為人有誤認的話,這個該怎麼辦。

00:17:24 - 00:17:27
第一個你看喔，我以為被害人有自主能力。

00:17:27 - 00:17:28
你看這個。

00:17:32 - 00:17:34
這個案例在255頁的上面。

00:17:34 - 00:17:37
A建議安撫B，早日自殺解脫，B也聽從建議自殺。

00:17:37 - 00:17:39
但事後證實了。

00:17:39 - 00:17:43
B在自殺時早已意識不清，那麼這樣案例當中，因為行為人

00:17:43 - 00:17:44
他的認知當中

00:17:44 - 00:17:47
他認為這個被害人是有自主能力的

00:17:48 - 00:17:50
但事實上來說呢，卻是沒有的

00:17:51 - 00:17:54
所以這種情況許澤天老師在文章裡面認為說

00:17:54 - 00:17:57
他應該只能論過失致死。

00:17:58 - 00:18:00
好，那反過來呢？

00:18:00 - 00:18:01
好，第二點這邊，

00:18:01 - 00:18:03
行為人誤以為被害人沒有自主能力，

00:18:03 - 00:18:05
可是事實上是有的。

00:18:06 - 00:18:07
你看到這個案例喔,

00:18:07 - 00:18:10
A在B的食物中下毒，希望B中毒而死,

00:18:10 - 00:18:12
但這個計謀被B看穿了,

00:18:12 - 00:18:14
B正好也有自殺念頭，

00:18:14 - 00:18:16
所以呢，吃下食物而死亡。

00:18:17 - 00:18:20
所以行為人主觀上是不是覺得自己在支配被害人的死亡？

00:18:20 - 00:18:22
他主觀上是這樣覺得吧，

00:18:22 - 00:18:23
但客觀上有支配嗎？

00:18:23 - 00:18:23
沒有，

00:18:24 - 00:18:25
客觀上被害人早就看穿了。

00:18:26 - 00:18:28
這個劇情有沒有感覺好像是那種本土劇會出現的,

00:18:28 - 00:18:32
玫瑰瞳鈴眼啊，藍色水玲瓏啊，就會有這種劇情嘛，對不對？

00:18:32 - 00:18:35
這種東西，學理上認為說論間接正犯的未遂，

00:18:36 - 00:18:38
因為他只是自以為在支配而已，

00:18:38 - 00:18:38
知道嗎？

00:18:38 - 00:18:39
他只是自以為在支配。

00:18:40 - 00:18:44
好，所以這個是我們講這個加重減輕事實的錯誤。

00:18:45 - 00:18:48
接著下面第六點這邊，過失致死，

00:18:48 - 00:18:52
這個我不多說，因為過失致死的問題，我們在刑總全部都講過了。

00:18:52 - 00:18:55
那麼過失致死的部分，我只提醒同學一件事。

00:18:56 - 00:18:58
我們叫過失致死,

00:18:58 - 00:18:59
你不要叫他過失殺人。

00:19:00 - 00:19:02
刑法上沒有過失殺人的概念,

00:19:02 - 00:19:02
知道嗎?

00:19:02 - 00:19:04
這個念法律系的同學應該都知道

00:19:04 - 00:19:07
但如果你不是法律系的同學的話，可能沒有聽過這樣的概念，

00:19:07 - 00:19:09
所以我再次跟同學講。

00:19:10 - 00:19:11
不會有過失殺人這種東西。

00:19:11 - 00:19:15
因為殺人的殺本，從文義上來講，它包含了故意的成分。

00:19:16 - 00:19:20
你不可能說，這個，我殺了你，抱歉，我是不小心的。

00:19:20 - 00:19:22
沒有嘛,不可能嘛,對不對?

00:19:22 - 00:19:24
所以殺人呢,它本身一定是故意的。

00:19:25 - 00:19:25
好。

00:19:27 - 00:19:31
那接下來,我們來看到255頁的第二節,遺棄罪。

00:19:33 - 00:19:34
好,遺棄罪。

00:19:35 - 00:19:36
遺棄罪這個犯罪啊,

00:19:37 - 00:19:41
也是同學很常寫在考卷上面，但其實很多時候是不用寫的犯罪。

00:19:42 - 00:19:43
我先跟同學強調一件事。

00:19:44 - 00:19:47
當行為人有殺人故意的時候,

00:19:48 - 00:19:50
我們原則上不用另外再去寫遺棄罪。

00:19:50 - 00:19:51
沒有意義，

00:19:51 - 00:19:52
知道嗎？

00:19:52 - 00:19:56
因為當行為人有殺人故意的時候，我們優先評價殺人罪就夠了。

00:19:56 - 00:20:00
所以啊，當你在考卷上，如果同

00:20:00 - 00:20:04
題目的同一個事實，你先寫殺人罪寫完，你又寫遺棄罪。

00:20:04 - 00:20:07
你要問問自己，寫那個遺棄罪是有意義的嗎？

00:20:07 - 00:20:09
我跟你講，通常是沒有，知道嗎？

00:20:09 - 00:20:09
通常是沒有。

00:20:10 - 00:20:15
當行為人這個行為已經可以用殺人罪去評價的時候，你就完全不需要再寫遺棄罪了。

00:20:15 - 00:20:17
寫了真的沒有意思啊，知道吧？

00:20:17 - 00:20:18
提醒各位喔。

00:20:19 - 00:20:19
好，那我們來看喔。

00:20:21 - 00:20:23
遺棄罪的本質是什麼？

00:20:23 - 00:20:24
同樣是生命法益。

00:20:25 - 00:20:26
殺人罪叫做實害犯。

00:20:27 - 00:20:29
遺棄罪叫做危險犯。

00:20:29 - 00:20:36
所以遺棄罪要處罰的行為是這樣子，他遺棄被害人，造成被害人生命上的危險。

00:20:36 - 00:20:37
比如說我們講喔。

00:20:37 - 00:20:41
你把一個流浪漢，比如說你在地下道看到一個流浪漢。

00:20:42 - 00:20:45
你拿刀去捅他，殺人罪，廢話，不用我多說嘛。

00:20:46 - 00:20:49
那如果你看到一個流浪漢，他奄奄一息地跟你求救。

00:20:50 - 00:20:52
結果你開車把他載到海邊去丟掉。

00:20:53 - 00:20:55
這個就叫做遺棄罪。

00:20:55 - 00:20:56
知道嗎？

00:20:56 - 00:20:56
這個叫遺棄罪。

00:20:56 - 00:20:59
所以殺人罪跟遺棄罪都是生命法益的犯罪。

00:21:00 - 00:21:01
但是呢。

00:21:01 - 00:21:05
他們所這個他們的性質不一樣,殺人罪叫實害犯,而遺棄罪呢,叫做危險犯。

00:21:09 - 00:21:11
好,那遺棄罪的條文,我們大致上來看一下。

00:21:12 - 00:21:15
第一個是293,這個叫做一般的遺棄罪。

00:21:15 - 00:21:17
293一般的遺棄罪。

00:21:18 - 00:21:22
比如說你開車把流浪漢再丟去海邊丟掉，這個是293。

00:21:22 - 00:21:24
再來是294，那個叫做義務遺棄罪。

00:21:26 - 00:21:30
也就是比如說子女把年邁虛弱的父母丟掉。

00:21:30 - 00:21:31
或者比如說。

00:21:31 - 00:21:34
長照機構的人，他們沒有好好照顧裡面的長輩。

00:21:34 - 00:21:35
這種的話是294。

00:21:36 - 00:21:40
接著後面有一個294之一，那個是遺棄罪的阻卻成立事由。

00:21:40 - 00:21:42
這個事由很特殊，我們等一下會去看它。

00:21:43 - 00:21:47
最後有一個沒有存在感的條文叫做295，遺棄直系血親尊親屬。

00:21:47 - 00:21:49
準確說，類似272條的規定。

00:21:50 - 00:21:50
好。

00:21:50 - 00:21:52
那我們先來看一個共同性的問題。

00:21:52 - 00:21:53
257頁這邊第二點，遺棄罪的危險犯性質。

00:21:57 - 00:21:59
這個東西是遺棄罪必考考點。

00:22:00 - 00:22:00
不厭其煩的考點。

00:22:01 - 00:22:05
真的，每次考遺棄罪，幾乎都在考這個東西。

00:22:05 - 00:22:06
要嘛考這個啦。

00:22:07 - 00:22:13
要嘛的話呢，考一個跟他相關、有關，跟他有相關的問題是那個撫養順序的問題，我們等一下會看到它。

00:22:14 - 00:22:14
好。

00:22:14 - 00:22:17
我們來看到，遺棄罪他是危險犯，沒有疑問。

00:22:17 - 00:22:19
那他是哪一種危險犯？

00:22:19 - 00:22:22
抽象危險犯，還是具體危險犯？

00:22:23 - 00:22:27
我想我們同學學到現在應該都知道，抽象危險犯的本質叫做行為犯。

00:22:28 - 00:22:33
抽象危險犯的意思是，當行為人做完行為，犯罪就成立了，管它有沒有危險，不管，犯罪照樣會成立，這個叫做抽象危險犯。

00:22:37 - 00:22:40
而具體危險犯的意思是，

00:22:41 - 00:22:48
這個犯罪，必須要個案當中真的有法益侵害的危險，犯罪才能成立，這個叫做具體危險犯，必須要真的有危險。

00:22:51 - 00:22:55
所以遺棄罪他是抽象危險犯，還是具體危險犯？

00:22:56 - 00:22:57
你說差別在哪裡？

00:22:58 - 00:23:05
如果有個媽媽剛生下一名小孩之後，她就把這個小孩留在警局的門口，然後人就跑掉了。

00:23:06 - 00:23:09
這樣的話，這個媽媽會不會成立遺棄罪？

00:23:09 - 00:23:11
他會不會成立本罪？

00:23:12 - 00:23:18
結論上來說啦，如果你說遺棄罪是抽象危險犯的話，行為人會成立本罪喔。

00:23:18 - 00:23:19
因為他有一切的行為，對不對？

00:23:20 - 00:23:23
但如果你說他是具體危險犯的話，行為人會不會成立本罪？

00:23:24 - 00:23:24
不會。

00:23:24 - 00:23:27
為什麼？因為小孩沒有生命上的危險，知道吧？

00:23:27 - 00:23:31
所以我們講，遺棄罪到底是抽象危險犯或具體危險犯，

00:23:31 - 00:23:33
它的區別實益就在於說呢，

00:23:33 - 00:23:39
那萬一在有些案例當中，行為人雖然有遺棄的作為，或者是不救助的不作為，

00:23:39 - 00:23:41
可是個案的生命卻沒有危險。

00:23:42 - 00:23:44
那行為人還能成立本罪嗎？這個就會有疑問。

00:23:45 - 00:23:45
好。

00:23:45 - 00:23:48
首先，各位一定要記得的是實務上的看法。

00:23:49 - 00:23:52
實務認為本罪是抽象危險犯。

00:23:53 - 00:23:54
實務的說法，

00:23:54 - 00:23:57
認為本罪是抽象危險犯。

00:23:57 - 00:23:59
實務很明確採這一說，好，為什麼呢？

00:24:00 - 00:24:00
抽象危險犯說確實也是部分學者的看法，但目前來說是少數說。

00:24:05 - 00:24:09
因為支持這一說最簡單的理由。

00:24:09 - 00:24:11
最簡單的理由是這個。

00:24:11 - 00:24:13
法條的規定。

00:24:13 - 00:24:15
你看喔，我們學刑分學到現在。

00:24:15 - 00:24:21
當我們說某個犯罪是具體危險犯的話，具體危險犯的條文，條文會寫什麼東西？

00:24:21 - 00:24:23
致生某某危險，對不對？

00:24:23 - 00:24:27
比如說放火罪是被175條的規定，致生公共危險。

00:24:27 - 00:24:30
所以持抽象危險犯說的學者就會說啊。

00:24:31 - 00:24:35
如果遺棄罪他真的是具體危險犯的話。

00:24:36 - 00:24:40
他的條文應該會說致使被害人生命的危險。

00:24:40 - 00:24:43
可是我們條文有這個規定嗎？

00:24:43 - 00:24:43
很明顯沒有，對不對？

00:24:44 - 00:24:47
不管是293、294條，條文都沒有這樣的規定。

00:24:47 - 00:24:51
所以從條文的規定本身來說呢，他應該是抽象危險犯，這第一點。

00:24:52 - 00:24:55
再來第二點是從他的刑度來推。

00:24:55 - 00:24:56
這個圖我就不再畫了。

00:24:57 - 00:24:59
來，抽象危險犯離實害近還是遠？

00:25:00 - 00:25:00
超遠，對不對？

00:25:01 - 00:25:04
我們講順序來說，先最遠的是抽象危險。

00:25:05 - 00:25:06
再來是繼續犯。

00:25:06 - 00:25:08
再來是具體危險犯。

00:25:08 - 00:25:09
最後才是實害犯，有印象吧？

00:25:11 - 00:25:13
抽象危險犯它離實害是最遠的。

00:25:14 - 00:25:17
所以既然抽象危險犯離實害遠的話，

00:25:18 - 00:25:19
它的刑度

00:25:19 - 00:25:20
應該也會很輕。

00:25:21 - 00:25:22
那反應在遺棄罪，沒有錯。

00:25:24 - 00:25:25
殺人罪是實害犯，那個刑度

00:25:26 - 00:25:28
十年起跳非常的重，而遺棄罪呢？

00:25:30 - 00:25:32
293輕到不可思議。

00:25:32 - 00:25:33
六個月以下。

00:25:34 - 00:25:35
然後294呢。

00:25:35 - 00:25:36
重一點，六個月以上。

00:25:37 - 00:25:38
五年以下。

00:25:39 - 00:25:44
他的刑度離殺人罪來說還算輕，還算遠，對不對？

00:25:44 - 00:25:45
其實還蠻輕的。

00:25:45 - 00:25:48
所以有學者會認為說294。

00:25:49 - 00:25:51
293這個遺棄罪呢。

00:25:51 - 00:25:53
他的本質應該是抽象危險犯。

00:25:53 - 00:25:59
因為如果是具體危險犯的話，具體危險犯離實害還近，他的刑度不可能到那麼輕，那下面你。

00:26:00 - 00:26:04
104年的實務見解，這個是一則最高法院的具有參考價值裁判。

00:26:04 - 00:26:09
這一則裁判，他也採取很明確的立場，採取的是抽象危險犯說。

00:26:10 - 00:26:12
只是那個內容，我就懶得去唸了，因為這個判決的內容說真的很無聊。

00:26:14 - 00:26:18
這個判決的內容，就在打高空講一些法理，然後最後，又講的一個很討厭的東西。

00:26:20 - 00:26:23
至少我很討厭啊，叫做國民法律感情。

00:26:25 - 00:26:28
我跟同學講過，我念法律實習到現在，我最討厭看到這句話。

00:26:29 - 00:26:30
我真的很討厭。

00:26:30 - 00:26:34
看到這句話，我一直講，為什麼法院的判決要去符合人民的法感情？

00:26:35 - 00:26:42
當一個法院的判決跟人民的法感情相抵觸的時候，你為什麼不說是人民的法學素養太差，人民的理性思考能力太差？

00:26:42 - 00:26:47
法院的判決不符合人民的法感情，那個是人民的問題吧，應該是人民應該檢討才對。

00:26:47 - 00:26:53
為什麼是法院的判決要去迎合這些不理性、沒有受過法治教育的人民呢？

00:26:54 - 00:26:57
我覺得我們司法人員要對自己有信心，不要去討好人民。

00:26:57 - 00:27:00
因為當法院的判決去迎合人民的法感情的時候，

00:27:00 - 00:27:03
它往往會得出一些非理性的結論。

00:27:03 - 00:27:08
就是情感上覺得好棒好爽，但這樣判下去，可能會造成一些不好的結果。

00:27:08 - 00:27:11
這個我我不贊同這個什麼人民法感情啦。

00:27:11 - 00:27:15
我們憲法第80條講得很清楚，法官要依法審判，不受任何的干涉。

00:27:16 - 00:27:20
法官當然不可以依照社會輿論或人民的法感情去審判，當然不可以喔。

00:27:23 - 00:27:26
所以在考卷上面你不要去寫什麼國民法感情這種東西。

00:27:27 - 00:27:28
不是我討厭而已。

00:27:28 - 00:27:30
我聽過好幾位學校老師，也對這種概念不以為然。

00:27:32 - 00:27:34
所以考卷上不要寫這種東西喔，提醒各位。

00:27:35 - 00:27:37
來，接著第二點，括號二，具體危險犯說。

00:27:40 - 00:27:43
學理上也有另外一種看法，認為說隱匿罪是具體危險犯。

00:27:44 - 00:27:45
為什麼呢？

00:27:45 - 00:27:47
具體危險犯說，他的理由。

00:27:47 - 00:27:50
我們翻到258頁這裡，主要幾個方面，第一個叫做刑法的最後手段性。

00:27:55 - 00:27:56
你看哦。

00:27:56 - 00:27:59
生命法益有實害犯，叫殺人罪。

00:27:59 - 00:28:00
生命

00:28:00 - 00:28:02
生命法益有危險犯，叫做遺棄罪。

00:28:02 - 00:28:07
那你在想，遺棄罪如果他真的是抽象危險犯的話，那會形成一個很詭異的結論喔。

00:28:08 - 00:28:10
生命法益有實害犯。

00:28:10 - 00:28:12
生命法益也有抽象危險犯，啊怎麼跳過具體危險犯了？

00:28:14 - 00:28:18
會有這個問題喔，所以這樣可能會導致法益保護的跳躍。

00:28:18 - 00:28:19
再來第二個呢。

00:28:20 - 00:28:22
我們講普遍的危險性。

00:28:23 - 00:28:25
放火罪173，他是一條抽象危險犯。

00:28:25 - 00:28:28
從來不會有人懷疑，為什麼？

00:28:30 - 00:28:32
因為你放火燒毀現供人使用的住宅

00:28:32 - 00:28:34
或現有人所在的建築物的時候，

00:28:34 - 00:28:37
這個行為一定會對建築物裡面的人的生命

00:28:37 - 00:28:39
產生典型的危險，

00:28:39 - 00:28:41
這個沒有人懷疑吧，對不對？

00:28:42 - 00:28:47
所以意思來說呢，遺棄這個放火罪是抽象危險犯，這件事是沒有人懷疑的。

00:28:48 - 00:28:48
可是喔。

00:28:50 - 00:28:50
遺棄罪呢。

00:28:51 - 00:28:51
你想喔。

00:28:52 - 00:29:01
以現在臺灣的社會狀況來講，通常遺棄一個無自救力的人，多半會造成他的生命危險嗎？

00:29:01 - 00:29:01
對啊。

00:29:01 - 00:29:05
你想嘛,通常把一個嬰兒丟在醫院的門口,會造成他生命的危險嗎?

00:29:06 - 00:29:07
好像不會,對不對?

00:29:07 - 00:29:13
以目前臺灣的社會安全網來講,通常遺棄一個無自理能力的人,未必會造成他生命上的危險。

00:29:14 - 00:29:21
所以以目前的社會現象來說,抽象危險犯說的理論很明顯,好像已經跟社會脫節了。

00:29:21 - 00:29:27
很明顯的,這個理論根本不符合抽象危險犯的立法初衷,叫做這個行為的典型危險性。

00:29:27 - 00:29:29
好,還有最後啊。

00:29:59 - 00:30:00
所以你向來說了。

00:30:00 - 00:30:04
把年邁失能的父母送往安養院之後，

00:30:04 - 00:30:05
從此不聞不問。

00:30:06 - 00:30:07
林東華老師在那本書上說,

00:30:07 - 00:30:09
這樣的行為會成立遺棄罪。

00:30:10 - 00:30:12
其實我一開始看到這段話,

00:30:12 - 00:30:13
我會覺得很困惑。

00:30:13 - 00:30:14
我會想說，來第一個，

00:30:15 - 00:30:16
把父母送往安養院,

00:30:16 - 00:30:18
這件事沒有犯法嘛。

00:30:18 - 00:30:21
因為本來就沒有法律規定說你要親自照顧父母啊,

00:30:22 - 00:30:24
送往安養院就是請他人代為履行扶養義務,

00:30:24 - 00:30:25
這OK嘛,

00:30:25 - 00:30:25
對不對？

00:30:26 - 00:30:27
這件事本身沒有犯法。

00:30:27 - 00:30:28
然後李棟老師說，

00:30:28 - 00:30:30
送往安養院之後不聞不問，

00:30:30 - 00:30:32
所以行為人會成立棄養罪。

00:30:32 - 00:30:33
那我那時候覺得困惑的點是，

00:30:34 - 00:30:34
蛤？

00:30:34 - 00:30:36
那所以平常有去看父母，

00:30:36 - 00:30:37
這個就不算遺棄。

00:30:38 - 00:30:40
送往安養院之後從此不再跟父母聯絡，

00:30:40 - 00:30:41
這個就叫遺棄。

00:30:41 - 00:30:42
不會吧。

00:30:42 - 00:30:43
那平常有沒有跟父母聯絡？

00:30:44 - 00:30:45
這不只是個人人品的問題而已嗎？

00:30:46 - 00:30:46
為什麼有聯絡？

00:30:47 - 00:30:49
這個就叫不成立犯罪

00:30:49 - 00:30:50
從此不聯絡

00:30:50 - 00:30:51
就叫遺棄罪呢？

00:30:51 - 00:30:53
後來我有一天我突然想通了。

00:30:53 - 00:30:55
林東茂老師這邊所講的不聞不問

00:30:55 - 00:30:57
指的應該不是說平常有沒有去看父母,

00:30:57 - 00:30:58
不是。

00:30:58 - 00:30:59
而是在指呢,

00:30:59 - 00:31:02
他有沒有定時給安養院錢。

00:31:02 - 00:31:03
這個是重要的。

00:31:03 - 00:31:04
為什麼？

00:31:04 - 00:31:06
因為有給錢的話就等於是怎麼樣？

00:31:06 - 00:31:08
找第三人代為履行撫養義務嘛。

00:31:09 - 00:31:10
但是如果沒有給錢的話，

00:31:11 - 00:31:15
代表他也沒有請第三人履行撫養義務的意思喔。

00:31:15 - 00:31:16
懂這個差別吧？

00:31:16 - 00:31:17
所以林老師會認為說，

00:31:18 - 00:31:20
這樣的行為會成立遺棄罪。

00:31:20 - 00:31:21
可是你回過頭來想啊，

00:31:23 - 00:31:24
這個說法一定會有問題。

00:31:25 - 00:31:29
因為行為人把父母送往長照機構之後，

00:31:29 - 00:31:31
從此就沒有給長照機構錢。

00:31:32 - 00:31:34
那長照機構可能基於人道的考量，

00:31:34 - 00:31:35
他不敢把這個老人丟出去吧。

00:31:36 - 00:31:36
對啊。

00:31:37 - 00:31:38
那你要想,

00:31:38 - 00:31:40
這個子女到底做錯了什麼？

00:31:41 - 00:31:44
他的行為有造成他父母生命上的危險嗎？

00:31:44 - 00:31:45
沒有,

00:31:45 - 00:31:46
你頂多說他人品差。

00:31:47 - 00:31:48
沒有履行扶養義務。

00:31:49 - 00:31:49
好啦,

00:31:49 - 00:31:50
不只人品差啦,

00:31:50 - 00:31:51
還有民事不法。

00:31:51 - 00:31:51
對啊,

00:31:51 - 00:31:52
就這樣子而已啊。

00:31:53 - 00:31:55
那這樣子沒有履行扶養義務的民事不法,

00:31:55 - 00:31:57
根本沒有造成任何人生命的危險,

00:31:58 - 00:31:59
你判他遺棄罪幹什麼?

00:31:59 - 00:32:00
那你

00:32:00 - 00:32:01
就回歸民法處理不就好了嗎？

00:32:01 - 00:32:03
所以許澤天老師批評得很正確，

00:32:04 - 00:32:07
他認為如果你說遺棄罪是一條抽象危險犯的話，

00:32:08 - 00:32:09
那麼運作下來的結果，

00:32:09 - 00:32:12
很可能就會造成說，行為人一違反扶養義務，

00:32:13 - 00:32:17
而這個撫養權利人是一個無自救力的人的話，行為人就成立本罪。

00:32:17 - 00:32:22
會讓這條罪完全喪失生命法益的本質，而變成是一種違反撫養義務的犯罪。

00:32:22 - 00:32:26
所以這裡呢，有一些這個批評。

00:32:26 - 00:32:29
所以學者的多數說會比較傾向具體危險犯說。

00:32:30 - 00:32:37
好，那下面的話這個題目，我們等一下再來看，因為這個會牽涉到那個撫養義務的順位。

00:32:37 - 00:32:40
接下來第三點，遺棄罪跟殺人罪的區分。

00:32:41 - 00:32:42
剛剛我跟各位說了，

00:32:42 - 00:32:44
我們在寫考卷的時候，

00:32:45 - 00:32:47
正常來說，我們不需要，

00:32:47 - 00:32:51
應該說啦，當行為人已經成立殺人罪的時候，

00:32:51 - 00:32:54
我們就不需要再去寫遺棄罪了。

00:32:55 - 00:32:55
知道嗎？

00:32:55 - 00:32:58
當行為人已經能成立殺人罪的時候，

00:32:58 - 00:33:01
我們就不需要再去寫遺棄罪了。

00:33:02 - 00:33:09
也就是啊，當行為人沒有殺人故意的時候，我們去檢討遺棄罪，這才有檢討的實益。

00:33:09 - 00:33:09
知道嗎？

00:33:10 - 00:33:13
否則如果行為人有殺人故意的話，

00:33:13 - 00:33:15
他已經有殺人故意了喔。

00:33:16 - 00:33:18
那我們論他殺人罪不就充分評價了嗎？

00:33:18 - 00:33:20
這個時候遺棄罪做什麼呢？

00:33:20 - 00:33:21
沒有意義，

00:33:21 - 00:33:21
知道嗎？

00:33:21 - 00:33:28
所以，當行為人具有殺人故意的時候，我們就優先論行為人殺人罪，這樣就好了。

00:33:30 - 00:33:33
好，那接下來可能會遇到一個問題是這樣子。

00:33:35 - 00:33:36
可能會遇到一個問題。

00:33:36 - 00:33:39
那我們要怎麼判斷行為人他已經具有殺人故意？

00:33:40 - 00:33:41
這可能沒那麼簡單吧？

00:33:41 - 00:33:43
我們要怎麼去認定行為人已經具有殺人故意？

00:33:44 - 00:33:52
所以這個東西，就回到我們前面跟各位說過的，當一個題目當中沒有特別去說行為人他主觀上出於什麼想法的時候，

00:33:52 - 00:34:00
那我們呢，就要依照題目當中所給的線索去推斷行為人他主觀上在

00:34:00 - 00:34:00
想什麼。

00:34:01 - 00:34:08
所以如果題目當中給的線索，我們看到行為人，他只是有意識到被害人的生命危險，

00:34:08 - 00:34:10
但並沒有覺得被害人死了也沒有關係。

00:34:10 - 00:34:14
如果是這樣子的話，那行為人就叫做遺棄故意，

00:34:15 - 00:34:16
就叫做遺棄故意。

00:34:16 - 00:34:21
可是如果從題目裡面給的線索我們看得出來，行為人他根本不在乎被害人的死活。

00:34:21 - 00:34:23
無所謂啦，死了跟我屁事啊。

00:34:23 - 00:34:26
如果是那樣的想法，那個就是殺人故意喔。

00:34:26 - 00:34:27
你要會分喔，那個就是殺人故意喔。

00:34:28 - 00:34:33
所以我們翻過來，260頁這邊，來看到這個題目。

00:34:37 - 00:34:40
這個是10年前警特四等的考題。

00:35:21 - 00:35:23
這個題目啊,10年前警特四等,

00:35:24 - 00:35:27
這一題我覺得設計的還不錯,要同學去判斷題意。

00:35:28 - 00:35:33
呃,你們覺得齁,一家三口,爸爸、媽媽還有兒子。

00:35:33 - 00:35:39
這個老媽媽是年老失能的無自救力人,而且已經奄奄一息的狀態了。

00:35:40 - 00:35:49
結果這個爸爸跟兒子把這個年老而失能的媽媽送到殯儀館，請他們暫時的去做冰存。

00:35:49 - 00:35:52
你覺得這個爸爸跟兒子，這對父子，他們是什麼故意？

00:35:53 - 00:35:55
那不用懷疑，當然是殺人故意。

00:35:55 - 00:35:57
好嗎？當然是殺人故意喔。

00:35:57 - 00:36:00
欸，這種題目你不要很白爛的跟我說。

00:36:00 - 00:36:02
題目裡面有沒有跟我說他有殺人故意，我們罪疑為輕的遺棄故意。

00:36:03 - 00:36:05
這就白痴寫法，不可以這樣寫，知道嗎？

00:36:06 - 00:36:09
題目裡面沒有講行為人出於什麼故意，你就要依照題目給的事實去做判斷。

00:36:12 - 00:36:13
這個沒有什麼好罪疑為輕的啦。

00:36:14 - 00:36:16
罪疑為輕的前提是

00:36:17 - 00:36:18
事實不明。

00:36:18 - 00:36:19
這一題哪有事實不明？

00:36:20 - 00:36:21
對啊，這題事實很明確啊。

00:36:22 - 00:36:25
就是他把一個嬰兒一個老人送殯儀館，說那個是屍體。

00:36:25 - 00:36:27
行為人根本希望被害人死掉吧，對不對？

00:36:28 - 00:36:29
所以這個題是殺人故意喔。

00:36:29 - 00:36:31
這一題你不要去寫遺棄罪,不可能,知道嗎?

00:36:31 - 00:36:33
這個題是殺人故意喔。

00:36:33 - 00:36:33
好。

00:36:35 - 00:36:37
所以這個我們要會分喔。

00:36:37 - 00:36:38
接下來第四點這邊。

00:36:39 - 00:36:44
遺棄罪可不可以經由被害人承諾而阻卻違法？

00:36:46 - 00:36:48
這個東西啊，是前幾年的新議題。

00:36:48 - 00:36:51
那在前幾年的高考法是有考過。

00:36:52 - 00:36:53
呃，我們講啊。

00:36:54 - 00:36:55
什麼叫遺棄罪的被害人承諾？

00:36:56 - 00:36:58
或者我們先講法律面的問題。

00:36:58 - 00:37:01
遺棄罪可不可以被承諾阻卻違法？

00:37:01 - 00:37:03
先說實務跟傳統的看法。

00:37:04 - 00:37:07
實務見解跟傳統的學說認為呢？

00:37:07 - 00:37:11
遺棄罪不能經過被害人承諾阻卻違法,不能,為什麼?

00:37:13 - 00:37:16
因為傳統見解會說來遺棄罪保護什麼犯罪啊?

00:37:17 - 00:37:18
生命,對不對?

00:37:18 - 00:37:19
生命可不可以承諾?

00:37:20 - 00:37:21
不可以嘛。

00:37:21 - 00:37:22
答案就這樣嗎,對不對?

00:37:22 - 00:37:24
所以傳統認為說呢,既然

00:37:24 - 00:37:27
遺棄罪是一個保護生命法益的犯罪,而生命法益

00:37:27 - 00:37:30
又不允許被害人承諾,所以遺棄罪

00:37:31 - 00:37:35
可不可以經由被害人的承諾而阻卻違法呢?

00:37:35 - 00:37:37
答案就是不可以，知道嗎？

00:37:37 - 00:37:37
就是不可以，這個是

00:37:38 - 00:37:39
傳統下面的說法。

00:37:40 - 00:37:44
可是我認為這個問題，臺大的謝玉偉老師說的說法更能說服我。

00:37:45 - 00:37:49
謝玉偉老師認為說遺棄罪應該要可以被害人承諾。

00:37:49 - 00:37:50
要可以,為什麼?

00:37:52 - 00:37:54
謝老師的思考是這樣喔。

00:37:54 - 00:37:55
我覺得也有道理,分享給各位。

00:37:56 - 00:37:58
謝老師認為說,來我們先思考一件事喔。

00:38:00 - 00:38:05
我們講說生命法益,不可以被案人承諾主卻違法,我們是怎麼推出來的。

00:38:06 - 00:38:09
275，受囑託的承諾殺人，對吧。

00:38:09 - 00:38:13
因為在殺人這當中，就算被害人說我好想死，你殺了我好不好。

00:38:14 - 00:38:16
行為人也還是會成立275的犯罪。

00:38:18 - 00:38:23
所以我們由此可以推導說呢，生命法益不容被害人的處分。

00:38:23 - 00:38:25
好，可是各位你接著想一個問題。

00:38:26 - 00:38:28
遺棄罪的被害人承諾。

00:38:29 - 00:38:32
是被害人在處分他的生命，捨棄他的生命嗎？

00:38:33 - 00:38:33
其實不是。

00:38:34 - 00:38:36
你知道遺棄罪的構成是什麼情況嗎？

00:38:36 - 00:38:39
好，比如說我過年回我老家的時候啊，我在家裡吸毒。

00:38:40 - 00:38:44
我吸到有點過量，口吐白沫倒在地上，意識有點不太清楚。

00:38:44 - 00:38:50
我爸要把我送醫院，我就跟我爸說，拜託不要把我送到醫院，我送到醫院好，會被警察抓，我要進去關的，你不要送我到醫院好。

00:38:51 - 00:38:55
你讓我喝點水，幫我扇扇風，過半個小時呢，我應該就沒事了。

00:38:56 - 00:38:58
這叫做遺棄罪的被害人承諾。

00:38:59 - 00:39:01
這有涉及到生命的危機嗎？

00:39:01 - 00:39:01
沒有啊，對不對。

00:39:02 - 00:39:03
這裡又沒有涉及生命的處分。

00:39:04 - 00:39:05
所以跟275沒有關係嘛。

00:39:05 - 00:39:07
而且再來，那遺棄罪當中。

00:39:08 - 00:39:11
有沒有類似275的那種加重遺棄的規定。

00:39:12 - 00:39:12
也沒有啊，對不對。

00:39:13 - 00:39:14
那既然沒有的話，我們基於尊重被害人意願的考量。

00:39:18 - 00:39:22
承認被害人承諾的有效性，讓遺棄罪可以被承諾阻卻違法。

00:39:23 - 00:39:23
這樣不好嗎？

00:39:24 - 00:39:25
這樣不是更能尊重被害人的意願嗎，對不對？

00:39:26 - 00:39:28
所以我認為學說上許玉偉老師的看法是更有說服力的。

00:39:31 - 00:39:34
簡單講一句啦，為什麼遺棄罪可以被承諾阻卻違法。

00:39:34 - 00:39:38
因為遺棄罪的被害人承諾，並不涉及到生命的捨棄。

00:39:39 - 00:39:39
瞭解吧。

00:39:40 - 00:39:42
因為我們刑法的底線是生命不可以捨棄嘛，有275的存在。

00:39:43 - 00:39:46
既然遺棄罪的被害人承諾，並沒有涉及到生命的捨棄，那為什麼不行？

00:39:48 - 00:39:49
我們都尊重被害人的意思啊，這不好吧，對不對？

00:39:51 - 00:39:54
所以喔，我認為許偉老師的看法應該比較合理喔。

00:39:55 - 00:39:58
下面這個考題262頁。

00:40:00 - 00:40:01
這一題就在考這個問題。

00:40:02 - 00:40:03
這一題我不去計較。

00:40:03 - 00:40:04
我先跟你們講，

00:40:04 - 00:40:08
這一題很多的參考書跟網路上的解答都寫錯，

00:40:08 - 00:40:10
就是寫錯不用懷疑。

00:40:10 - 00:40:12
對，因為很多人來問我。

00:40:12 - 00:40:15
真的啦，很多網路上解答，公職王這一題根本亂解。

00:40:16 - 00:40:18
不是我解的，我解的我怎麼會說自己亂解，對不對？

00:40:18 - 00:40:20
公職王上面這題根本就亂解。

00:40:20 - 00:40:23
然後有一些其他家的參考書，這一題也在亂解。

00:40:23 - 00:40:25
因為他們都沒有看過文章。

00:40:26 - 00:40:29
我可以很坦白的跟各位說，這一題剛出來的時候，

00:40:29 - 00:40:32
我還沒看過文章的時候，我自己試圖去解，我也在亂解。

00:40:33 - 00:40:36
但當我看過文章之後，我就發現我錯了，我就趕快做修正。

00:40:37 - 00:40:40
但其他人好像沒有，他們不知道是不知道還是怎麼樣。

00:40:41 - 00:40:41
反正啦。

00:40:42 - 00:40:47
這一題它在考的就是遺棄罪可不可以經由被害人承諾而阻卻違法。

00:40:48 - 00:40:52
所以你去看那個寫什麼過失致死罪的寫什麼的，那個解法就不對，知道嗎？

00:40:52 - 00:40:54
這一題就是文章題，就是文章題。

00:40:56 - 00:40:59
詳細的我們等一下再說，因為這一題還會提到遺棄罪其他的問題。

00:41:40 - 00:41:45
接下來，我們來看到263頁，我們來看到普通的遺棄罪293。

00:41:57 - 00:42:00
好，293是一般的遺棄罪。

00:42:00 - 00:42:01
這一條的遺棄，僅限於作為，不包括不作為，為什麼呢？

00:42:05 - 00:42:08
這件事我們應該在第一次還第二次上課有講過，但沒關係，我再幫同學複習一下。

00:42:37 - 00:42:44
好，293他的行為僅限於積極作為，而不包括消極的不作為。

00:42:44 - 00:42:51
所以我們說，對一個流浪漢，他在跟你呼救，而你不去救他，你不會成立遺棄罪。

00:42:51 - 00:42:53
這個結論我們都知道，來怎麼推導出來的？

00:42:54 - 00:42:56
我再講一次，這個我們在刑總講過。

00:42:57 - 00:43:00
光就293來講，293的行為僅

00:44:00 - 00:44:01
那樣叫做遺棄。

00:44:01 - 00:44:06
那293的遺棄這兩個字，我們單看遺棄這兩個字，

00:44:07 - 00:44:07
語意上來說，

00:44:08 - 00:44:12
遺棄這兩個字，可不可以包括消極不作為在內？

00:44:13 - 00:44:14
其實可以啊，對不對？

00:44:15 - 00:44:17
有個人出去玩五天，

00:44:17 - 00:44:20
結果他家的狗，他完全沒有給牠飼料跟水。

00:44:21 - 00:44:22
回家之後那條狗奄奄一息,

00:44:22 - 00:44:24
你可不可以說他遺棄他的狗？

00:44:24 - 00:44:25
好像可以，對不對？

00:44:25 - 00:44:31
所以單就文意上來說，遺棄這兩個字，確實可以包括消極的不作為在內。

00:44:31 - 00:44:33
可是，我們對照294。

00:44:34 - 00:44:41
294的行為，態樣除了遺棄之外，還包括了不為生存所必要的輔助、養育或保護。

00:44:41 - 00:44:46
那你看哦，不為生存所必要的輔助、養育或保護，它百分之百一定是什麼呢？

00:44:47 - 00:44:48
一定是不作為嘛，對不對？

00:44:48 - 00:44:51
所以反過來推，那294的遺棄是作為還不作為？

00:44:52 - 00:44:55
所以反過來推，那遺棄兩個字是作為還不作為？

00:44:55 - 00:44:56
當然限縮作為啊，對不對？

00:44:57 - 00:44:58
那你再看293，

00:44:58 - 00:45:40
293是不是只有寫遺棄？

00:45:40 - 00:45:43
他並沒有寫不為生存所必要的輔助、養育或保護，

00:45:44 - 00:45:46
那我們經過294的推導之後，遺棄限縮作為嘛。

00:45:47 - 00:45:53
只有遺棄，又沒有不為生存所必要的輔助養育或保護，所以它僅限於什麼才能成立？

00:45:54 - 00:45:55
作為，就這樣推的，知道嗎？

00:45:55 - 00:45:57
這是法條的體系解釋。

00:45:59 - 00:45:59
好，

00:45:59 - 00:46:00
那再來的話

00:46:00 - 00:46:05
對啊,你在臺北市上門口,看到有一個乞丐流浪漢,你還那麼無聊啊,開車把他載去山上丟掉。

00:46:06 - 00:46:07
一般人不會那麼無聊,知道嗎?

00:46:07 - 00:46:11
所以293,想像上存在,但實際上很少有人會去犯。

00:46:12 - 00:46:15
通常會犯的遺棄罪,往往都是294。

00:46:15 - 00:46:21
所以各位你會發現,很多遺棄罪的爭議問題,都在談294。

00:46:21 - 00:46:24
並不是說這個問題只有在294才會發生，不是。

00:46:25 - 00:46:26
而是為什麼呢？

00:46:27 - 00:46:30
因為實務上發生的遺棄罪，幾乎都在294。

00:46:30 - 00:46:34
就像你看剛剛那個問題，抽象危險犯說跟具體危險犯說。

00:46:34 - 00:46:37
兩說，幾乎都是放在294之下討論。

00:46:38 - 00:46:40
並不是說293沒有這個問題，不是。

00:46:40 - 00:46:42
而是293在實務上不容易發生，知道嗎？

00:46:42 - 00:46:44
所以這個觀念同學你要知道。

00:46:45 - 00:46:45
好。

00:46:47 - 00:46:47
那我們來看294喔。

00:46:48 - 00:46:53
這一條，它是一個純正犯，它是一個身分犯。

00:46:53 - 00:46:59
這一條罪必須行為人對別人有依法律或契約的救助義務，法律或契約。

00:47:00 - 00:47:03
所以這邊講得很清楚啊，法律或契約。

00:47:04 - 00:47:06
請記住，只有這兩個才算。

00:47:07 - 00:47:10
它跟刑總保證人的地位來源不一樣喔。

00:47:10 - 00:47:15
刑總上面保證人的地位來源除了法定跟契約之外，還包括了其他東西嗎？什麼為共同體什麼的，但這裡沒有。

00:47:16 - 00:47:18
這裡只有法令跟契約，它只有這兩種喔。

00:47:18 - 00:47:21
只有法令跟契約。

00:47:24 - 00:47:24
好。

00:47:24 - 00:47:25
所以第一個法令。

00:47:25 - 00:47:27
我們看這個法令包括什麼呢？

00:47:27 - 00:47:32
比如說15條第二項的危險前行為，又或者比如說像民法當中的扶養義務，這些。

00:47:32 - 00:47:34
這個是我們這邊所說的法令。

00:47:34 - 00:47:39
相對來說，如果這個法令，它雖然有寫應或不得，但如果這個法令經過體系上的解釋，認為說它只是一個訓示規定的話，

00:47:40 - 00:47:43
那種東西就不是遺棄罪的法令依據。

00:47:43 - 00:47:45
所以這個是第一個我們講法令。

00:47:45 - 00:47:49
像刑法第15條第二項啊，或者是一些這個民事法、行政法，這個都算。

00:48:00 - 00:48:01
接著第二點叫做契約，

00:48:02 - 00:48:03
契約看的是，

00:48:03 - 00:48:06
這邊有沒有一個事實上的承擔行為。

00:48:07 - 00:48:10
這裡的契約就是有一個承擔的行為就可以,

00:48:10 - 00:48:13
不需要實際上那個契約有成立生效,

00:48:13 - 00:48:13
不用,

00:48:13 - 00:48:17
但不管怎麼樣呢,都要有法令或契約的義務,

00:48:17 - 00:48:18
這個才算

00:48:18 - 00:48:18
好。

00:48:21 - 00:48:22
好，那我們來看一個題目，

00:48:23 - 00:48:25
今年高考有考到的。

00:48:43 - 00:48:45
我們來看第57頁的第一題。

00:50:00 - 00:50:00
的故意。

00:50:01 - 00:50:07
同學啊，你不能因為被害人有生命危險而行為人知道這件事，你就說他容忍。

00:50:08 - 00:50:09
我們再強調一次喔！

00:50:10 - 00:50:13
間接故意是要有認識再加上容忍。

00:50:14 - 00:50:16
認識加容忍，這個才叫間接故意。

00:50:17 - 00:50:19
如果是認識而去信其不發生，

00:50:20 - 00:50:22
那個叫做有認識過失。

00:50:22 - 00:50:23
知道吧？

00:50:23 - 00:50:27
所以如果你說有認識，他就是不確定故意。

00:50:27 - 00:50:29
如果你要這樣說的話，

00:50:29 - 00:50:33
那你的法學知識就跟那些在雅虎新聞下面留言的那些人一樣。

00:50:34 - 00:50:35
不要有這種奇怪的想法,知道嗎?

00:50:35 - 00:50:38
有認識不代表他就是容忍。

00:50:39 - 00:50:41
你要想，這一題當中，

00:50:42 - 00:50:43
這個甲，

00:50:44 - 00:50:45
他會覺得A死了也沒關係嗎？

00:50:46 - 00:50:47
我認為是不會啦。

00:50:48 - 00:50:49
他跟那個人無冤無仇的，

00:50:50 - 00:50:51
覺得他死了也沒關係。

00:50:51 - 00:50:53
他死了以後就少了一個損友嘞，對不對？

00:50:53 - 00:50:59
所以我會認為說，這一題當中從題意來看，應該看不出來說行為人對人的死亡是容忍的。

00:50:59 - 00:50:59
應該沒有。

00:51:00 - 00:51:03
行為人他應該只是認知到被害人的生命處於一個危險的狀態，

00:51:04 - 00:51:06
所以這一題呢，應該不會有殺人罪的成立，

00:51:06 - 00:51:07
沒辦法論殺人罪。

00:51:07 - 00:51:10
好，那接下來可不可以論遺棄致死罪？

00:51:11 - 00:51:13
因為294有加重結果犯嘛,

00:51:13 - 00:51:14
可不可以論遺棄罪？

00:51:14 - 00:51:17
來，我們先想，293不可能，為什麼？

00:51:18 - 00:51:19
因為他是不作為嘛，對不對？

00:51:20 - 00:51:20
他是不作為。

00:51:23 - 00:51:26
欸你不要講說他把A移到可避雨之處,

00:51:26 - 00:51:27
這個叫作為喔。

00:51:28 - 00:51:29
不是喔，這一題是不作為喔。

00:51:29 - 00:51:36
因為這一題我們要譴責的對象並不是說他的空間移動，而是說他並沒有採取最有效的救助措施嘛。

00:51:36 - 00:51:37
所以這一題是一個不作為，你知道嗎？

00:51:38 - 00:51:41
所以不作為的話，我們就可以排除了。

00:51:41 - 00:51:43
那會不會成立？

00:51:44 - 00:51:48
那我們講的行為人主體要什麼？他的行為主體要什麼東西？

00:51:49 - 00:51:51
依法令或契約，對不對？

00:51:51 - 00:51:52
這題有沒有法令？

00:51:53 - 00:51:53
沒有。

00:51:53 - 00:51:54
那有沒有契約？

00:51:54 - 00:51:55
也沒有。

00:51:55 - 00:51:56
你說那不是危險共同體？

00:51:56 - 00:51:58
危險共同體那個叫保證人地位。

00:51:58 - 00:51:59
那個不是契約，好嗎？

00:52:00 - 00:52:01
294是要遵守罪刑法定原則喔。

00:52:02 - 00:52:03
法條就寫法令跟契約，

00:52:04 - 00:52:07
所以294這邊行為人也不會成立，

00:52:07 - 00:52:08
因為他根本不是這條罪的行為主體。

00:52:09 - 00:52:10
所以行為人可以論什麼？

00:52:11 - 00:52:13
過失致死的不作為犯。

00:52:13 - 00:52:13
好吧，

00:52:14 - 00:52:17
這裡行為人他只能論過失致死的不作為犯。

00:52:18 - 00:52:19
這裡不作為犯的保證人地位是什麼呢？

00:52:20 - 00:52:22
就是危險共同體，

00:52:22 - 00:52:23
知道嗎？

00:52:23 - 00:52:24
你想看完整的解答的話，

00:52:24 - 00:52:25
公職王這一本是我解的，

00:52:26 - 00:52:26
你們可以看喔！

00:52:27 - 00:52:30
反正這一題當中考點就是遺棄罪的主體資格

00:52:31 - 00:52:32
要遵守罪刑法定。

00:52:33 - 00:52:35
你不能把那個保證人地位全部都拿來用

00:52:35 - 00:52:36
不可以喔

00:52:36 - 00:52:39
遺棄罪嚴格的限於法令或契約

00:52:39 - 00:52:40
嚴格限於這兩種喔。

00:52:42 - 00:52:43
好,

00:52:43 - 00:52:44
那再來的話,

00:52:44 - 00:52:48
我們回來看一下剛剛那個262頁這一題。

00:53:47 - 00:53:48
好,

00:53:48 - 00:53:50
這一題當中我覺得它題目有點，

00:53:50 - 00:53:52
有一個地方出的不是很好。

00:53:52 - 00:53:55
題目裡面說甲乙是同居人。

00:53:56 - 00:53:57
好，

00:53:57 - 00:53:58
這個地方我覺得設計的不好。

00:53:58 - 00:53:59
為什麼呢?

00:54:00 - 00:54:00
人他欠缺主體資格,他又是不作為,所以他構成一些不該當。

00:54:03 - 00:54:05
那這題你要寫什麼,對不對?

00:54:05 - 00:54:11
所以這一題,他題目有一個bug,因此你要盡可能地把它拗到有東西可以寫,於是你要怎麼說呢?

00:54:12 - 00:54:16
你要說啊,甲乙他們是一種永久共同生活為目的的同居。

00:54:17 - 00:54:25
因為在民法上面說，如果是以永久共同生活為目的的同居的話，那個時候在民法上會視為家長跟家屬的關係。

00:54:25 - 00:54:28
這時候呢，就會有法律上的扶養義務。

00:54:28 - 00:54:29
你要這樣拗才合理，知道嗎？

00:54:30 - 00:54:34
所以這裡的話呢，我們一定要把行為人說成是294的行為主體。

00:54:35 - 00:54:37
那麼接下來，我這邊也寫到了。

00:54:39 - 00:54:41
被害人說，沒關係，不用救他。

00:54:42 - 00:54:46
所以這裡就會牽涉到說，那遺棄罪可不可以經由被害人承諾而阻卻違法。

00:54:46 - 00:54:48
正反意見，我們並列。

00:54:48 - 00:54:49
有人認為說可以。

00:54:50 - 00:54:51
也有人認為說不行。

00:54:51 - 00:54:54
那我會認為說可以的說法應該比較合理。

00:54:54 - 00:54:59
因為我強調了，遺棄罪的被害人承諾，並不是涉及到生命的捨棄。

00:54:59 - 00:55:03
遺棄罪的被害人承諾，他只是被害人自願承擔危險而已。

00:55:03 - 00:55:05
被害人並沒有在處分他的生命。

00:55:06 - 00:55:07
我們法條也沒有禁止。

00:55:07 - 00:55:09
所以這裡應該是沒有否定的道理才對，這個是我的想法。

00:55:11 - 00:55:12
好，那最後這裡說啊，

00:55:13 - 00:55:19
專家鑑定，即使甲如有遲疑，請速送醫的話，也會因為多重器官衰竭而無法被救治。

00:55:20 - 00:55:21
這邊我跟同學強調喔，這個是一個很常見的誤會。

00:55:26 - 00:55:33
遺棄罪當中，如果題目跟你說，就算這個人有及時被送醫，但他的傷勢過重，所以他也救不活。

00:55:34 - 00:55:35
遺棄罪還是成立喔。

00:55:36 - 00:55:39
這裡只代表他不會升級成加重結果犯而已。

00:55:40 - 00:55:41
知道嗎？

00:55:41 - 00:55:44
因為我們講，遺棄罪他罰的是什麼？

00:55:45 - 00:55:46
這些行為，對不對？

00:55:46 - 00:55:47
遺棄的行為、不救助的行為。

00:55:47 - 00:55:49
那你由這些行為犯罪就成立啦。

00:55:50 - 00:55:52
至於被害人是不是因此而死,

00:55:52 - 00:55:57
那個是會不會升級變加重結果犯的問題，聽得懂嗎?

00:55:57 - 00:55:59
那個是會不會升級變加重結果犯的問題。

00:56:00 - 00:56:00
所以這一題當中,很明顯是怎麼樣?

00:56:02 - 00:56:07
被害人的死亡結果,跟行為人不救助的行為之間,沒有因果關係。

00:56:08 - 00:56:11
那只代表他不會成立加重結果犯,而你不能回過頭來說,所以他遺棄罪都不成立,不可以這樣說,知道嗎?

00:56:11 - 00:56:16
那個是兩個不同層次的問題哦。

00:56:21 - 00:56:23
好,這個問題我們看到這邊。

00:56:26 - 00:56:27
OK，這個問題我們看到這邊喔。

00:56:28 - 00:56:29
這個，好。

00:56:29 - 00:56:31
那剛好11點喔，我們休息一下。

00:56:31 - 00:56:34
後面幾個比較複雜的問題呢，我們先休息完等一下再來看。

00:56:40 - 00:56:45
好，那我們接著來看到265頁的這個問題，265頁。

00:56:46 - 00:56:47
這個是一個很深的問題啦。

00:56:47 - 00:56:50
在談說那個294啊，他是，

00:56:50 - 00:56:52
他294他的身份，

00:56:52 - 00:56:54
他是一種純正身份犯，

00:56:54 - 00:56:57
還是他是一種不純正身份犯，

00:56:57 - 00:56:58
這個是第二個。

00:56:59 - 00:57:02
這個是一個比較偏文章體的考點。

00:57:02 - 00:57:11
那這個東西以前我，我在課程上，到後面有點不太想講，可是前幾年竟然考了，而且還考在普考，讓我覺得很意外，普考考這種東西哦。

00:57:13 - 00:57:14
所以我來講一下這個問題是什麼。

00:57:16 - 00:57:17
我們先想喔。

00:57:18 - 00:57:20
293跟294，你覺得它們是什麼關係？

00:57:21 - 00:57:24
是不是看起來很像293是基本，294是加重？

00:57:25 - 00:57:25
看起來很像，對不對？

00:57:25 - 00:57:27
293基本，294加重。

00:57:27 - 00:57:30
所以294的身份犯，如果你說293是基本，294是加重的話。

00:57:33 - 00:57:37
那293的，294的身份犯是一種什麼身份犯？

00:57:38 - 00:57:39
純正，對不對？

00:57:39 - 00:57:42
看起來感覺它是一種純正，抱歉，不純正的，294看起來像是一種不純正的身份犯。

00:57:45 - 00:57:46
好。

00:57:46 - 00:57:48
那麼接下來的問題就在下面。

00:57:49 - 00:57:52
你看我這邊所舉的這個例子，貪汙偷懶案。

00:57:54 - 00:57:55
256頁這邊，我寫一下喔。

00:58:28 - 00:58:31
好，B是被看護者

00:58:31 - 00:58:32
B受僱照顧者

00:58:32 - 00:58:32
老人C

00:58:32 - 00:58:37
有一天假日的時候，B的朋友A，A就跟B說，我們出去玩

00:58:37 - 00:58:40
B就想說，這是可以嗎？我要照顧C耶。

00:58:40 - 00:58:43
說沒差啦，你去玩一天這個C不會死啦。

00:58:43 - 00:58:45
B受不了誘惑，B就跟A出去玩了。

00:58:46 - 00:58:52
那A跟B出去玩之後，B很晚回到家，看到那個老人C，奄奄一息地倒在地上。

00:58:52 - 00:58:52
還好C沒有死掉。

00:58:52 - 00:58:54
這時候，B犯什麼罪？

00:58:55 - 00:58:56
這沒有疑問嘛。

00:58:57 - 00:59:00
B是看護嘛，他沒有照顧老人，所以B犯什麼罪呢？

00:59:00 - 00:59:02
294的第一項，對不對？

00:59:02 - 00:59:03
這個沒有疑問，B對這個老人呢

00:59:04 - 00:59:08
犯的是294條第一項的遺棄罪，OK，這個沒有疑問。

00:59:09 - 00:59:11
那再來這個A犯什麼罪？

00:59:12 - 00:59:13
這個A犯什麼罪？

00:59:14 - 00:59:16
A的話，他成立哪一條罪的教唆犯？

00:59:17 - 00:59:18
依照我們剛剛的論述，

00:59:19 - 00:59:22
如果你說294是293的加重，所以294的身分是一種

00:59:22 - 00:59:26
不純正身分犯的話，那A要論什麼的教唆犯？

00:59:28 - 00:59:29
293，對吧？

00:59:30 - 00:59:31
A看起來要論293的教唆犯

00:59:31 - 00:59:33
可是這裡會卡住喔

00:59:33 - 00:59:35
B做的是294的哪一種行為

00:59:36 - 00:59:37
不作為，對吧

00:59:37 - 00:59:39
B做的是294的不作為，好，那你想喔

00:59:40 - 00:59:43
B做的是294的不作為的話，那如果你說

00:59:44 - 00:59:46
A要論293的教唆犯，293有這種不作為的態樣嗎

00:59:49 - 00:59:49
沒有

00:59:49 - 00:59:50
瞭解我的意思吧

00:59:50 - 00:59:51
根本沒有

00:59:51 - 00:59:53
所以你有沒有發現，到這邊根本就卡住了

00:59:54 - 00:59:56
如果你說294是293的加重，那所以沒有身分的A

00:59:56 - 00:59:59
他依照31條第二項

01:00:00 - 01:00:03
只能回去論293的教唆犯，

01:00:03 - 01:00:08
可是問題是293的教唆犯根本就沒有不作為的這種行為態樣

01:00:08 - 01:00:12
293的條文裡面根本沒有不作為的這種行為，

01:00:12 - 01:00:14
所以你要怎麼論293的教唆犯？

01:00:14 - 01:00:16
根本論不了，對不對？

01:00:16 - 01:00:19
所以有學者認為說294，

01:00:20 - 01:00:23
他的身分根本是純正身分犯。

01:00:24 - 01:00:28
也就是，294跟293它並不是基本跟加重的關係，

01:00:28 - 01:00:31
294是一個獨立的條文，

01:00:31 - 01:00:33
知道嗎？294是個獨立的條文，

01:00:33 - 01:00:36
所以如果你說294是一個獨立的條文的話，

01:00:36 - 01:00:40
那麼293跟294就沒有關係了。

01:00:40 - 01:00:42
那294的身份變什麼身份？

01:00:42 - 01:00:44
純正身份犯，

01:00:44 - 01:00:45
有這樣的說法，知道嗎？

01:00:45 - 01:00:48
294它會變成是一條純正身份犯，

01:00:48 - 01:00:51
所以這時候啊，沒有身份的人怎麼論罪？

01:00:51 - 01:00:56
沒有身分的A，他論的就是294的教唆犯。

01:00:56 - 01:00:58
然後因為他沒有身分嘛，

01:00:58 - 01:01:16
所以要用31條第一項

01:01:16 - 01:01:25
類此身分，

01:01:25 - 01:01:43
但是A可以減輕其刑。

01:01:43 - 01:01:49
所以這裡的說法呢，有學者認為說294它就是一種純正身分犯。

01:01:49 - 01:01:53
所以沒有身分的人呢，要依照31條第一項類此身分哦。

01:01:55 - 01:01:57
好，那這邊我們來看一個考題。

01:01:57 - 01:01:59
這個是前幾年的普考考出來的。

01:02:00 - 01:02:00
配分，可是我們很難想像你完全不交代你的情況你要怎麼去起假。

01:02:05 - 01:02:07
因為這裡會有共犯總數的問題啊。

01:02:07 - 01:02:14
所以這個題目當中雖然對乙沒有配分，但是你還是要稍微講一下，乙的刑責你怎麼論，這樣甲的部分，你才寫得下去喔。

01:02:15 - 01:02:19
好，所以各位，這一題以當中，乙的刑責我們會怎麼論處啊。

01:02:21 - 01:02:22
乙的部分。

01:02:22 - 01:02:22
我們看一下。

01:02:24 - 01:02:28
那個乙生下小孩之後，他離開了醫院。

01:02:29 - 01:02:31
就等於把小孩留在嬰兒房嘛。

01:02:31 - 01:02:32
乙離開了醫院。

01:02:32 - 01:02:33
所以乙涉及到什麼呢?

01:02:33 - 01:02:34
294。

01:02:35 - 01:02:37
所以你的294你要寫什麼問題?

01:02:37 - 01:02:39
抽象危險犯說跟具體危險犯說。

01:02:40 - 01:02:42
知道嗎？乙的294你要去處理這個問題。

01:02:42 - 01:02:45
抽象危險犯說或具體危險犯說。

01:02:46 - 01:02:55
因為在這個題目當中，在這個題目當中，他把小孩留在醫院的嬰兒房，小孩不可能會有生命的危險。

01:02:55 - 01:02:59
所以一樣，採抽象危險犯說的話，乙罪會成立。

01:02:59 - 01:03:06
但如果採具體危險犯說的話，因為這個小孩並沒有任何的生命危險，所以乙罪不會成立。

01:03:07 - 01:03:08
OK嗎？

01:03:08 - 01:03:08
乙罪不會成立。

01:03:09 - 01:03:10
所以看你採哪一說。

01:03:10 - 01:03:11
那我會強烈建議各位，這一題要採抽象危險犯說。

01:03:14 - 01:03:16
那個抽象危險犯說。

01:03:17 - 01:03:21
雖然我不認同這一說，但這一題我們要採抽象危險犯說。

01:03:22 - 01:03:22
你知道為什麼吧？

01:03:23 - 01:03:27
因為這一題如果你採取具體危險犯說的話，

01:03:27 - 01:03:28
那共犯怎麼從屬？

01:03:29 - 01:03:29
對不對？

01:03:29 - 01:03:30
採具體危險。

01:03:30 - 01:03:33
犯說的話，那個以構成要件不該當，以構成要件不該當的話，

01:03:33 - 01:03:35
那甲你要寫什麼？

01:03:35 - 01:03:36
甲不就沒得論了，對不對？

01:03:37 - 01:03:41
所以這一題乙的部分，你要採取抽象危險犯說，這樣子的話呢。

01:03:41 - 01:03:43
甲的部分才有辦法論罪。

01:03:44 - 01:03:45
所以甲要怎麼論罪？

01:03:47 - 01:03:50
有些同學，還是什麼網路上的解答就這麼亂解。

01:03:50 - 01:03:53
說甲要成立遺棄罪的共同正犯。

01:03:53 - 01:03:55
理由是說因為兩個人一起離開醫院。

01:03:57 - 01:03:59
我都會看得會想問奇怪。

01:03:59 - 01:04:00
所以一起離開醫院就叫共犯。

01:04:00 - 01:04:01
共同正犯嗎？

01:04:01 - 01:04:02
甲是探病的人欸。

01:04:03 - 01:04:08
所以難道說，甲先離開，甲過10分鐘才離開，甲就沒有共同的，所以甲就不是共同正犯了。

01:04:09 - 01:04:11
不是吧，重點不在這邊，好不好？

01:04:12 - 01:04:14
甲是去探病的人，甲本來就會離開醫院啊。

01:04:14 - 01:04:19
那甲離開醫院的時候，甲有沒有跟乙一起，這件事在刑法上來說根本就不重要，好不好？

01:04:19 - 01:04:20
根本就不重要。

01:04:21 - 01:04:23
這一題當中，甲是怎麼樣？

01:04:23 - 01:04:27
我們要譴責的是甲乙不要去照顧他的嬰兒。

01:04:27 - 01:04:28
這才是我們要譴責的，知道嗎?

01:04:29 - 01:04:33
而不是甲跟乙一起離開醫院，那個一起離開根本就不是重點。

01:04:33 - 01:04:40
所以既然我們講，在法律上譴責的是甲教唆乙離開醫院，所以甲的角色就是一個教唆犯，那甲要論哪一條的教唆犯，那就是黑板上這個問題了，好嗎?就這個問題，遺棄罪的身分犯性質。

01:04:47 - 01:04:49
所以我覺得普考考這個東西算很難啦。

01:04:49 - 01:04:51
正常來說普考他不會考到這麼難。

01:04:51 - 01:04:53
但為什麼那個時候考這樣的東西？

01:04:53 - 01:04:54
這個我也不知道。

01:04:56 - 01:04:59
好，所以這個是這個問題。

01:04:59 - 01:05:00
這個進階問題。

01:05:00 - 01:05:03
接著下面，我們來看到行為的部分。

01:05:03 - 01:05:07
好，294的遺棄罪，他的行為呢？

01:05:09 - 01:05:10
做這樣的區分。

01:05:11 - 01:05:12
294的遺棄罪。

01:05:13 - 01:05:14
他的行為這邊，來第一個，叫做遺棄。

01:05:15 - 01:05:17
第一個叫做遺棄，再來第二個呢，叫做不為生存所必要的扶助、養育或保護。

01:05:17 - 01:05:24
它包含這兩個層面，遺棄，還有不為生存所必要的扶助、養育或保護，遺棄的部分應該比較不會有疑問。

01:05:24 - 01:05:27
那我們來看到第二個，不為生存所必要的扶助、養育或保護，這個不作為的部分。

01:05:33 - 01:05:35
我們翻到266頁喔。

01:05:35 - 01:05:36
這邊下面涉及到幾個問題。

01:05:36 - 01:05:39
第一個來，因為我們實務界經常把他們跟民法上的扶養義務畫在一起討論嘛。

01:05:39 - 01:05:44
所以這裡就會產生民法上的扶養義務，對於本罪成立範圍的影響。

01:05:44 - 01:05:45
第一個是這樣。

01:05:46 - 01:05:50
受扶養權利人，如果他不滿扶養義務人

01:06:00 - 01:06:01
所提供的扶養方式。

01:06:02 - 01:06:06
比如說有個爸有個老人啊，年紀大了。

01:06:06 - 01:06:12
他的兒子就說我們工作也很忙，也沒有空照顧你，不然我幫你送到附近還不錯的長照機構，怎麼樣啊？

01:06:13 - 01:06:19
結果這個老爸就覺得說兒子把自己送到長照機構是一個很不孝的行為，這個爸爸拒絕前往。

01:06:19 - 01:06:22
那兒子說不然怎麼辦嘛，我也不可能辭掉工作去照顧你啊。

01:06:22 - 01:06:24
所以雙方僵在那邊。

01:06:24 - 01:06:28
最後爸爸寧可在家裡當獨居老人，也不願意前往長照機構。

01:06:29 - 01:06:31
這樣的話行為人有算是遺棄罪嗎？

01:06:31 - 01:06:34
不是喔，行為人是願意提供扶養喔。

01:06:35 - 01:06:37
只是被害人他不願接受。

01:06:37 - 01:06:41
這樣的情況我們就不會說行為人是本罪的不作為。

01:06:41 - 01:06:41
這個是第一個。

01:06:42 - 01:06:42
好。

01:06:44 - 01:06:46
那再來第二個，括號二這邊。

01:06:47 - 01:06:48
扶養順位。

01:06:49 - 01:06:53
這個你們在民法親屬篇一定都學過扶養順位的問題。

01:06:54 - 01:06:57
那個扶養順位，他所涉及到的問題是這樣子。

01:06:59 - 01:07:02
比如說以你們阿公那輩來說好了。

01:07:02 - 01:07:04
如果你們阿公那輩還在的話。

01:07:04 - 01:07:07
當你的阿公還在的時候。

01:07:07 - 01:07:08
誰對他負有扶養義務？

01:07:08 - 01:07:10
假設你阿嬤也還在的話。

01:07:10 - 01:07:10
那就是阿嬤。

01:07:10 - 01:07:11
還有誰呢？

01:07:11 - 01:07:14
你爸爸、姑姑、叔叔、伯伯那一輩的。

01:07:14 - 01:07:15
會不會輪到你？

01:07:16 - 01:07:18
原則上不會嘛，因為你的順序在他們後面嘛，對不對？

01:07:19 - 01:07:22
除非你爸爸那一輩的長輩全部都不在了，那才會輪到你嘛，OK吧？

01:07:22 - 01:07:24
這個是民法上有扶養義務的順序。

01:07:24 - 01:07:25
好。

01:07:25 - 01:07:27
那可能產生的問題是這樣子喔。

01:07:29 - 01:07:30
那如果說。

01:07:30 - 01:07:31
如果說那個。

01:07:32 - 01:07:34
今天有個行為人。

01:07:34 - 01:07:36
他有扶養義務沒有錯。

01:07:37 - 01:07:39
但在民法上的順位還沒有輪到他。

01:07:39 - 01:07:42
可是呢，他又事實上去照顧那個無自救力之人，這個很常見啊。

01:07:44 - 01:07:47
比如說阿公是無自救力之人。

01:07:47 - 01:07:48
阿公無自救力。

01:07:49 - 01:07:51
但是爸爸那一輩的人工作都很忙。

01:07:51 - 01:07:52
沒有空照顧阿公。

01:07:53 - 01:07:56
所以這個阿公在寒暑假的時候呢,由孫子來照顧。

01:07:57 - 01:08:00
那你說孫子是不是一個依法有義務的人?

01:08:00 - 01:08:00
不是嘛,

01:08:00 - 01:08:01
對不對?

01:08:01 - 01:08:02
因為撫養義務還沒有輪到他。

01:08:02 - 01:08:04
那有一天孫子跟阿公吵了架，

01:08:04 - 01:08:06
孫子從此離家出走，

01:08:06 - 01:08:07
不再照顧阿公。

01:08:08 - 01:08:12
那這個孫子會不會成立294、295的犯罪？

01:08:14 - 01:08:16
抽象來說孫子有沒有扶養義務？

01:08:16 - 01:08:16
有對不對？

01:08:17 - 01:08:18
但輪到他了沒有？

01:08:18 - 01:08:18
還沒。

01:08:18 - 01:08:20
所以這裡他是本罪的行為主體嗎？

01:08:21 - 01:08:22
這裡的話，

01:08:22 - 01:08:23
實務認為說，

01:08:23 - 01:08:23
不算，

01:08:24 - 01:08:24
不算，

01:08:24 - 01:08:26
因為實務對這一條的扶養義務的判斷，

01:08:26 - 01:08:28
他是完全以民法作為依歸。

01:08:28 - 01:08:29
所以實務會說呢，

01:08:29 - 01:08:33
在民法上既然扶養義務還沒有發生的話，

01:08:33 - 01:08:35
那就算孫子事實上有照顧，

01:08:36 - 01:08:38
這裡也不算是本罪的行為主體，

01:08:38 - 01:08:39
這個也不算。

01:08:40 - 01:08:40
好，

01:08:40 - 01:08:41
接下來，

01:08:41 - 01:08:42
括號三。

01:08:42 - 01:08:45
括號三這個東西也是遺棄罪非常核心的考點，

01:08:45 - 01:08:49
它經常會跟前面的抽象危險犯說的爭執考在一起。

01:08:49 - 01:08:51
它其實有點像是一體兩面的問題啦。

01:08:53 - 01:08:53
我們剛說了，

01:08:54 - 01:08:56
實務見解對於遺棄罪的危險犯性質，

01:08:56 - 01:08:58
實務很明確採什麼說？

01:08:58 - 01:09:00
抽象危險犯說對不對？

01:09:00 - 01:09:00
好,

01:09:01 - 01:09:03
那麼在採取抽象危險犯說之下,

01:09:03 - 01:09:04
會有一個隱憂啦,

01:09:05 - 01:09:05
像我們剛剛說的,

01:09:06 - 01:09:10
它可能會導致遺棄罪淪為是一種違反扶養義務的犯罪。

01:09:11 - 01:09:13
那實務其實後來也有意識到這個問題,

01:09:13 - 01:09:14
就是說,

01:09:14 - 01:09:17
如果我們真的貫徹抽象危險犯說的話,

01:09:18 - 01:09:22
可能真的會讓這條罪淪為是一種扶養義務的違反。

01:09:22 - 01:09:23
所以我們該怎麼做呢?

01:09:24 - 01:09:24
你們想啊,

01:09:25 - 01:09:26
實務上很常發生這樣案例,

01:09:26 - 01:09:28
這個在臺灣社會非常的常見。

01:09:28 - 01:09:29
好,

01:09:29 - 01:09:29
比如說呢,

01:09:31 - 01:09:31
有個老頭，

01:09:31 - 01:09:33
他是無自救能力之人。

01:09:34 - 01:09:36
平常由他兩個兒子

01:09:36 - 01:09:38
由這兩兄弟輪流照顧。

01:09:38 - 01:09:40
那麼長照過了一段時間之後呢，

01:09:41 - 01:09:42
這兩兄弟啊,

01:09:42 - 01:09:43
吵架。

01:09:43 - 01:09:46
哥哥跟弟弟對這個照顧有一些意見,

01:09:46 - 01:09:48
所以哥哥跟弟弟呢大吵一架。

01:09:48 - 01:09:50
哥哥跟弟弟大吵一架之後啊,

01:09:51 - 01:09:53
哥哥從此離家,

01:09:53 - 01:09:54
跟弟弟說,

01:09:54 - 01:09:55
爸爸的事我再也不想管了,

01:09:55 - 01:09:56
以後就你照顧吧。

01:09:57 - 01:09:58
兩個人兄弟就決裂了。

01:09:58 - 01:09:59
哥哥從此離家。

01:10:00 - 01:10:02
我在照顧爸爸，只剩下弟弟一個人照顧。

01:10:03 - 01:10:07
所以你說這個時候，哥哥會不會成立遺棄罪？

01:10:08 - 01:10:09
各位你想喔。

01:10:09 - 01:10:12
假設你貫徹原本我們的抽象危險犯說的話。

01:10:14 - 01:10:15
哥哥會不會成立遺棄罪？

01:10:15 - 01:10:18
會有喔，因為他確實有撫養義務，他沒有履行嘛，對不對？

01:10:19 - 01:10:24
所以許澤天老師才說，如果你真的貫徹遺棄罪是抽象危險犯的話。

01:10:25 - 01:10:29
那真的很容讓這條罪淪為是一種違反撫養義務的犯罪。

01:10:29 - 01:10:34
所以到後來呢，學者也想，試圖也想要做些說明。

01:10:34 - 01:10:36
後來實務的限縮途徑是這樣。

01:10:36 - 01:10:39
他說，遺棄罪固然是抽象危險犯沒有錯。

01:10:39 - 01:10:42
但是遺棄罪的成立，

01:10:43 - 01:10:44
有一個前提喔。

01:10:45 - 01:10:49
下面這個87年的判例，87年的判例。

01:10:51 - 01:10:54
這個在267頁的上面引號當中。

01:10:56 - 01:10:58
這個引號我可能忘了標，反正它就是一個。

01:11:00 - 01:11:02
87年的判例。

01:11:02 - 01:11:03
你看到書體是在這邊。

01:11:03 - 01:11:11
這裡說因以該義務人不履行義務之際，業已由其他義務人為扶助或保護危難。

01:11:11 - 01:11:17
否則義務人一旦不履行義務，對於該義務人自然的人身有生命的危險，難解於該罪的罪責。

01:11:18 - 01:11:20
所以實務用的緩衝方法就是。

01:11:21 - 01:11:23
行為人不履行義務，沒有關係。

01:11:23 - 01:11:29
但如果這個時候啊，還有一個其他義務人在照顧無自救力之人的話。

01:11:30 - 01:11:32
那這個無自救力人生命沒有危險。

01:11:32 - 01:11:34
行為人就不成立本罪。

01:11:34 - 01:11:41
所以像我剛說的，兄弟在照顧爸爸，後來哥哥跟弟弟吵架之後，哥哥從此離家，不再照顧爸爸。

01:11:42 - 01:11:46
雖然照原本抽象危險犯說的推論，會讓行為人成立本罪沒有錯。

01:11:46 - 01:11:48
但依照實務緩衝的說法，不會，為什麼？

01:11:49 - 01:11:50
因為這個時候還是有弟弟在照顧。

01:11:51 - 01:11:52
弟弟是不是一個有義務的人呢？

01:11:53 - 01:11:53
是嘛，對不對？

01:11:54 - 01:11:57
所以照實務這個緩和的說法，哥哥不會成立遺棄罪。

01:11:59 - 01:11:59
實務會這樣。

01:12:00 - 01:12:01
我想我覺得也正常。

01:12:01 - 01:12:05
否則如果你真的要貫徹抽象危險犯說。

01:12:05 - 01:12:08
那不是一堆家屬就分裡面的人都會變成遺棄罪嗎？

01:12:08 - 01:12:10
比如說兄弟姊妹感情可能還不好。

01:12:11 - 01:12:13
原本約好這個爸爸要大家一起照顧。

01:12:13 - 01:12:17
但是最後到頭來呢，可能都是那個沒有結婚的女兒在照顧。

01:12:17 - 01:12:20
另外幾個兄弟就每年意思意思回來個兩三次而已。

01:12:20 - 01:12:21
非常有可能是對不對？

01:12:21 - 01:12:24
所以實務才會說，我們用這個方式緩和。

01:12:24 - 01:12:27
只要有在照顧的人呢，是一個有義務的人的話。

01:12:27 - 01:12:32
那其他沒有照顧的人，就不會去論遺棄罪。

01:12:32 - 01:12:34
好，所以我們來看到下面這一題。

01:12:54 - 01:12:57
好，下面這個題目，我們來看喔。

01:13:41 - 01:13:45
就以甲來說，乙涉及294，乙涉及294。

01:13:47 - 01:13:49
那這邊我們會有兩個問題要處理。

01:13:50 - 01:13:53
我們要先處理遺棄罪是抽象危險犯還是具體危險犯。

01:13:54 - 01:13:59
如果你說遺棄罪是抽象且具體危險犯的話。

01:14:00 - 01:14:00
照顧無自救力的人是誰？

01:14:00 - 01:14:01
是小孩的媽媽，依法有義務嗎？

01:14:05 - 01:14:06
所以那個爸爸會選哪個罪？

01:14:06 - 01:14:07
教務進學，不會，知道嗎？

01:14:07 - 01:14:09
教務進學也不會喔,所以這個題目我覺得設計的還不錯,就在考呢

01:14:12 - 01:14:16
抽象具體危險犯說,跟遺棄罪撫養義務的順位,我覺得這個出的還不錯

01:14:17 - 01:14:19
來,那我們來看一個類似的考題喔

01:14:21 - 01:14:23
拿出題目本,來看到68頁的第七題

01:14:42 - 01:14:43
這一題非常類似

01:14:44 - 01:14:48
兒子跟爸爸吵架之後，從此不再照顧爸爸

01:14:49 - 01:14:53
只有鄰居協助送醫，並且前來送餐探視

01:14:53 - 01:14:57
所以這時候，兒子會不會成立遺棄罪

01:14:57 - 01:15:02
一樣，如果採具體危險犯說的話，遺棄罪不會成立

01:15:02 - 01:15:06
那採抽象危險犯說搭配實務的線索，這裡會不會成立遺棄罪

01:15:07 - 01:15:08
欸

01:15:08 - 01:15:09
這裡會喔

01:15:10 - 01:15:11
這一題

01:15:11 - 01:15:11
跟剛剛

01:15:11 - 01:15:14
幾題那一題的差別關係在哪裡?

01:15:14 - 01:15:20
無自救力人雖然都有人照顧沒有錯,可是吉特那一題是,是誰照顧?

01:15:21 - 01:15:22
是有義務

01:15:22 - 01:15:23
的人照顧

01:15:23 - 01:15:23
可是

01:15:23 - 01:15:26
下面這個錦三這一題是誰照顧?

01:15:26 - 01:15:26
是一個

01:15:26 - 01:15:27
無關的人照顧

01:15:27 - 01:15:28
既然

01:15:28 - 01:15:32
是一個無關的人在照顧的話，代表他沒有義務

01:15:32 - 01:15:32
沒有

01:15:32 - 01:15:33
義務的人

01:15:33 - 01:15:35
那個照顧隨時可以停止，法律也不會譴責他

01:15:35 - 01:15:36
所以

01:15:36 - 01:15:38
那個被遺棄的人生命有沒有危險？

01:15:38 - 01:15:38
其實

01:15:38 - 01:15:39
還是有的喔，知道嗎？

01:15:39 - 01:15:40
所以下面這個錦三這一題

01:15:40 - 01:15:40
因為

01:15:40 - 01:15:44
在照顧的人並不是一個有義務的人，所以行為人呢

01:15:44 - 01:15:46
還是會成立遺棄罪，這樣瞭解喔

01:15:46 - 01:15:47
所以這個線索的方向

01:15:47 - 01:15:49
同學你要知道，這是實務上的說法

01:15:52 - 01:15:52
好

01:15:52 - 01:15:53
接下來

01:15:53 - 01:15:55
我們來看到後面幾個東西

01:15:57 - 01:15:59
接著後面267頁的第三點這邊

01:15:59 - 01:16:00
你

01:16:00 - 01:16:00
遺棄質性精神疾病，受親屬295，它是個加重的規定，我不多說。

01:16:05 - 01:16:08
接下來是遺棄質者的主張卻是由294之一。

01:16:09 - 01:16:14
這個294之1，它是在2010年的時候增訂的，15年前增訂的。

01:16:15 - 01:16:17
增訂這個條文有它的原因，為什麼呢？

01:16:18 - 01:16:23
因為啊，原本在民法上，扶養義務是絕對的。

01:16:24 - 01:16:26
有身分就有義務。

01:16:26 - 01:16:29
不管你的意願，不管怎麼樣，反正有身分，那個義務就會發生。

01:16:29 - 01:16:37
但後來立法者發現，扶養義務如果真的是絕對而沒有例外的話，有些時候會導致一些不公平的情況。

01:16:37 - 01:16:38
像同學一定有聽過這種案例。

01:16:39 - 01:16:43
可能有個做爸爸的人呢，年輕的時候不顧家，在外面吃喝嫖賭樣樣來。

01:16:43 - 01:16:50
最後啊，把家裡的錢敗得一乾二淨，討債公司還經常登門討債，而那個爸爸呢，一個人遠走高飛，去躲債了。

01:16:50 - 01:16:53
留下辛苦的媽媽，還有多名小孩。

01:16:53 - 01:16:56
後來20年後啊，小孩長大了，爸爸老了。

01:16:57 - 01:16:59
這時候啊，年輕不顧家的爸爸突然回家了。

01:17:00 - 01:17:01
突然來找小孩了。

01:17:01 - 01:17:03
所以我是你們的爸爸，你們要養我啊。

01:17:04 - 01:17:05
這時候，小孩會有什麼想法？

01:17:06 - 01:17:07
會覺得憑什麼？

01:17:08 - 01:17:09
你沒養，你也沒有養過我們呢。

01:17:10 - 01:17:11
為什麼我們要養你？

01:17:11 - 01:17:12
很容易有這種想法，對不對？

01:17:13 - 01:17:15
但是以前的民法並沒有這樣子排除的規定。

01:17:18 - 01:17:22
所以變成是這個時候小孩對爸爸還是負有扶養的義務。

01:17:22 - 01:17:24
那大家就覺得很奇怪，想說奇怪喔。

01:17:24 - 01:17:25
這不公平嘛，他也沒有養過我們，我們憑什麼要養他喔。

01:17:28 - 01:17:30
所以後來呢，在2010年的時候，民法上的扶養義務就做出了一些修正。

01:17:34 - 01:17:43
修正成說呢，如果今天受扶養權利人，他對扶養義務人，有一些比如說不法行為啊，或者是沒有履行扶養義務的這些行為在先的話。

01:17:43 - 01:17:48
這時候扶養義務可以申請法院減輕或免除。

01:17:48 - 01:17:50
好，於是我們來看到268頁這邊。

01:17:51 - 01:17:53
294之1條就是這樣應運而生的。

01:17:54 - 01:17:57
因為在民法上扶養義務可以減輕或免除。

01:17:58 - 01:18:00
那學者就進一步在想。

01:18:01 - 01:18:04
想說，那民法上都做了這個排除或卸責了。

01:18:04 - 01:18:07
那我們在刑法上是不是也要做對應的調整？

01:18:08 - 01:18:11
不然的話在民法上撫養義務都被減輕或免除了，

01:18:11 - 01:18:13
結果在刑法上你不養父母的行為還是成立犯罪，

01:18:14 - 01:18:15
這裡可能會有矛盾，

01:18:15 - 01:18:17
所以294之1呢，就是這樣子誕生的。

01:18:18 - 01:18:20
那這一條的各款是有我們不去細看,

01:18:20 - 01:18:21
因為那個都很簡單,

01:18:21 - 01:18:22
你們看條文就可以懂。

01:18:23 - 01:18:25
這裡幾個問題,第一個括號二這邊,

01:18:26 - 01:18:28
消極怠惰的遺棄罪才可以適用哦,

01:18:28 - 01:18:31
這個請同學注意喔，這個法條是有寫的。

01:18:31 - 01:18:36
也就是294之1，它只有阻卻掉這種不作為的遺棄罪。

01:18:37 - 01:18:39
作為則沒有被阻卻喔。

01:18:41 - 01:18:42
所以很簡單的這樣說，

01:18:43 - 01:18:46
如果有個女生，小時候被爸爸性侵害，

01:18:47 - 01:18:49
後來爸爸因此而去坐牢，關了十幾年出來。

01:18:50 - 01:18:53
爸爸出來之後女兒長大了，爸爸成為無自救能力的人。

01:18:54 - 01:18:55
這時候女兒可以怎麼做啊？

01:18:56 - 01:18:58
不養爸爸，OK，法律允許。

01:18:59 - 01:19:01
可不可以開車把那個爸爸載去山上丟掉？

01:19:02 - 01:19:06
不可以喔，它只有阻卻這種消極態樣的遺棄罪，這是第一個。

01:19:06 - 01:19:07
好。

01:19:08 - 01:19:10
再來它的不法性質是什麼？

01:19:12 - 01:19:17
很直覺的看法，會把這一條的不法性質理解成是一個阻卻罪責事由。

01:19:18 - 01:19:20
很有可能認為它是一個阻卻罪責事由。

01:19:20 - 01:19:26
那我跟你們說，這一條如果把它理解成是一個阻卻罪責事由的話，會變得莫名其妙。

01:19:27 - 01:19:30
因為你說它阻卻罪責代表這個不作為具有不法性喔。

01:19:31 - 01:19:36
也就是女兒被爸爸性侵，20年後爸爸出獄，成為無自救之人後，

01:19:37 - 01:19:39
女兒不養爸爸這個行為是不法的喔。

01:19:40 - 01:19:43
那是具有不法的話，這時候看不下去的大伯，

01:19:43 - 01:19:45
是不是可以出來主張正當防衛？

01:19:45 - 01:19:47
拿刀架著女兒，你給我養你爸爸。

01:19:48 - 01:19:51
這樣的話，這一條的不法意旨，是不是會大打折扣？

01:19:52 - 01:19:53
對啊，沒有錯啊。

01:19:53 - 01:19:56
所以學理上後來說，294之1的不法...

01:19:57 - 01:20:00
它的性質不是什麼阻卻違法。

01:20:00 - 01:20:01
也不是什麼阻卻罪責啦，都不是294之一的不法，它是一個情勢政策上面的不法事由

01:20:07 - 01:20:10
就跟不能謂事理上的阻卻刑罰事由很像，它就是一個情勢政策上面的不法事由

01:20:16 - 01:20:21
而且，這個不法事由會及於共犯，來為什麼呢，我就延續我剛剛那個例子

01:20:24 - 01:20:26
女生小時候被爸爸性侵害，後來爸爸去入獄服刑

01:20:28 - 01:20:33
關的時期20年，終於出獄了，爸爸出獄之後女兒也長大了，也成年了

01:20:34 - 01:20:37
這個女兒原本在爸爸出獄之後還是有養他

01:20:37 - 01:20:39
後來這個女兒交了男朋友

01:20:39 - 01:20:43
有一天這個女兒跟男朋友講說她小時候被爸爸性侵的事

01:20:43 - 01:20:49
那男朋友聽得很生氣，就想說，這個畜生小時候對你性侵害，他根本不配當你爸

01:20:49 - 01:20:51
現在你還養他，你是在怎樣啊

01:20:51 - 01:20:55
你是，對啊，就覺得這個女兒，這個女朋友太笨了吧

01:20:55 - 01:20:58
爸爸以前性侵你還去做牢，現在你還養他幹什麼啊

01:20:59 - 01:21:02
所以，女兒就想說，也是，越想越覺得怪

01:21:03 - 01:21:06
女兒想了三天，覺得男朋友說的有道理，於是她想說對

01:21:07 - 01:21:09
我不應該再養我爸爸了

01:21:09 - 01:21:12
於是呢，這個女兒，女兒啊，從此也就不再養她的爸爸

01:21:14 - 01:21:17
這時候的話，女兒會不會成立294、295

01:21:18 - 01:21:19
不會

01:21:19 - 01:21:21
為什麼，因為294之一阻卻了他的刑罰，對不對

01:21:22 - 01:21:24
那女兒294之一阻卻刑罰的話，這個男朋友

01:21:26 - 01:21:28
會不會成立294的教唆犯

01:21:30 - 01:21:33
你看哦，學者把294之一定位在哪，三親外面，對不對

01:21:34 - 01:21:36
那三親外面的話代表什麼意思

01:21:36 - 01:21:38
代表女兒不養他爸爸，該當違法且有責

01:21:40 - 01:21:42
只是三親等外阻卻刑罰，那女兒不法違法

01:21:43 - 01:21:45
女兒該當違法且有責哦，那形式上來看他男朋友

01:21:46 - 01:21:48
可不可以成立教唆犯，好像可以，對不對

01:21:50 - 01:21:53
可是學者就覺得說不啦，不能這樣判斷

01:21:53 - 01:21:57
因為294原本真的想罰的應該是那個女兒

01:21:58 - 01:22:00
結果法律上說那個女兒

01:22:00 - 01:22:02
294之一我們都不罰讓他無罪了,

01:22:02 - 01:22:04
那你罰那個局外人男朋友幹什麼?

01:22:05 - 01:22:05
懂我的意思吧?

01:22:06 - 01:22:08
真正有身分的人都已經不罰都無罪了,

01:22:08 - 01:22:09
你罰那個局外人沒有意義,

01:22:09 - 01:22:10
知道嗎?

01:22:10 - 01:22:15
所以學者會認為說294之一它是一個事理上的阻卻刑罰事由沒有錯,

01:22:15 - 01:22:16
但很特殊,

01:22:17 - 01:22:18
它會及於共犯

01:22:18 - 01:22:18
知道嗎？

01:22:19 - 01:22:21
它是一個及於共犯的阻卻刑罰事由，

01:22:21 - 01:22:22
這個很特別喔。

01:22:24 - 01:22:24
好，

01:22:25 - 01:22:26
這個是遺棄罪。

01:22:27 - 01:22:31
那遺棄罪這邊很多題目其實同質性都很高啦,

01:22:31 - 01:22:33
都在考那個抽象危險犯說跟具體危險犯說,

01:22:34 - 01:22:35
我就不再帶同學去看了。

01:22:38 - 01:22:38
接下來,

01:22:39 - 01:22:40
我們來看一下下面這個東西,

01:22:40 - 01:22:41
墮胎罪。

01:22:42 - 01:22:43
墮胎罪我簡單講，

01:22:44 - 01:22:46
因為我每年在講墮胎罪的時候啊，

01:22:46 - 01:22:47
都有同學會問說，

01:22:48 - 01:22:51
可是那個司律二試的命題大綱墮胎罪不在裡面啊。

01:22:51 - 01:22:51
真的要看嗎？

01:22:54 - 01:22:56
可是以前真的考過啦。

01:22:57 - 01:22:58
12年前，

01:22:58 - 01:22:59
2013年的時候，

01:22:59 - 01:23:00
就102年。

01:23:00 - 01:23:01
102年

01:23:01 - 01:23:03
102年那個時候真的有考到墮胎罪過

01:23:03 - 01:23:03
真的有。

01:23:04 - 01:23:06
那所以我覺得還是講一下啦，

01:23:06 - 01:23:07
因為它也不多啦

01:23:07 - 01:23:08
真的啦,

01:23:08 - 01:23:09
大概20分鐘可以講完的東西。

01:23:12 - 01:23:12
墮胎罪是這樣,

01:23:13 - 01:23:14
我講過它的現況。

01:23:15 - 01:23:16
就是像我上次,

01:23:16 - 01:23:17
不對，

01:23:17 - 01:23:18
就前幾天，

01:23:18 - 01:23:22
因為我們在臺北大學那邊有中國的交換生嘛。

01:23:22 - 01:23:23
交換生就問我說，

01:23:23 - 01:23:25
那你們臺灣有墮胎罪嗎？

01:23:25 - 01:23:26
我說有是有，

01:23:27 - 01:23:27
但是呢，

01:23:27 - 01:23:30
因為優生保健法對於24週之內的人工流產，

01:23:30 - 01:23:32
幾乎等於是無條件準許啦。

01:23:32 - 01:23:35
所以墮胎罪在臺灣是一個名存實亡的犯罪。

01:23:35 - 01:23:36
我就跟陸生這樣說,

01:23:36 - 01:23:37
所以他就說原來是這樣的狀況。

01:23:38 - 01:23:38
所以沒有錯,

01:23:39 - 01:23:42
墮胎罪雖然在現行法它依然是一個存在的犯罪,

01:23:42 - 01:23:47
可是一方面因為優生保健法上的人工流產是由它給得非常的寬。

01:23:48 - 01:23:50
24週之內幾乎是可以無條件人工流產，

01:23:51 - 01:23:51
這是第一點。

01:23:52 - 01:23:54
所以讓墮胎罪很難成立。

01:23:54 - 01:23:55
還有再來第二點，

01:23:56 - 01:23:59
有些人工流產行為它就算不符合優生保健法，

01:24:00 - 01:24:04
的，但墮胎真的很容易會形成犯罪黑數。

01:24:04 - 01:24:06
這個道理很容易理解，你們想喔，

01:24:06 - 01:24:09
殺人罪的犯罪黑數應該很少吧？

01:24:09 - 01:24:10
幾乎沒有，對不對？

01:24:11 - 01:24:11
殺人罪也，

01:24:12 - 01:24:14
世界上要少，世界上少了一個人，

01:24:16 - 01:24:17
你說大家會沒有發現嗎？

01:24:18 - 01:24:19
還是兇手都抓不出來嗎？

01:24:19 - 01:24:20
現在監視器那麼多，

01:24:20 - 01:24:21
不太可能，對不對？

01:24:21 - 01:24:26
所以殺人罪要形成犯罪黑數在這個年代，當然我們很難去想像。

01:24:26 - 01:24:29
可是墮胎罪很容易變成犯罪黑數，

01:24:29 - 01:24:32
因為世界上少了一個胎兒真的不會有什麼人知道。

01:24:32 - 01:24:33
知道吧？

01:24:33 - 01:24:40
所以墮胎罪，這個在實務上重要性真的是不高了，因為要麼觸法，要麼就是犯罪黑數。

01:24:40 - 01:24:41
好，那我們再來看一下，

01:24:41 - 01:24:43
墮胎罪保護什麼法益呢？

01:24:44 - 01:24:47
第一個這邊說，墮胎罪保護的就是胎兒的本身。

01:24:48 - 01:24:49
他就是保護胎兒，

01:24:49 - 01:24:52
墮胎罪要保護的並不是孕婦的身體健康。

01:24:53 - 01:24:55
知道嗎，所以第一個他保護的就是胎兒。

01:24:55 - 01:24:57
再來第二個

01:24:57 - 01:24:59
墮胎罪沒有罰過失，

01:24:59 - 01:25:02
墮胎罪也不處罰傷害胎兒。

01:25:02 - 01:25:05
第一個，為什麼墮胎罪不罰過失？

01:25:06 - 01:25:08
我們從孕婦這邊來講,

01:25:08 - 01:25:10
如果墮胎要罰過失,

01:25:11 - 01:25:12
那我想到以前看過一個案例。

01:25:13 - 01:25:15
有個律師去法院調解,

01:25:16 - 01:25:18
調解的對象是個孕婦。

01:25:19 - 01:25:22
調解到一半，孕婦表情痛苦，

01:25:22 - 01:25:24
地下出現一灘血，

01:25:25 - 01:25:26
孕婦就說糟糕，我好像流產了，

01:25:27 - 01:25:28
快步離開調解室，

01:25:29 - 01:25:31
留下傻眼的律師跟調解委員。

01:25:31 - 01:25:32
對，這是一個真實發生的事。

01:25:32 - 01:25:35
我很久以前在臉書上看到的，一個臉友說的。

01:25:35 - 01:25:40
那所以你想喔，如果自行墮胎有罰則的話，

01:25:41 - 01:25:43
那那個孕婦是不是變過失墮胎？

01:25:43 - 01:25:44
她有罪。

01:25:45 - 01:25:47
都懷孕了還去做調解，

01:25:47 - 01:25:50
調解可能會心情激動，可能會流產什麼的，你還去做，

01:25:50 - 01:25:50
所以你有過失。

01:25:51 - 01:25:53
哎，這樣的話誰敢懷孕啊？

01:25:53 - 01:25:54
對吧？

01:25:54 - 01:25:56
這樣的話，孕婦什麼事都不敢做欸。

01:25:56 - 01:26:00
連在浴室洗個澡，不行喔，萬一滑倒我流產的。

01:26:00 - 01:26:00
罰我。

01:26:01 - 01:26:03
像孕婦，對啊，這樣誰想懷孕，這樣你說孕婦可以幹什麼？

01:26:05 - 01:26:07
就過得跟神豬一般整天躺在床上。

01:26:08 - 01:26:09
幾乎沒有行動自由啦，對不對？

01:26:09 - 01:26:16
所以孕婦這邊的過失墮胎，我們刑法不過是有原因的，因為如果罰的話，恐怕會對孕婦的行動自由形成過度的影響。

01:26:16 - 01:26:17
再來第二個是這樣。

01:26:19 - 01:26:20
第二件事。

01:26:21 - 01:26:22
第二個考量是這樣，那第三人對孕婦的墮胎過失總沒有問題了吧？

01:26:26 - 01:26:28
對啊，你不小心開車撞到孕婦害她流產，這個過失墮胎刑法為什麼？

01:26:30 - 01:26:30
不罰的。

01:26:30 - 01:26:33
因為我們的考量是法益沒有那麼的重要。

01:26:33 - 01:26:36
過失犯只有在重要的法益才有罰，那我們一直強調，胎兒，胎兒他不是人。

01:26:40 - 01:26:42
在我們法律的評價之下，胎兒他就不是人。

01:26:43 - 01:26:47
所以他不是人的話，我們的刑法也不需要提供那麼多的保護。

01:26:47 - 01:26:51
所以就算是第三人導致的過失墮胎呢，我們的刑法也是不介入的。

01:26:52 - 01:26:52
好。

01:26:52 - 01:26:56
那麼接下來第二點，墮胎既遂的時點是什麼時候？

01:26:56 - 01:26:58
這個也是一個共通性的問題。

01:26:59 - 01:27:01
墮胎罪什麼時候既遂？

01:27:02 - 01:27:07
這裡，有一種說法認為，只要讓胎兒早產，就是墮胎的既遂。

01:27:07 - 01:27:09
這個我們在很前面總的課程有講過。

01:27:10 - 01:27:11
這是一個歷史上的說法。

01:27:11 - 01:27:15
只要故意讓胎兒早產，就是墮胎的既遂。

01:27:15 - 01:27:17
但是我們現在不採這一說了。

01:27:18 - 01:27:21
現在我們採的叫做胎兒死亡說。

01:27:22 - 01:27:24
現在認為說呢，光是早產還不夠。

01:27:24 - 01:27:26
因為早產不會怎麼樣。

01:27:26 - 01:27:28
要真的讓胎兒被殺掉，這個才叫做墮胎既遂。

01:27:31 - 01:27:33
所以現在的說法採的呢,都是胎兒死亡說。

01:27:34 - 01:27:34
好。

01:27:35 - 01:27:37
那剛剛有一點我漏講,括號二,墮胎除了不罰過失之外。

01:27:39 - 01:27:43
墮胎也不處罰傷害胎兒喔。

01:27:43 - 01:27:45
因為墮胎指的就是把胎兒殺掉。

01:27:46 - 01:27:48
如果是故意傷害胎兒的話,

01:27:49 - 01:27:50
我們刑法是不過問的喔。

01:27:51 - 01:27:52
所以比如說,

01:27:52 - 01:27:57
如果有一個孕婦，她超想生下畸形兒。

01:27:57 - 01:28:00
所以這個孕婦在懷胎期間，天靈蓋。

01:28:00 - 01:28:00
每天去照X光。

01:28:00 - 01:28:00
他在懷孕期間，每天都去那個機場的安檢門，那個X光這邊走來走去，他就很想生下一名畸形兒。

01:28:00 - 01:28:01
後來懷孕期滿之後啊，他真的生下畸形兒哦。

01:28:01 - 01:28:01
那個小孩，有六隻手，比如說這個手指頭有六隻。

01:28:01 - 01:28:02
然後雞雞有兩條，睪丸有四顆之類的，真的生下一個畸形兒。

01:28:02 - 01:28:02
我們刑法會罰他嗎?

01:28:02 - 01:28:02
不會，我們刑法並沒有處罰這個傷害胎兒的行為。

01:28:02 - 01:28:03
好，接下來我們來看到這隻豬。

01:28:03 - 01:28:03
這個專題研究。

01:28:03 - 01:28:03
同時存在原則呢，在墮胎罪的適用。

01:28:03 - 01:28:03
這個東西稍微難一點，稍微具有學理一點。

01:28:04 - 01:28:04
考出來機率很低啦。

01:28:04 - 01:28:04
不過既然我們還有時間，我們就帶各位來看一下。

01:28:04 - 01:28:04
這邊我們講。

01:28:04 - 01:28:05
同時存在原則是講什麼跟什麼要同時存在？

01:28:05 - 01:28:05
行為客體跟行為要同時存在。

01:28:05 - 01:28:05
我們是不是在講這個東西，知道嗎？

01:28:05 - 01:28:05
行為客體跟行為，這兩者要同時存在。

01:28:06 - 01:28:06
好，那既然我們講行為客體跟行為要同時存在的話，

01:28:06 - 01:28:06
那你要知道啊，從胎兒到人，它是一個連續的過程。

01:28:06 - 01:28:07
所以這裡可能會產生的問題是，行為人做行為的時候，肚子裡面他還是個胎兒。

01:28:07 - 01:28:08
只是後來呢，到這個胎兒變成之後，我們才發現那個損害的發生。

01:28:08 - 01:28:08
這時候我們要怎麼去評價呢？

01:28:08 - 01:28:08
好，第一個。

01:28:08 - 01:28:08
傷害胎兒的行為，而且那個胎兒也順利出生。

01:28:08 - 01:28:09
就像我說的嗎？

01:28:09 - 01:28:09
孕婦想生畸形兒，所以在懷孕期間一直去照X光。

01:28:09 - 01:28:09
後來這個孕婦果真生下了一名畸形兒。

01:28:09 - 01:28:09
所以這個孕婦怎麼論罪？

01:28:10 - 01:28:10
墮胎不可能，對不對？

01:28:10 - 01:28:10
他沒有殺掉胎兒。

01:28:10 - 01:28:10
那你可不可以論他傷害罪或重傷害罪？

01:28:10 - 01:28:10
當然不行啊，為什麼？

01:28:10 - 01:28:11
因為他在照X光的時候，肚子裡是一個胎兒。

01:28:11 - 01:28:11
傷害罪的對象是人嘛，胎兒不算嘛，是啊。

01:28:11 - 01:28:11
所以這種行為呢,當然沒辦法去論罪,因為他在做行為的時候呢,

01:30:00 - 01:30:02
肚子裡只是個胎兒而已,並不是一個人喔。

01:30:03 - 01:30:04
好,那我們翻過來。

01:30:06 - 01:30:07
括號二。

01:30:07 - 01:30:12
那如果胎兒出生之後,因為該傷害行為而死呢。

01:30:12 - 01:30:14
這個過去有發生過喔。

01:30:14 - 01:30:16
就是有個孕婦。

01:30:16 - 01:30:18
她在懷孕的期間，她吸毒。

01:30:21 - 01:30:22
好。

01:30:22 - 01:30:25
吸毒之後啊，這個小孩生產。

01:30:26 - 01:30:30
那小孩生產之後啊,不到24個小時。

01:30:31 - 01:30:36
這個小孩呢,就因為安非他命中毒的關係死掉了。

01:30:36 - 01:30:37
這個孕婦怎麼論罪？

01:30:38 - 01:30:40
當然第一個他論吸毒罪沒有問題。

01:30:40 - 01:30:45
那這個孕婦除了吸毒的犯罪之外,還會論什麼罪呢？

01:30:45 - 01:30:55
懷孕期間吸毒，後來生下一名足月的男嬰，這名男嬰出生之後不到24個小時，就因為甲基安非他命中毒的關係他死掉了。

01:30:55 - 01:30:58
好，孕婦除了這個吸毒罪之外，還要論什麼罪？

01:30:59 - 01:31:00
他可不能過失致死。

01:31:01 - 01:31:01
不行。

01:31:01 - 01:31:02
為什麼？

01:31:02 - 01:31:05
因為你說他過失致死的話，他的過失行為是哪一個？

01:31:06 - 01:31:06
是吸毒，對吧。

01:31:07 - 01:31:09
可是要過失致人於死。

01:31:10 - 01:31:12
他在行為的時候，有人死掉嗎？

01:31:13 - 01:31:13
沒有。

01:31:14 - 01:31:18
是他在行為後的好幾個月，胎兒變成人之後才死掉。

01:31:19 - 01:31:24
所以你會發現哦，你要用他的吸毒行為論過失致死，根本沒有辦法論。

01:31:25 - 01:31:26
知道吧，根本沒法論。

01:31:26 - 01:31:30
因為行為時，並沒有一個人存在。

01:31:30 - 01:31:31
知道嗎，根本沒一個人，根本就沒有一個人的存在。

01:31:33 - 01:31:36
那孕婦生產之後可以論過失致死嗎？

01:31:36 - 01:31:39
可是問題是她生產之後，她並沒有對胎兒做什麼過失的行為啊。

01:31:40 - 01:31:41
瞭解吧。

01:31:41 - 01:31:44
所以這件，不管你怎麼看，都沒辦法去論罪。

01:31:45 - 01:31:46
所以這種情況呢，也是無罪的。

01:31:47 - 01:31:48
接著來第二點。

01:31:49 - 01:31:52
墮胎未遂之後，使嬰兒死亡。

01:31:53 - 01:31:55
這是第一個，我們先來看到下面幾種子類型。

01:31:56 - 01:32:00
第一個是墮胎未遂之後，放

01:32:00 - 01:32:02
任嬰兒的死亡，括號一號。

01:32:02 - 01:32:07
你看喔，懷胎婦女在不符合優生保健法的情況之下，捶打肚皮要人工流產，

01:32:07 - 01:32:08
結果產下了女嬰沒有死，

01:32:08 - 01:32:12
奄奄一息，於是呢，甲放任這個女嬰死亡。

01:32:13 - 01:32:15
這個案例當中，我們要論什麼罪？

01:32:16 - 01:32:19
墮胎既遂。

01:32:19 - 01:32:21
好,我們要論墮胎既遂,為什麼?

01:32:22 - 01:32:24
因為他在做行為的時候,

01:32:24 - 01:32:26
肚子裡是什麼?胎兒,

01:32:26 - 01:32:28
對不對?肚子裡是胎兒。

01:32:28 - 01:32:31
後來胎兒成為嬰兒之後,固然死了,沒有錯,

01:32:32 - 01:32:34
但因為我們是以行為時來認定嘛,

01:32:34 - 01:32:35
行為時就是胎兒嘛,

01:32:36 - 01:32:38
胎兒最後成為嬰兒，然後死掉,

01:32:38 - 01:32:39
但最後就還是死了啊，對不對？

01:32:40 - 01:32:43
所以這個案例呢，我們論的可以是墮胎罪的既遂。

01:32:44 - 01:32:46
好，那這裡可不可以論生母殺嬰罪？

01:32:47 - 01:32:51
有些同學會想說，那這裡是不是可以論生母殺嬰罪的

01:32:52 - 01:32:54
呃，不作為犯，可不可以這樣論？

01:32:54 - 01:32:55
那我要跟各位說，

01:32:56 - 01:32:59
這個案例所預設的前提是，

01:33:40 - 01:33:43
因為這個胎兒是奄奄一息的,

01:33:44 - 01:33:45
就算有救助,也救不活。

01:33:46 - 01:33:48
這一種案情通常都是這樣,知道嗎?

01:33:48 - 01:33:52
就是那個胎兒成為嬰兒之後,雖然可能有呼吸,有心跳,

01:33:53 - 01:33:54
但是救不活了。

01:33:55 - 01:33:57
因為他前面已經受到傷害了，他就救不活了。

01:33:57 - 01:33:59
所以這個案例會不會有生母殺嬰罪的未遂？

01:33:59 - 01:34:00
不會，為什麼？

01:34:00 - 01:34:00
會不會成立

01:34:01 - 01:34:02
墮胎既遂

01:34:03 - 01:34:07
現在我們通常說對墮胎的既遂時點採納怎麼說

01:34:09 - 01:34:09
胎兒死亡說

01:34:09 - 01:34:10
對不對

01:34:10 - 01:34:13
哎，那這一題很特別哦，跟上面那一題不一樣哦

01:34:13 - 01:34:16
上面那一題是，一開始墮胎沒有成功

01:34:17 - 01:34:19
生下一名活產，活的嬰兒

01:34:20 - 01:34:23
結果這個嬰兒因為體弱多病，沒幾個小時就死掉了

01:34:24 - 01:34:27
那我們說上面那個選項可以直接論墮胎既遂，對不對

01:34:27 - 01:34:27
這個沒有疑問

01:34:27 - 01:34:28
好，那可能下面不一樣喔

01:34:29 - 01:34:34
下面這個案例是，他墮胎未遂，胎兒生出來是有生命跡象的

01:34:35 - 01:34:37
只是行為人積極把他殺掉

01:34:37 - 01:34:42
所以你知道嗎，下面這種案例等於說中間有一個行為人的行為介入

01:34:43 - 01:34:45
這個會變什麼，反常的因果歷程

01:34:45 - 01:34:46
瞭解吧

01:34:46 - 01:34:50
這就好像，你拿刀攻擊了被害人，

01:34:50 - 01:34:54
被害人被攻擊之後，他可能又被第三人砍，

01:34:54 - 01:34:57
加速了他的死亡流程。

01:34:57 - 01:35:00
這裡會有一個反常因果歷程的介入。

01:35:00 - 01:35:02
所以圈圈二這邊，你看喔。

01:35:04 - 01:35:06
雖然這個小孩到最後可能也是會死，沒有錯。

01:35:07 - 01:35:08
可是問題在哪裡？

01:35:10 - 01:35:15
問題在於在這個題目當中，有一個行為人的故意積極行為介入

01:35:15 - 01:35:20
學理上認為說這裡足以阻斷原本墮胎罪的因果關係

01:35:21 - 01:35:27
所以這裡的自行墮胎，他會變成是一個法律上所不罰的墮胎未遂

01:35:27 - 01:35:28
會變成這樣子喔

01:35:28 - 01:35:29
變成一個不罰的墮胎未遂

01:35:29 - 01:35:33
所以變成不法的墮胎未遂的話，墮胎罪就不成立了

01:35:33 - 01:35:35
所以這裡行為人只能論什麼罪，生母殺嬰罪

01:35:36 - 01:35:39
只能論那個生母殺嬰罪的故意既遂犯，只能這樣來論

01:35:42 - 01:35:44
好，所以這個是273頁這邊

01:35:45 - 01:35:48
這些案例可能同學聽的會覺得稍微複雜一點

01:35:48 - 01:35:50
就大概開過一些印象啦

01:35:50 - 01:35:51
因為墮胎罪在國考當中

01:35:51 - 01:35:51
呃

01:35:51 - 01:35:54
我不敢說一定不會考，但是考出來的機率相對低

01:35:54 - 01:35:57
因為這個在實務上確實比較不具有重要性

01:35:58 - 01:35:59
好，接下來

01:35:59 - 01:35:59
好

01:35:59 - 01:35:59
你

01:36:00 - 01:36:02
罪是每一個罪的啟示。

01:36:03 - 01:36:04
墮胎罪幾個條文。

01:36:05 - 01:36:07
我們請來看下面這個經濟的問題。

01:38:00 - 01:38:00
好，我來說的哈

01:38:01 - 01:38:06
墮胎罪在考試上的重要性相對低，但因為我們還有時間嘛，所以我們就稍微講一下它的一些爭議。

01:38:07 - 01:38:10
這個東西是許恆達老師多年前的文章所探討的問題哈。

01:38:11 - 01:38:14
那個墮胎罪，墮胎罪它的身分犯的性質。

01:38:18 - 01:38:20
哎，我這邊怎麼寫兩個死。

01:38:20 - 01:38:22
我不是疊字裝可愛，我這邊應該是要寫死亡啦。

01:38:24 - 01:38:25
我沒有疊字裝可愛哈。

01:38:25 - 01:38:26
我們看一下。

01:38:28 - 01:38:29
墮胎罪的身分犯性質。

01:38:31 - 01:38:35
這個問題，它可能會在288的脈絡之下被討論出來。

01:38:36 - 01:38:38
288條這個條文，他說

01:38:40 - 01:38:43
懷胎婦女，服藥或以他法，自行墮胎。

01:38:43 - 01:38:44
288這麼說。

01:38:45 - 01:38:45
來各位。

01:38:46 - 01:38:51
288那個懷胎婦女，他是純正身分犯，還是不純正身分犯？

01:38:53 - 01:38:55
這個問題，同學以前可能沒有想過。

01:38:56 - 01:39:02
對啊，288那個懷胎婦女，他是純正身分犯，還是他是不純正身分犯呢？

01:39:03 - 01:39:05
我換一個方式問，我換一個方式問各位哈。

01:39:06 - 01:39:09
各位同學你覺得我有沒有辦法墮胎？

01:39:09 - 01:39:11
我,我有辦法墮胎。

01:39:11 - 01:39:14
同學是不是覺得很怪,你男人墮什麼胎？

01:39:14 - 01:39:15
哎,不見得喔。

01:39:16 - 01:39:17
什麼叫墮胎？

01:39:18 - 01:39:19
殺掉胎兒叫墮胎,對不對？

01:39:20 - 01:39:21
所以我再講一次，我可以墮胎嗎？

01:39:22 - 01:39:22
可以啊。

01:39:23 - 01:39:25
我在路上看到一個孕婦，我過去踹她肚子讓她流產，我沒有在墮胎嗎？

01:39:26 - 01:39:27
有啊。

01:39:27 - 01:39:29
欸，誰說墮胎要孕婦自己墮胎才算墮胎？

01:39:30 - 01:39:32
別人幫孕婦流產是不是墮胎，是，對不對？

01:39:33 - 01:39:34
所以我再問一次，我可不可以墮胎？

01:39:34 - 01:39:35
可以啊。

01:39:35 - 01:39:38
誰說墮胎要自己，要殺掉自己的胎兒才算，同意是吧？

01:39:39 - 01:39:42
所以我們看，墮胎罪的體系長什麼樣子。

01:39:43 - 01:39:44
傳統

01:39:44 - 01:39:45
上是這樣分。

01:39:45 - 01:39:49
傳統上會說，孕婦自己墮胎是自成一條288。

01:39:50 - 01:39:52
那如果是別人為孕婦墮胎的話

01:39:52 - 01:39:55
這種有經過孕婦同意的289、290。

01:39:56 - 01:39:59
沒有經過孕婦同意的,這個叫291。

01:40:00 - 01:40:02
是墮胎罪原始條文的結構

01:40:02 - 01:40:07
所以在上面這一種結構之下,288的懷胎婦女的身份,它是一種什麼身份

01:40:08 - 01:40:09
純正身分犯

01:40:09 - 01:40:14
知道嗎,照上面的結構,懷胎婦女,他會是一個純正身分犯

01:40:14 - 01:40:17
而如果照下面這個結構的話就不是了

01:40:17 - 01:40:19
下面這一種結構

01:40:19 - 01:40:22
他會說,任何人都可墮胎

01:40:23 - 01:40:25
因為墮胎的定義我們 殺掉胎兒嘛

01:40:25 - 01:40:27
那誰不能殺掉胎兒,那每個人都可以對不對

01:40:28 - 01:40:29
任何人都可墮胎

01:40:30 - 01:40:38
所以在任何人都可墮胎的情況之下，其實懷孕婦女，她只是一個減輕的身份

01:40:38 - 01:40:42
所以其實墮胎罪的基本規定是289

01:40:42 - 01:40:42
是289

01:40:43 - 01:40:44
墮胎罪的基本規定是289

01:40:45 - 01:40:49
那麼接著290,291，他是加重

01:40:50 - 01:40:54
然後呢，288，他是減輕

01:40:55 - 01:41:00
因為孕婦會去墮胎，難免會有一些不得已的苦衷在，那個是期待可能性的降低

01:41:00 - 01:41:01
那個是減輕

01:41:01 - 01:41:02
這是另外一種體系

01:41:03 - 01:41:05
所以這裡真實的實意是，很簡單的案例

01:41:06 - 01:41:11
我找一個孕婦，已經懷胎七個多月，已經不能人工流產的孕婦

01:41:11 - 01:41:14
我叫他自己拿榔頭去錘肚皮墮胎，那我要論什麼罪的教唆犯

01:41:16 - 01:41:17
孕婦一定是288，這個沒有疑問

01:41:18 - 01:41:20
那我論什麼罪的教唆犯

01:41:20 - 01:41:23
你照上面那個傳統體系的話

01:41:23 - 01:41:24
我當然是288的教唆犯嘛

01:41:25 - 01:41:30
但如果照下面這個新進體系的話，我會變成是289的教唆犯

01:41:30 - 01:41:31
哎呀很特別，對不對

01:41:31 - 01:41:33
這是許恆達老師的想法

01:41:33 - 01:41:35
認為說呢,墮胎罪裡不能照那個字面去解釋

01:41:35 - 01:41:38
而要回歸他的實質不法內涵去做討論

01:41:38 - 01:41:39
好

01:41:39 - 01:41:40
那這邊幾個問題

01:41:41 - 01:41:43
288條他的行為態樣

01:41:43 - 01:41:45
第一個是服藥會以他法自行墮胎，這個沒有疑問

01:41:47 - 01:41:50
再來第二個是第二項，聽從他人墮胎

01:41:50 - 01:41:52
那個聽從墮胎什麼意思啊

01:41:52 - 01:41:54
這個我在總則可能有講過，我幫同學複習一下

01:41:56 - 01:41:56
來

01:41:57 - 01:41:59
有個孕婦已經懷胎七個多月了，快要生了。

01:42:00 - 01:42:00
而我跟那個孕婦說，你要生小孩喔，你沒有搞錯，你連自己都快養不活了，你要怎麼養小孩？不要生啊，你去墮胎啦。

01:42:08 - 01:42:09
我一直勸那個孕婦。

01:42:09 - 01:42:12
後來那個孕婦被我勸的時候，越想越有道理，於是呢，她拿榔頭槌自己的肚子，後來呢，成功流產了。

01:42:17 - 01:42:20
這時候，這個孕婦論什麼罪？

01:42:21 - 01:42:25
如果你說這個叫教唆墮胎罪，因為是我叫他墮胎他才去的。

01:42:26 - 01:42:28
如果你說這個叫教唆墮胎罪。

01:42:29 - 01:42:30
那很沒有意義。

01:42:30 - 01:42:30
為什麼？

01:42:31 - 01:42:35
因為孕婦是自己決定去墮胎的，還是接受別人建議去墮胎的。

01:42:36 - 01:42:37
這個在法律上不重要吧，對不對？

01:42:38 - 01:42:38
這是第一件事。

01:42:39 - 01:42:39
還有再來，如果聽從墮胎罪論述是第二項的話。

01:42:44 - 01:42:46
那你特別是訂這個條文幹什麼？

01:42:46 - 01:42:48
因為聽從墮胎不是也是一種自行墮胎嗎？

01:42:49 - 01:42:51
對不對，這樣的話第二項變得完全沒有意義。

01:42:52 - 01:42:54
所以，其實真正的說法是這樣子。

01:42:55 - 01:42:56
合理的說法是這樣。

01:42:57 - 01:43:01
288條的第二項的聽從墮胎罪，他那個聽從是一種不作為犯。

01:43:01 - 01:43:07
那個不作為是指說，有人要對懷胎婦女做自行墮胎的行為，而這個懷胎婦女呢，不為任何的阻止。

01:43:08 - 01:43:13
這才是所謂的聽從墮胎，知道嗎？有人要對懷孕的婦女墮胎，而懷孕婦女呢，不想保護她的胎兒，放任別人對她墮胎。

01:43:13 - 01:43:19
所以比如說我在路上看到一個孕婦，我過去踹她肚子，想讓她流產，結果那個孕婦竟然說呢，你要踹喔，她就給你踹，反正這個小孩喔，我可要可不要，無所謂，你要踹就踹。

01:43:20 - 01:43:23
這樣的話，這個孕婦論的才是288的第二項，知道嗎？

01:43:23 - 01:43:26
所以這個條文呢，它其實是一個不作為犯。

01:43:27 - 01:43:29
好，再來289、290、291。

01:43:31 - 01:43:33
這幾個條文應該比較沒有什麼特別要說的。

01:43:33 - 01:43:35
最後那個292，我稍微跟同學講一下。

01:43:36 - 01:43:39
292其實是一個很莫名其妙的條文，就我也不懂為什麼它可以活到現在。

01:43:41 - 01:43:43
292，我們來看一下喔。

01:43:43 - 01:43:44
我這邊有沒有發電，我看一下。

01:43:47 - 01:43:48
有有有，這個。

01:44:00 - 01:44:01
這個基本小六法，

01:44:01 - 01:44:03
現在已經一點都不小了。

01:44:14 - 01:44:17
那個292條他說以文字圖畫他法，

01:44:17 - 01:44:19
公然介紹墮胎的方法或物品。

01:44:19 - 01:44:22
或公然介紹自己或他人為墮胎的行為。

01:44:23 - 01:44:24
292。

01:44:25 - 01:44:27
這一條真的很莫名其妙，

01:44:27 - 01:44:29
但竟然就活活到了現在。

01:44:30 - 01:44:31
同學你們想一件事，

01:44:31 - 01:44:34
如果有人要公然介紹殺人的方法,

01:44:35 - 01:44:36
有沒有罰法？

01:44:37 - 01:44:37
沒有啊。

01:44:38 - 01:44:38
對啊,

01:44:38 - 01:44:40
就除非這個人在介紹殺人方法的時候,

01:44:40 - 01:44:42
後面還附帶一句話,

01:44:42 - 01:44:43
這些方法真的很有用,

01:44:43 - 01:44:45
你們可以去試試看喔。

01:44:45 - 01:44:46
這樣變刑法153嘛,

01:44:46 - 01:44:47
煽惑他人犯罪。

01:44:48 - 01:44:48
否則,

01:44:48 - 01:44:50
如果在介紹殺人方法的時候,

01:44:50 - 01:44:53
他只是純粹就科學的角度去講,

01:44:53 - 01:44:54
怎麼殺人比較容易死。

01:44:54 - 01:44:55
但後面有警語,

01:44:55 - 01:44:56
這只是科學的研究，

01:44:56 - 01:44:57
請你們不要以身試法。

01:44:58 - 01:44:58
那OK嘛。

01:44:58 - 01:44:59
言論自由嘛。

01:45:40 - 01:45:41
所以介紹殺人的方法。

01:45:41 - 01:45:42
OK，可以。

01:45:42 - 01:45:44
介紹墮胎的方法呢？

01:45:44 - 01:45:45
這是違法的，

01:45:45 - 01:45:46
那是犯罪。

01:45:47 - 01:45:47
是不是很奇怪？

01:45:48 - 01:45:49
介紹殺人方法OK,

01:45:50 - 01:45:51
介紹墮胎的方法不可以,

01:45:51 - 01:45:52
所以是怎樣,

01:45:52 - 01:45:53
墮胎比殺人還可惡嗎?

01:45:54 - 01:45:55
這很輕重失衡,

01:45:55 - 01:45:56
對不對？

01:45:56 - 01:45:58
這個條文如果你真的要去論的話，

01:45:59 - 01:46:00
像我老家附近有一家婦產科診所，

01:46:00 - 01:46:02
等一下我們再來看傷害罪。

01:46:15 - 01:46:19
好，我們繼續來看到的是傷害罪277條以下，傷害罪。

01:46:19 - 01:46:28
那個殺人罪我們都學過之後啊，傷害罪我想同學就比較不會有問題，因為傷害罪的規定跟殺人罪有高度的重疊，像比如說。

01:46:30 - 01:46:34
殺直系血親尊親屬的規定，傷害罪也有類似的加重。

01:46:34 - 01:46:37
義憤殺人的減輕，傷害罪也有。

01:46:37 - 01:46:40
那加工自殺的規定，傷害罪也有282。

01:46:41 - 01:46:44
所以傷害罪跟殺人罪呢，有一大半是重疊的。

01:46:44 - 01:46:51
所以我們等一下在講的時候，我們也只會專注於傷害罪他獨有的規定去做說明。

01:46:52 - 01:46:56
好，那這裡的話呢，首先第一個我們來看到的是普通傷害罪，普通傷害。

01:46:57 - 01:47:00
那普通傷害罪的話呢，第一點這邊說：

01:47:01 - 01:47:04
我們講行為客體的部分，行為客體。

01:47:05 - 01:47:07
傷害罪的行為客體，限於人。

01:47:08 - 01:47:10
不包括胎兒喔，這個我們剛剛講過了。

01:47:10 - 01:47:13
那再來什麼叫做傷害的結果。

01:47:13 - 01:47:14
這個是一個傳統的爭議啦。

01:47:15 - 01:47:20
身體完整性說跟生理機能障礙說，這裡有傳統兩種不同的說法。

01:47:20 - 01:47:26
身體完整性說跟生理機能障礙說，這兩種說法的意思是這樣子。

01:47:30 - 01:47:33
它們的區別是在於說。

01:47:33 - 01:47:38
如果今天一個傷害行為，他並沒有對生理機能形成不良的影響。

01:47:38 - 01:47:41
但是他破壞了對方身體的完整性。

01:47:41 - 01:47:42
比如說什麼呢？

01:47:43 - 01:47:44
剃光別人的頭髮。

01:47:45 - 01:47:46
各位，你想。

01:47:46 - 01:47:48
剃光別人的頭髮。

01:47:48 - 01:47:50
是不是破壞別人身體的完整性，是嗎？

01:47:50 - 01:47:51
因為頭髮也是身體的一部分。

01:47:52 - 01:47:55
可是剃光別人頭髮會造成別人生理機能的障礙嗎？

01:47:56 - 01:47:57
你想一想陸伯言。

01:47:58 - 01:48:00
陸伯言光頭，他的生理

01:48:00 - 01:48:00
有什麼差別，沒有啊，他超有活力，他超會講話的啊。

01:48:00 - 01:48:00
完全沒有差嘛，對不對？

01:48:00 - 01:48:00
沒頭髮搞不好更有活力，更有魅力。

01:48:00 - 01:48:00
對啊，所以

01:48:08 - 01:48:11
這個剃光別人的頭髮算是傷害罪的結果嗎？

01:48:12 - 01:48:13
身體完整性說算，因為頭髮是身體的部分，這個我們刑法也要保護。

01:48:16 - 01:48:18
那另外一說叫生理機能障礙說。

01:48:18 - 01:48:22
生理機能障礙說就會講說呢，頭髮剃光不會怎麼樣。

01:48:22 - 01:48:25
身體的完整性應該不是傷害罪所要保護的吧？

01:48:25 - 01:48:29
傷害罪要處罰的是真的造成被害人生理機能的妨害。

01:48:30 - 01:48:31
我們的刑法才要介入。

01:48:31 - 01:48:33
這是另外一說，叫做身體。

01:48:34 - 01:48:36
這個叫做生理機能障礙說。

01:48:37 - 01:48:39
那第三點是蔡聖偉老師的說法。

01:48:39 - 01:48:42
蔡老師認為說其實這兩說在我國根本就可以並存。

01:48:43 - 01:48:43
為什麼呢？

01:48:44 - 01:48:49
因為我們277條文講傷害什麼東西，傷害人的身體或健康。

01:48:49 - 01:48:50
對啊，身體或健康啊。

01:48:51 - 01:48:54
那既然條文已經把身體或健康並列的話,

01:48:54 - 01:48:59
那不就代表這兩個結果都是我們現行法所接受的。

01:49:00 - 01:49:02
身體的部分叫身體完整性說嘛。

01:49:02 - 01:49:04
健康的部分叫生理機能障礙說。

01:49:04 - 01:49:05
對啊，又沒有衝突。

01:49:05 - 01:49:06
所以沒有錯哈。

01:49:06 - 01:49:08
確實有學者認為說傷害罪的成立。

01:49:11 - 01:49:12
傷害罪的成立哈。

01:49:12 - 01:49:17
這個就算是身體完整性說，我們的現行法有採。

01:49:17 - 01:49:20
那當然這裡可能會面臨到的一個疑問是說，

01:49:21 - 01:49:22
身體完整性啊。

01:49:24 - 01:49:24
採這一說的話,

01:49:24 - 01:49:27
會不會造成傷害罪的處罰範圍過度的膨脹。

01:49:28 - 01:49:30
那對此蔡老師說也不會,為什麼呢?

01:49:31 - 01:49:31
你想哦。

01:49:32 - 01:49:33
假設是你上課的時候很無聊,

01:49:34 - 01:49:39
你看到你前面的女同學，她的頭髮好像有一根分叉的頭髮。

01:49:39 - 01:49:39
你看得覺得哎呀,

01:49:40 - 01:49:45
所以在沒有經過她的同意之下，你就偷偷剪了她一點點頭髮的分叉。

01:49:46 - 01:49:47
採這樣的案例,

01:49:47 - 01:49:51
採身,在這樣的案例當中,如果我們採身體完整性說,

01:49:51 - 01:49:52
行為人會不會算傷害?

01:49:53 - 01:49:55
當然不會啊,只剪掉一小段頭髮,那個哪會叫傷害,知道吧?

01:49:56 - 01:49:59
所以蔡老師說,就算我們的現行法可以採

01:50:00 - 01:50:01
身體完整性說,

01:50:01 - 01:50:06
可是要構成身體完整性的傷害而達到傷害罪的入罪門檻，

01:50:06 - 01:50:07
其實也不是那麼的容易啦，

01:50:07 - 01:50:10
並不會動不動就讓傷害罪成立，

01:50:10 - 01:50:12
應該不會有這樣的困擾。

01:50:13 - 01:50:16
好，所以這個是我們這邊講，傷害的認定。

01:50:16 - 01:50:19
那接下來我們來看到278頁下面這些問題,

01:50:19 - 01:50:22
使他人無症狀的感染傳染病,

01:50:23 - 01:50:25
算不算是傷害的結果呢?

01:50:25 - 01:50:28
這是蔡老師前幾年在疫情期間的一篇文章,

01:50:29 - 01:50:30
叫做得意忘形。

01:50:31 - 01:50:31
你看那個瘟疫的疫

01:50:32 - 01:50:34
蔡老師非常喜歡諧音梗，得意忘形。

01:50:34 - 01:50:36
那這一篇文章裡面所探討的就是說

01:50:36 - 01:50:39
因為之前有人得那個武漢肺炎，他根本沒有任何的症狀

01:50:39 - 01:50:41
那讓別人無症狀得到這個病

01:50:42 - 01:50:44
算得上是傷害別人的身體健康嗎？

01:50:44 - 01:50:46
多數說認為算，

01:50:46 - 01:50:47
因為多數說會覺得說，

01:50:48 - 01:50:50
對方有被病毒感染，

01:50:50 - 01:50:53
他的身體狀況就是得到了一個負面的影響。

01:50:54 - 01:50:56
雖然沒有產生具體不舒服的結果沒有錯,

01:50:56 - 01:50:59
但是呢,他的生理機能確實受到了妨礙,

01:50:59 - 01:51:01
所以依然算是有傷害的結果,

01:51:02 - 01:51:03
德國的多數說是採這樣的說法。

01:51:04 - 01:51:08
好,接下來,重傷罪的部分,278頁。

01:51:08 - 01:51:12
重傷的各款事由，我不再一個一個講了。

01:51:13 - 01:51:16
這一些事由的認定，我們前面都畫過圖了。

01:51:16 - 01:51:17
有印象吧？

01:51:17 - 01:51:18
我們畫了一隻佩佩豬啊。

01:51:19 - 01:51:20
還記得吧？我們課程前有畫過啊。

01:51:21 - 01:51:26
這個，函授的工讀生也被迫一起畫佩佩豬，

01:51:26 - 01:51:27
然後有同學拍給我看，

01:51:28 - 01:51:30
函授的那隻佩佩豬鼻子超長，

01:51:30 - 01:51:32
對，鼻子超長，那個工讀生畫的可能不太好啊，

01:51:32 - 01:51:33
鼻子畫超長。

01:51:34 - 01:51:35
然後下面還有同學回說,

01:51:35 - 01:51:36
因為我PO到IG上嘛,

01:51:37 - 01:51:37
還有同學回說,

01:51:38 - 01:51:39
那一定是說謊的佩佩豬,

01:51:39 - 01:51:40
鼻子才那麼長,

01:51:40 - 01:51:41
同學很有創意。

01:51:42 - 01:51:45
好，我們來看一下，這個重傷罪的認定。

01:51:46 - 01:51:48
這邊講毀敗，嚴重減損。

01:51:49 - 01:51:52
毀敗是說這個器官的機能完全喪失掉，

01:51:52 - 01:51:53
這個叫做毀敗。

01:51:53 - 01:51:55
再來叫做嚴重減損,

01:51:55 - 01:52:00
嚴重減損是說這個器官的機能已經喪失了一大半。

01:52:01 - 01:52:02
比如說以眼睛來講，

01:52:03 - 01:52:05
眼睛完全瞎掉，這個叫做毀敗。

01:52:06 - 01:52:12
那如果是戴上眼鏡，戴上眼鏡之後，視力都還只剩下0.1，

01:52:13 - 01:52:15
那個就叫做嚴重減損，

01:52:15 - 01:52:16
那個叫嚴重減損。

01:52:16 - 01:52:20
我講，戴上眼鏡之後視力都還只有0.1哦，

01:52:20 - 01:52:22
那個叫做嚴重減損。

01:52:22 - 01:52:26
如果是裸視0.1，但戴上眼鏡可以到1.0，

01:52:27 - 01:52:27
那個不算，

01:52:27 - 01:52:28
好嗎？那個不算喔。

01:52:30 - 01:52:33
這個，很多人都有近視啦，

01:52:33 - 01:52:38
對，很多人都有近視，近視到一定程度的話，你拿下眼鏡可能0.1都看不到。

01:52:38 - 01:52:39
這個是很正常的,

01:52:39 - 01:52:44
所以我說如果矯正之後可以到1.0的話，這個還沒有達到重傷的結果,

01:52:44 - 01:52:46
並沒有到那麼寬鬆的去認定。

01:52:48 - 01:52:50
之前一直有同學問我說是不是戴隱形眼鏡,

01:52:50 - 01:52:51
我說沒有，我真的沒有戴眼鏡。

01:52:52 - 01:52:53
真的啦，我真的沒有。

01:52:53 - 01:52:56
呃，我有一點點近視。

01:52:57 - 01:53:00
左眼好像一眼25度，一眼75度。

01:53:01 - 01:53:02
對，我有一點點近視。

01:53:02 - 01:53:03
嚴格來說算有。

01:53:03 - 01:53:04
那你說會不會戴眼鏡？

01:53:04 - 01:53:05
會，

01:53:05 - 01:53:05
我會戴。

01:53:05 - 01:53:06
我的眼鏡放在車上，

01:53:07 - 01:53:08
就我晚上開車才會戴。

01:53:09 - 01:53:10
因為我還有一點閃光,

01:53:10 - 01:53:13
晚上開車沒有帶眼鏡的話,我會覺得真的有點危險,

01:53:13 - 01:53:16
因為有點閃光了,這個會影響到行車的安全性,

01:53:16 - 01:53:18
所以我的眼鏡就放在車上,

01:53:18 - 01:53:19
只有晚上開車才會戴,

01:53:19 - 01:53:21
所以你們平常不會看到我戴眼鏡,

01:53:21 - 01:53:23
不是因為我戴隱形眼鏡,是真的平常沒有這個需要。

01:53:25 - 01:53:30
好,然後呢,我們講重傷也必須要是一個終局性的結果,這個才算喔,

01:53:31 - 01:53:35
所以如果只是造成別人一時的毀敗或嚴重減損,

01:53:36 - 01:53:36
這個就不算

01:53:36 - 01:53:40
比如說我們看過很多次的，把別人打成骨折，這個就不算是重傷。

01:53:41 - 01:53:43
那接著圈圈二這邊，

01:53:43 - 01:53:45
器官的功能有沒有嚴重減損，

01:53:45 - 01:53:51
我們說，要從一般人的角度判斷，而不能以被害人的特殊角度判斷，

01:53:52 - 01:53:53
這個沒有爭議。

01:53:54 - 01:53:58
比如說，你砍斷了一個馬拉松選手的腳筋，

01:53:59 - 01:54:00
那後來

01:54:00 - 01:54:00
這個人腳筋有機會

01:54:02 - 01:54:04
日常的行走跑跳沒有問題，比如說火車快要關門了，

01:54:06 - 01:54:09
跑個快速衝刺去趕這個火車，OK這個沒問題啊。

01:54:10 - 01:54:12
日常的行走跑跳都還可以

01:54:13 - 01:54:16
但是這個人呢,從此不能再跑馬拉松了

01:54:16 - 01:54:18
這樣的話有沒有算是重傷啊

01:54:19 - 01:54:19
不算喔

01:54:19 - 01:54:22
我們重傷最保護的是一般的機能

01:54:22 - 01:54:26
一般的技能，我們並不會考慮到被害人的特殊職業

01:54:28 - 01:54:30
好，那各款的試用

01:54:30 - 01:54:31
我們來看一下軍軍這邊

01:54:32 - 01:54:35
砍落別人的手指，算不算重傷

01:54:36 - 01:54:37
一般的說法

01:54:38 - 01:54:40
如果砍落別人的大拇指

01:54:40 - 01:54:41
算不算重傷

01:54:41 - 01:54:41
算

01:54:42 - 01:54:43
大拇指被砍落會怎麼樣

01:54:45 - 01:54:46
你不要跟我說從此不能比讚

01:54:47 - 01:54:48
這不是重點，好嗎？

01:54:48 - 01:54:51
大拇指被砍落除了從此不能比讚很痛苦之外

01:54:52 - 01:54:54
你大拇指沒了，你這個手有什麼功能？

01:54:55 - 01:54:56
你沒有大拇指，你的手怎麼抓握，對不對？

01:54:57 - 01:54:59
手最重要的功能是用大拇指啊。

01:54:59 - 01:55:00
有大拇指你才能抓握嘛

01:55:00 - 01:55:05
所以當你沒有大拇指的話，你除了不能比讚之外，你的手也不再能抓握了

01:55:05 - 01:55:07
所以這個確實可以算是重傷

01:55:07 - 01:55:10
那如果是其他指的話有算嗎

01:55:12 - 01:55:13
好，其他指的話

01:55:14 - 01:55:17
像你來看到之後的,你來看到這個

01:55:19 - 01:55:20
注33號

01:55:22 - 01:55:22
他這邊說

01:55:23 - 01:55:26
左手大拇指、食指、中指砍落

01:55:26 - 01:55:29
殘餘的無名指跟小指就失去了作用

01:55:30 - 01:55:31
所以這種情況確實有重傷

01:55:32 - 01:55:34
所以沒有錯,如果只剩最後兩隻的話

01:55:34 - 01:55:36
這個手幾乎沒有什麼作用了

01:55:36 - 01:55:37
所以這個算是重傷

01:55:37 - 01:55:42
那如果大拇指以外的其他手指頭可能有斷掉一根或斷掉一小節呢

01:55:43 - 01:55:47
我曾經處理過一個過失傷害案件

01:55:48 - 01:55:50
這案件是一名越南移工

01:55:50 - 01:55:55
他在工廠工作的時候，不專心工作，轉頭跟他的同事聊天

01:55:55 - 01:55:57
造成他的

01:55:57 - 01:55:59
我忘記是左手還右手

01:55:59 - 01:56:00
的食指

01:56:00 - 01:56:01
被機器整個碾斷。

01:56:02 - 01:56:03
我記得是這樣。

01:56:03 - 01:56:04
三年前的事情啦,

01:56:04 - 01:56:06
就移工,

01:56:06 - 01:56:08
越南移工在跟他的同鄉聊天，

01:56:08 - 01:56:09
沒有專心工作，

01:56:09 - 01:56:12
造成他的手指被機器碾斷，

01:56:12 - 01:56:13
好像是右手食指吧，

01:56:13 - 01:56:14
我印象中。

01:56:15 - 01:56:16
最後這件和解啦,

01:56:16 - 01:56:19
就當初檢察官辦這個僱主過失傷害,

01:56:19 - 01:56:22
因為這個僱主沒有對員工進行安全教育訓練,

01:56:22 - 01:56:23
所以去辦那個過失傷害,

01:56:23 - 01:56:25
後來這件好像花了好幾十萬去和解。

01:56:26 - 01:56:27
那你想,

01:56:27 - 01:56:32
越南移工他的食指,假設是左手的食指,一整根,被機器輾斷,

01:56:33 - 01:56:34
這樣有沒有算重傷?

01:56:35 - 01:56:40
一隻手少了食指,有沒有達到這一隻手的功能毀敗或嚴重減損的程度?

01:56:41 - 01:56:41
沒有。

01:56:41 - 01:56:42
嘿,

01:56:42 - 01:56:42
沒有。

01:56:42 - 01:56:43
對,

01:56:43 - 01:56:43
當然沒有。

01:56:44 - 01:56:45
他的手的功能可能會下降沒有錯,

01:56:46 - 01:56:49
但是沒有達到毀敗或嚴重減損的程度。

01:56:51 - 01:56:52
那你說可不可以改用最後一款？

01:56:53 - 01:56:55
其他身體或健康重大不治難治的傷害。

01:56:57 - 01:56:57
也還好。

01:56:58 - 01:56:59
就沒有到重大的程度啦。

01:56:59 - 01:56:59
知道嗎?

01:57:00 - 01:57:01
所以這一件只有普通傷害而已。

01:57:02 - 01:57:05
就少了一根手指，當然對當事人來說，可能會對自己的外表比較沒有自信，

01:57:06 - 01:57:07
日常生活可能會有一些些的不方便。

01:57:08 - 01:57:14
還有像這個越南人，如果他以後想學中文的話，學到這個伸手不見五指的成語，可能看自己的手指會覺得怪怪的。

01:57:14 - 01:57:16
學起來有點心虛,可能是這樣子,

01:57:17 - 01:57:20
但是呢,這個並沒有達到刑法上重傷的程度。

01:57:21 - 01:57:21
好。

01:57:23 - 01:57:24
所以這個不算。

01:57:24 - 01:57:27
那接著下面,砍落別人的耳廓,

01:57:28 - 01:57:29
可不可以算是重傷？

01:57:31 - 01:57:34
我們講，砍落別人的耳殼，

01:57:34 - 01:57:37
欸，不算是聽能的那一款重傷，

01:57:38 - 01:57:40
因為沒有耳殼對聽能的影響是相對有限，

01:57:40 - 01:57:43
但它可以認為是一種身體外觀的重大改變。

01:57:43 - 01:57:44
它幾乎算是一種毀容

01:57:45 - 01:57:48
所以呢,它可以用最後一款的重傷去處理。

01:57:48 - 01:57:50
你想，沒有耳殼是不是很奇怪？

01:57:51 - 01:57:54
兩年前流行的一部YouTube影片叫山道猴子

01:57:54 - 01:57:55
那個山道猴子就沒有耳朵啊。

01:57:56 - 01:57:57
真的就很醜啊,

01:57:57 - 01:57:57
對不對？

01:57:57 - 01:58:00
沒有耳殼很怪，而且沒有耳殼的話，

01:58:00 - 01:58:00
怎麼戴眼鏡、怎麼戴口罩。

01:58:00 - 01:58:00
那個對日常生活確實會形成一些影響。

01:58:06 - 01:58:10
我記得好幾年前，我看到臉書上轉發的一天一篇那個網路霸凌的文章。

01:58:10 - 01:58:17
就是有一個特殊生，他好像就是先天耳殼畸形還是怎麼樣，然後他在交友社團PO交友文。

01:58:18 - 01:58:20
那那個年紀的學生就喜歡去霸凌人家嘛。

01:58:20 - 01:58:25
我記得當他貼這篇交友文之後，當時剛好是疫情期間。

01:58:25 - 01:58:31
下面就有人去嗆那個PO文的人說，啊你耳朵這樣你要怎麼戴口罩，你是不是每天都觸犯校規。

01:58:31 - 01:58:33
就那個，對，就那個年紀的人就喜歡去霸凌人家，所以我覺得想說。

01:58:35 - 01:58:37
就人家沒惹到你，幹嘛去這樣嗆人家。

01:58:37 - 01:58:37
好。

01:58:37 - 01:58:41
所以這個是重傷的認定。

01:58:41 - 01:58:43
那第五款這邊。

01:58:43 - 01:58:46
第五款是生殖機能。

01:58:46 - 01:58:48
生殖機能的話呢。

01:58:49 - 01:58:54
這邊講說，這一款它保護的生殖能力，而沒有保護性能力。

01:58:54 - 01:58:56
所以生殖能力的話是歸這一款。

01:58:57 - 01:58:59
其實我一直很懷疑這件事情啊。

01:59:00 - 01:59:05
就是說，為什麼生殖機能可以跟其他的五官四肢並列？

01:59:06 - 01:59:07
對啊。

01:59:07 - 01:59:07
你有想過這件事嗎？

01:59:08 - 01:59:12
就為什麼生殖機能在法律上的重要性，可以跟其他的五官四肢並列？

01:59:13 - 01:59:13
你們想一件事喔。

01:59:15 - 01:59:17
如果有一天你經歷一場重大的車禍。

01:59:18 - 01:59:21
醒來之後，你發現你失明了。

01:59:22 - 01:59:23
從此看不到了。

01:59:23 - 01:59:24
你會不會覺得人生變黑白？

01:59:25 - 01:59:25
會，對不對？

01:59:26 - 01:59:29
那如果你醒來之後,你發現你少了一條胳臂,你少了一條腿,會不會覺得。

01:59:29 - 01:59:30
人生變黑白,應該也會,對吧?

01:59:31 - 01:59:37
那如果你醒來之後,醫生跟你說你四肢五官沒有大礙,但是你這輩子不能生了。

01:59:38 - 01:59:39
你覺得程度是一樣的嗎?

01:59:40 - 01:59:41
至少我覺得還好吧。

01:59:42 - 01:59:46
對啊,就是你少了眼睛,少了耳朵,少了四肢的任何一個部分。

01:59:46 - 01:59:47
那就是失能嘛。

01:59:47 - 01:59:50
你將來的日常生活會有嚴重的影響。

01:59:50 - 01:59:56
但如果是,比如說女生,因為一場車禍,而你喪失了子宮或卵巢,將來不能生了。

01:59:57 - 02:00:00
這個嚴重程度有跟其他的在比。

02:00:00 - 02:00:02
氣或五官的喪失一樣嚴重嗎?

02:00:02 - 02:00:07
至少我個人是覺得還好吧,就不能生,對啊,就還好啊,不會怎麼樣啊。

02:00:07 - 02:00:12
所以為什麼生殖機能可以跟其他各款並列,其實我也還蠻懷疑的。

02:00:13 - 02:00:15
因為它的嚴重程度不會到失能那麼的嚴重。

02:00:16 - 02:00:18
像我記得對保險公司來說。

02:00:19 - 02:00:22
我記得在對保險公司來說，喪失生殖器官。

02:00:23 - 02:00:26
保險公司就對保險公司來講，生殖器官超不重要。

02:00:26 - 02:00:31
因為你沒有那一根，或女生沒有子宮卵巢，一樣可以活得很好。

02:00:31 - 02:00:35
所以為什麼這個東西也會列為重傷，這個我覺得有點奇怪的。

02:00:36 - 02:00:41
最後，我們講第六款，身體或健康，重大不治難事的傷害。

02:00:41 - 02:00:43
對，生殖機能的話，我跟同學講一個嘗試。

02:00:44 - 02:00:48
男生的蛋蛋少一顆，算不算是第五款的重傷啊？

02:00:49 - 02:00:50
不算。

02:00:50 - 02:00:50
不算。

02:00:50 - 02:00:51
為什麼？

02:00:51 - 02:00:55
因為只有一顆蛋，還是可以生殖，還是有性能力。

02:00:55 - 02:00:58
真的啦，所以少一顆蛋不會怎麼樣。

02:00:58 - 02:01:00
少一顆蛋，不算是重傷。

02:01:00 - 02:01:02
兩顆都不見，當然是重傷。

02:01:02 - 02:01:08
但以前我遇過很奇怪的同學，竟然在考卷上面說兩顆蛋蛋都不見，也不影響生殖的機能。

02:01:09 - 02:01:13
所以我就很想問同學說，那所以你覺得你的蛋蛋是用來做什麼用的，是裝飾用的嗎？

02:01:14 - 02:01:16
就我看我這種莫名其妙的答案。

02:01:16 - 02:01:17
然後，好啦。

02:01:17 - 02:01:20
還有以前還有同學問我什麼問題。

02:01:20 - 02:01:24
說好，少一顆蛋，不算重傷，因為生殖機能沒有顯著的影響。

02:01:25 - 02:01:28
那可不可以改論第六款，就好像少了一個耳朵一樣。

02:01:28 - 02:01:29
認為是一種毀容，是。

02:01:30 - 02:01:31
身體外觀的重大改變。

02:01:32 - 02:01:33
不行啦。

02:01:33 - 02:01:33
為什麼？

02:01:34 - 02:01:37
你少一個耳朵，你走在路上每個人都可能會多看你一眼。

02:01:37 - 02:01:39
你可能會從此對自己的外表還沒有自信。

02:01:40 - 02:01:42
你少一顆蛋蛋會有一樣的狀況嗎？

02:01:42 - 02:01:44
每個人在路上多看你一眼，你怎麼少一顆？

02:01:45 - 02:01:49
如果你有這個擔憂的話，那你就是暴露狂嘛，你就是公然猥褻的慣犯。

02:01:49 - 02:01:50
一般人不會這樣吧。

02:01:51 - 02:01:56
那同學接著問，那如果那個人是個男性的性工作者，但對他來說超重要怎麼辦？

02:01:56 - 02:01:57
那就回到前面的問題，刑法的重傷罪。

02:01:58 - 02:02:00
不考慮被害人的特質。

02:02:00 - 02:02:00
主職業

02:02:00 - 02:02:01
好嗎？

02:02:01 - 02:02:02
順便提醒各位。

02:02:02 - 02:02:03
好，

02:02:04 - 02:02:05
然後第六款，

02:02:05 - 02:02:07
重大不治或難治的傷害。

02:02:08 - 02:02:09
那個第六款的話,

02:02:11 - 02:02:12
它這邊講,

02:02:12 - 02:02:13
重大不治或難治,

02:02:14 - 02:02:16
並不是單純的不治或難治喔,

02:02:16 - 02:02:17
要重大的程度才算。

02:02:18 - 02:02:19
所以像毀容那一種,

02:02:19 - 02:02:20
那個確實是第六款,

02:02:20 - 02:02:21
沒有疑問。

02:02:22 - 02:02:24
那除了毀容之外,

02:02:24 - 02:02:27
第六款它還處理到什麼樣的情況呢?

02:02:28 - 02:02:29
比如說,

02:02:29 - 02:02:33
造成他人身體大面積的燒燙傷那一種。

02:02:34 - 02:02:35
雖然不是臉部,

02:02:35 - 02:02:37
但造成別人大面積的燒燙傷。

02:02:37 - 02:02:38
是這樣,

02:02:38 - 02:02:40
大面積的燒燙傷，

02:02:40 - 02:02:42
你要看是身體的哪一個部位。

02:02:42 - 02:02:44
因為如果是臉部，

02:02:45 - 02:02:48
或者是這個我們一般肉眼明顯可見的部位的話，

02:02:48 - 02:02:50
確實有可能會認為是第六款。

02:02:51 - 02:02:53
但如果是比如說肚子、

02:02:54 - 02:02:54
屁股、

02:02:54 - 02:02:55
大腿這種地方的話,

02:02:56 - 02:02:58
那因為一般人本來就會穿衣服遮蔽,

02:02:58 - 02:02:59
所以那個程度會不一樣。

02:03:00 - 02:03:00
知道嗎？

02:03:00 - 02:03:01
那程度會不一樣。

02:03:01 - 02:03:02
好，

02:03:02 - 02:03:04
還有像比如說實務上有探討說，

02:03:05 - 02:03:06
腎臟的喪失，

02:03:06 - 02:03:07
算不算重傷？

02:03:08 - 02:03:10
這個講下去會變醫學的問題啦。

02:03:11 - 02:03:12
就是說是這樣，

02:03:12 - 02:03:13
讓別人少一顆腎，

02:03:13 - 02:03:14
算第六款嗎？

02:03:15 - 02:03:16
這個確實有一些爭議。

02:03:17 - 02:03:19
那醫學的觀點是這樣子，

02:03:19 - 02:03:20
因為我問過，

02:03:20 - 02:03:23
我記得我以前有學生剛好是腎臟科的醫師，

02:03:23 - 02:03:24
我有問過他這件事情，

02:03:24 - 02:03:25
他的說法是說，

02:03:25 - 02:03:26
少一顆腎，

02:03:26 - 02:03:28
短期來說是不會怎麼樣。

02:03:29 - 02:03:31
可是長期來說的話會，

02:03:31 - 02:03:32
因為你少一顆腎的話，

02:03:32 - 02:03:36
等於是你讓原本兩顆可以分擔的事變成一顆來做。

02:03:37 - 02:03:38
那原本有兩顆，

02:03:38 - 02:03:39
它可以休息喘息一下，

02:03:39 - 02:03:41
那現在變成是一顆做兩顆的事，

02:03:41 - 02:03:44
長期來說對健康當然會有負面的影響。

02:03:44 - 02:03:46
但這個影響從學理上的觀點，

02:03:46 - 02:03:48
應該還沒有到重傷的程度，

02:03:48 - 02:03:49
學理上認為不算，

02:03:49 - 02:03:51
但實務認為是算的喔，

02:03:51 - 02:03:52
這個還蠻特別的。

02:03:52 - 02:03:53
好啦,

02:03:53 - 02:03:54
所以我們大概就看到這邊。

02:03:55 - 02:03:56
接下來279,

02:03:56 - 02:03:56
280,

02:03:56 - 02:03:57
這個我不特別說。

02:03:58 - 02:03:58
281,

02:03:59 - 02:04:00
施暴行。

02:04:00 - 02:04:00
與尊親屬罪,這個我稍微講一下。

02:04:03 - 02:04:07
281條的施暴情與直系血親尊親屬罪。

02:04:07 - 02:04:12
他所要罰的其實是一個原本不罰的傷害未遂。

02:04:14 - 02:04:14
好，怎麼說呢？

02:04:15 - 02:04:17
你們是不是想一個情境？

02:04:17 - 02:04:20
我跟我爸吵架，越吵越生氣。

02:04:20 - 02:04:24
我爸很生氣地基於傷害故意把我推了一把在地上。

02:04:24 - 02:04:27
但是我撐住了，所以我毫髮無傷。

02:04:28 - 02:04:29
我爸會不會成立犯罪？

02:04:30 - 02:04:32
不會，對不對？為什麼？因為傷害不罰未遂嘛，OK喔。

02:04:32 - 02:04:34
好，那聽到我過來，同樣的情境。

02:04:34 - 02:04:38
我很生氣地推了我爸一把，我爸當場跌坐在地。

02:04:39 - 02:04:40
我爸也沒受傷，那我會不會成立犯罪？

02:04:41 - 02:04:43
喂，我成立281。

02:04:44 - 02:04:47
所以同樣的情境，我爸推我，我爸沒事。

02:04:47 - 02:04:49
但我推我爸也不行，我有事，我成立281。

02:04:50 - 02:04:53
有沒有感受到強烈的中華文化氣息存在？

02:04:54 - 02:04:56
對，就是這樣，就中華文化是這樣的法律。

02:04:56 - 02:04:59
這個德國應該沒有啦，我記得應該沒有。

02:05:00 - 02:05:01
好。

02:05:01 - 02:05:01
這個是281號。

02:05:02 - 02:05:04
再來是282，加工重傷。

02:05:05 - 02:05:06
這一條啊。

02:05:06 - 02:05:09
2019年修法之後，我只能說面目全非。

02:05:11 - 02:05:14
就是修法者根本沒有看懂這個條文在規定什麼。

02:05:15 - 02:05:17
然後就把這個條文修得亂七八糟的。

02:05:18 - 02:05:20
我先帶各位看一下原本舊的規定。

02:05:20 - 02:05:22
281頁這邊，281頁這邊。

02:05:22 - 02:05:23
最上面這裡，原本舊的282。

02:05:24 - 02:05:25
我們看清楚喔。

02:05:26 - 02:05:29
原本舊的282，來你看到它前段跟後段。

02:05:31 - 02:05:31
前段說：

02:05:32 - 02:05:38
教唆或幫助他人使之自傷，或受其囑託得其承諾的傷害，成重傷者。

02:05:38 - 02:05:40
來，原本282的前段是什麼？

02:05:41 - 02:05:42
加工重傷罪。

02:05:43 - 02:05:45
原本282的前段，就叫做加工重傷罪。

02:05:47 - 02:05:51
所以像比如說以前不是有個什麼武俠小說說什麼的。

02:05:51 - 02:05:56
說葵花寶典上面寫說如練，欲練神功，必先自宮嘛。

02:05:57 - 02:06:00
如果有人真的想自宮,但他不敢自己來。

02:06:00 - 02:06:03
委託他朋友做,那他朋友犯的就是282的前段。

02:06:03 - 02:06:04
好,接著後面,

02:06:06 - 02:06:06
因而致死,

02:06:07 - 02:06:09
那那個叫什麼?加重結果犯。

02:06:10 - 02:06:13
所以如果你幫你朋友動手術之後,他失血過多人死掉了,

02:06:14 - 02:06:16
這時候你會變282的後段,

02:06:16 - 02:06:17
加重結果犯。

02:06:17 - 02:06:18
所以原本很單純,

02:06:19 - 02:06:21
前段叫加工重傷罪,

02:06:22 - 02:06:25
後段叫做加工重傷致死罪,

02:06:25 - 02:06:27
後段它是一個加重結果犯,

02:06:27 - 02:06:28
原本就這麼單純的條文。

02:06:29 - 02:06:29
結果你知道嗎？

02:06:30 - 02:06:33
六年前多的修法者啊，根本沒有讀懂這個條文。

02:06:34 - 02:06:36
六年前的修法者一直存在一個誤會，

02:06:36 - 02:06:41
他以為282是加工輕傷的加重結果犯。

02:06:42 - 02:06:44
聽清楚，完全不同的意思喔。

02:06:44 - 02:06:47
原本282的前段叫加工重傷，

02:06:47 - 02:06:49
後段叫加重結果犯。

02:06:49 - 02:06:57
結果六年前多的修法者，他以為282是加工輕傷的致死致重傷的加重結果犯，

02:06:57 - 02:06:58
立法者這樣以為的。

02:06:59 - 02:07:01
所以就把這個條文呢，修成現在這個樣子。

02:07:02 - 02:07:04
所以現在這個條文呢，看起來變什麼？

02:07:05 - 02:07:06
加工輕傷致死，

02:07:06 - 02:07:08
加工輕傷致重傷，

02:07:08 - 02:07:10
看起來變成是一條加重結果犯。

02:07:11 - 02:07:13
而學者認為這個解釋當然不合理。

02:07:14 - 02:07:16
因為加工輕傷本身是阻卻違法的事。

02:07:17 - 02:07:18
加工輕傷本身無罪。

02:07:18 - 02:07:22
那我們立法上為什麼要特別去評價他的加重結果犯？

02:07:23 - 02:07:24
完全在學理上說不過去，知道嗎？

02:07:25 - 02:07:29
而且這樣一來，加工重傷反而被除罪化喔。

02:07:30 - 02:07:33
從修法理由來看，立法者沒有想把這個東西除罪化啊。

02:07:34 - 02:07:36
對啊，那如此一來加工重傷罪反而被除罪化了。

02:07:37 - 02:07:38
所以你說現行法之下怎麼辦？

02:07:39 - 02:07:40
於是你翻到這邊。

02:07:42 - 02:07:43
282頁。

02:07:44 - 02:07:46
現行法之下怎麼辦呢？

02:07:47 - 02:07:49
有第一種做法了。

02:07:50 - 02:07:52
就是讓加工重傷直接去論一般的重傷。

02:07:53 - 02:07:54
這是想像上的一種做法，

02:07:55 - 02:07:57
可是這一種做法可能不是那麼的妥當。

02:07:58 - 02:08:00
因為這個會輕重失衡。

02:08:00 - 02:08:02
加工自殺都可以減輕了。

02:08:03 - 02:08:06
啊為什麼加工重傷跟一般的犯罪輕重失衡,

02:08:06 - 02:08:06
對不對?

02:08:06 - 02:08:08
所以該怎麼做比較好啊,

02:08:08 - 02:08:09
圈圈二這個解套。

02:08:10 - 02:08:14
圈圈二說呢,就把現行法一二項後段的致重傷,

02:08:15 - 02:08:21
解釋成呢，兼指加工輕傷致重傷跟加工重傷這兩種不同的行為。

02:08:22 - 02:08:27
這樣的做法才不會莫名其妙的讓加工重傷罪被除罪化。

02:08:27 - 02:08:28
這個是學理上提供的解套。

02:08:29 - 02:08:30
但這個解套也只是一個權宜之計啦。

02:08:31 - 02:08:33
最根本的做法還是把這個法條修回來才對。

02:08:34 - 02:08:36
不然的話現在這個條文呢，根本變得莫名其妙。

02:08:37 - 02:08:37
這個是282。

02:08:54 - 02:08:56
好，再來是283，聚眾鬥毆。

02:08:57 - 02:08:58
聚眾鬥毆。

02:08:59 - 02:09:05
283這個條文聚眾鬥毆啊，它也是一個在2019年修法之後完全面目全非的犯罪。

02:09:05 - 02:09:07
我先講原本這個條文的價值在哪裡。

02:09:08 - 02:09:08
你們想喔,

02:09:09 - 02:09:11
一群人打群架,

02:09:12 - 02:09:14
結果有人死掉或重傷了,

02:09:15 - 02:09:17
那這一群人我們可以怎麼論罪?

02:09:17 - 02:09:21
一群人打架，後來有人不小心被打到死掉或重傷，

02:09:21 - 02:09:22
這群人怎麼論罪？

02:09:23 - 02:09:25
如果他們是共同正犯的話，

02:09:25 - 02:09:29
我們是不是可以論他們傷害致死或傷害致重傷的共同正犯，

02:09:29 - 02:09:29
對吧？

02:09:29 - 02:09:30
這應該沒有疑問。

02:09:31 - 02:09:35
那如果這一群人他們不是共同正犯呢？

02:09:36 - 02:09:37
一群人打群架喔,

02:09:38 - 02:09:41
後來有人死掉或重傷，但他們不是共同正犯，

02:09:41 - 02:09:42
這個可以想像啊。

02:09:42 - 02:09:47
比如說看球賽，兩邊的球迷都覺得裁判不公，

02:09:47 - 02:09:50
所以他們在觀眾席上就打了起來。

02:09:50 - 02:09:54
然後啊，一群混戰當中，最後有人死掉，或者說有人受重傷，

02:09:54 - 02:09:56
他們很明顯不是共同正犯。

02:09:57 - 02:09:59
那他們不是共同正犯的話，

02:09:59 - 02:10:00
從原本的條文...

02:10:00 - 02:10:00
我來講什麼？論？

02:10:01 - 02:10:06
你可不可以論大家個別，我們個別都去論傷害致死或傷害致重傷。

02:10:07 - 02:10:07
那一定不行，為什麼？

02:10:08 - 02:10:12
因為每個人會說，你又不能證明那個人是被我打死的。

02:10:12 - 02:10:12
對不對？

02:10:13 - 02:10:19
在這種群毆行為當中，最後有人死掉或重傷的話，因果關係其實很難證明。

02:10:20 - 02:10:26
所以立法者後來為了處理這個問題呢，立法者就在283制定了聚眾鬥毆罪。

02:10:26 - 02:10:29
立法者制定這個條文的意義，就是呢

02:10:30 - 02:10:38
要讓這種非共同正犯而參與群毆行為的人，有法可論，這是立法者當初的意志。

02:10:39 - 02:10:41
結果，後來修法怎麼修的？

02:10:43 - 02:10:46
後來修法，造成的，因為我們現在說

02:10:47 - 02:10:48
你現在看到283的規定。

02:10:48 - 02:10:50
我們來看到284頁。

02:10:53 - 02:10:56
原本283這個條文是說，聚眾鬥毆。

02:10:57 - 02:10:59
致人於死或重傷。

02:10:59 - 02:11:03
然後在場注視的人，他是一個刑度。

02:11:03 - 02:11:09
接著呢，下手實施傷害的人，依傷害各條的規定處斷。

02:11:10 - 02:11:12
原本這個條文的規定很正確。

02:11:13 - 02:11:14
原本就是說

02:11:14 - 02:11:17
在一場群毆行為，而且有人死掉或重傷的情況之下。

02:11:18 - 02:11:20
你在旁邊搖旗吶喊的人，

02:11:20 - 02:11:21
要論一個刑度。

02:11:21 - 02:11:25
然後下去打的人，依傷害各條規定處斷。

02:11:25 - 02:11:28
那個依傷害各條規定處斷是什麼意思？

02:11:29 - 02:11:30
意思就是說

02:11:30 - 02:11:34
你們下去打的人，論罪還是論283。

02:11:35 - 02:11:41
而科刑的話呢，我們用傷害致死或傷害致重傷的刑度來科。

02:11:41 - 02:11:44
所以原本舊法的條文說

02:11:45 - 02:11:49
人依傷害各條規定處斷，它的性質

02:11:49 - 02:11:52
一般都講說那個叫做法定刑的準用。

02:11:53 - 02:11:55
而不是構成要件的準用。

02:11:55 - 02:11:59
因為如果它是構成要件的準用的話。

02:11:59 - 02:12:00
那這裡

02:12:00 - 02:12:00
這個條文沒有意義。

02:12:01 - 02:12:05
因為如果你講構成要件的準用的話，那構成要件準用會傷害致死。

02:12:06 - 02:12:08
是不是又會卡到因果關係證明的困難，對不對？

02:12:09 - 02:12:13
所以過去都說呢，這個條文它是一個法律效果的準用規定。

02:12:13 - 02:12:13
好。

02:12:14 - 02:12:17
結果啊，2019年修法的時候，立法者沒有看懂。

02:12:18 - 02:12:19
地方立法者沒看到這個條文啊。

02:12:19 - 02:12:21
立法者就以為說

02:12:22 - 02:12:24
啊，準用不就構成要件準用嗎？

02:12:25 - 02:12:26
那構成要件準用就沒有意義啊。

02:12:27 - 02:12:28
我們不需要這個條文啊。

02:12:28 - 02:12:32
所以後來就把那個下手使傷害的那個部分呢，把它刪掉。

02:12:33 - 02:12:34
哎，這個刪掉問題很嚴重。

02:12:35 - 02:12:40
因為刪掉之後啊，立法者說沒關係吧，下去打的本來就可以論傷害致死啊。

02:12:40 - 02:12:45
可是問題就是這種群毆行為，如果他們又不是共同正犯的話，你要怎麼證明因果關係，對不對？

02:12:46 - 02:12:50
所以2019年修法之後，這個條文我只能說面目全非。

02:12:50 - 02:12:54
立法者自以為說稍微這樣修可以精簡條文的用語。

02:12:54 - 02:12:59
但是這樣修完之後啊，會讓這個條文產生很大的處罰漏洞。

02:12:59 - 02:13:01
真的哦，會產生很大的處罰漏洞。

02:13:02 - 02:13:02
所以

02:13:03 - 02:13:07
這個條文在現在來說的話，確實會有這樣的問題存在。

02:13:08 - 02:13:09
你們就想嘛。

02:13:10 - 02:13:12
球賽當中兩群觀眾打成一團。

02:13:13 - 02:13:16
打成一團之後，有人被踩死，有人被打死。

02:13:17 - 02:13:18
他們又不是共同正犯。

02:13:19 - 02:13:20
那我們怎麼論這兩群人？

02:13:22 - 02:13:23
有人要為死亡結果負責嗎？

02:13:24 - 02:13:26
如果283的後端被刪掉了。

02:13:26 - 02:13:27
哎，沒有哎，對不對？

02:13:27 - 02:13:28
沒有哎。

02:13:28 - 02:13:30
所以現行法之下

02:13:30 - 02:13:34
的話，這樣修，確實會產生還蠻嚴重的問題喔。

02:13:35 - 02:13:35
好。

02:13:35 - 02:13:37
所以這個條文在現在幾乎沒有什麼適用的空間啊。

02:13:38 - 02:13:40
那其他的要件我們來看一下喔。

02:13:42 - 02:13:44
像這條字的前提，第一個我們講聚眾鬥毆。

02:13:45 - 02:13:46
這個

02:13:46 - 02:13:48
你要跟150做個對照。

02:13:49 - 02:13:51
因為149、150

02:13:51 - 02:13:53
他們原本也都是寫聚眾。

02:13:54 - 02:13:54
原本也是。

02:13:55 - 02:13:59
可是149跟150在2019年年底修法的時候

02:14:00 - 02:14:02
立法者都把聚眾改成，

02:14:02 - 02:14:06
在公共場所或公眾得出入的場所聚集三人以上。

02:14:07 - 02:14:09
19年的時候立法者都有這樣修。

02:14:10 - 02:14:13
可是聚眾鬥毆這個283有沒有這樣修？

02:14:13 - 02:14:13
沒有。

02:14:14 - 02:14:16
283還是寫聚眾。

02:14:16 - 02:14:18
那以往的實務都說什麼叫聚眾?

02:14:19 - 02:14:21
人數要隨時可增加。

02:14:22 - 02:14:24
很嚴格哦，要隨時可增加。

02:14:24 - 02:14:30
所以既然283的聚眾沒有隨著像149、150那樣修的話,

02:14:30 - 02:14:34
所以283的聚眾從實務進起來講，要不要人數隨時可增加？

02:14:34 - 02:14:35
要喔。

02:14:35 - 02:14:36
要喔。

02:14:38 - 02:14:38
好。

02:14:39 - 02:14:41
然後，行為態樣是在場助勢。

02:14:41 - 02:14:47
接著這一條罪有一個客觀處罰條件是致人於死或重傷。

02:14:47 - 02:14:49
要打到有人死掉或重傷才算喔。

02:14:50 - 02:14:53
一般的輕傷不算，要死掉或重傷。

02:14:54 - 02:14:56
我加深一下同學的印象。

02:14:58 - 02:15:19
這個條文很冷門啦，

02:15:19 - 02:15:40
考試幾乎很少出現。

02:15:40 - 02:15:43
尤其在2019年修法之後，它幾乎是變成一個無用武之地的條文。

02:15:44 - 02:15:45
所以現在來講考試更少出現。

02:15:45 - 02:15:47
但我還是提醒同學這個法條的規定。

02:15:48 - 02:15:49
我記得我大學要畢業的那一年。

02:15:50 - 02:15:53
寒假的前夕，對，跨年的那一天。

02:15:54 - 02:15:57
那一天啊，原本早上我們有修一門錢建榮法官的課。

02:15:57 - 02:15:59
但當初，但那天早上呢，

02:15:59 - 02:16:00
老師臨時停課。

02:16:00 - 02:16:01
考刑法組嘛。

02:16:01 - 02:16:03
那當然聊天的話題呢都跟刑法有關。

02:16:03 - 02:16:05
這個同學就突然講了一句話，

02:16:05 - 02:16:05
他說，

02:16:05 - 02:16:06
我最近看新聞，

02:16:06 - 02:16:08
發現新聞都在亂報。

02:16:08 - 02:16:09
國中生打群架,

02:16:09 - 02:16:13
新聞說警方以傷害罪移送他們。

02:16:14 - 02:16:15
我這個同學說不對吧,

02:16:16 - 02:16:17
國中生打群架,

02:16:17 - 02:16:19
打群架不就是聚眾鬥毆嗎?

02:16:20 - 02:16:22
他應該警方應該是要用聚眾鬥毆移送才對啊,

02:16:22 - 02:16:24
怎麼會用傷害罪呢？

02:16:24 - 02:16:24
我說沒有啊,

02:16:24 - 02:16:25
新聞沒有報錯啊。

02:16:26 - 02:16:29
聚眾鬥毆要打到死掉或重傷才算。

02:16:30 - 02:16:31
國中生打架沒那麼兇殘吧？

02:16:31 - 02:16:33
把人家打到死掉或重傷，

02:16:33 - 02:16:33
沒有吧。

02:16:33 - 02:16:35
所以警方用傷害罪移送沒有錯啊，

02:16:35 - 02:16:36
因為他們沒有死亡或重傷啊。

02:16:36 - 02:16:37
那當時我同學說,

02:16:37 - 02:16:38
蛤真的嗎?

02:16:38 - 02:16:39
要死亡或重傷？

02:16:39 - 02:16:40
我說真的啦,

02:16:40 - 02:16:41
不信你去翻法典。

02:16:41 - 02:16:42
當時同學剛好拿了一本六法

02:16:43 - 02:16:44
他翻到283

02:16:44 - 02:16:44
真的耶

02:16:45 - 02:16:45
要死亡或重傷。

02:16:45 - 02:16:46
好

02:16:46 - 02:16:47
他發現他講錯了，

02:16:47 - 02:16:48
就跳到下一個話題了。

02:16:48 - 02:16:50
當時我在旁邊，

02:16:50 - 02:16:51
我聽到同學這樣講，

02:16:51 - 02:16:53
我心中有一種非常安心的感覺。

02:16:54 - 02:16:54
真的啦,

02:16:54 - 02:16:56
因為他也想考刑法組,

02:16:56 - 02:16:57
然後我就發現,

02:16:57 - 02:16:58
都快要考試了,

02:16:58 - 02:16:59
他對法條還不熟欸。

02:17:40 - 02:17:41
我當下覺得很安心,

02:17:41 - 02:17:41
嘿嘿,

02:17:41 - 02:17:42
我少了一個對手,

02:17:42 - 02:17:42
這種感覺。

02:17:43 - 02:17:43
所以各位,

02:17:43 - 02:17:44
法條要熟喔,

02:17:44 - 02:17:45
知道嗎？

02:17:45 - 02:17:47
法條不熟的話,

02:17:47 - 02:17:47
你跟人家講法條,

02:17:47 - 02:17:48
別人發現你講錯,

02:17:48 - 02:17:49
別人就會覺得安心了,

02:17:49 - 02:17:50
少了一個對手,

02:17:50 - 02:17:51
不要給人有這種感覺喔。

02:17:53 - 02:17:53
好,

02:17:53 - 02:17:55
所以這個是我們這邊講到,

02:17:55 - 02:17:56
它的構成要件條件,

02:17:56 - 02:17:58
致死或重傷。

02:17:58 - 02:17:59
總之啦,

02:17:59 - 02:18:00
法定刑準用的部分

02:18:01 - 02:18:03
這個條文在近年來的創見還蠻高的。

02:18:04 - 02:18:05
我是覺得啦，

02:18:05 - 02:18:07
也不是說現在的人比較愛虐童啦。

02:18:08 - 02:18:10
應該是現在的社會比較重視這樣的議題啦，

02:18:10 - 02:18:11
我覺得是這樣子。

02:18:12 - 02:18:13
虐童在以前也許更多。

02:18:14 - 02:18:18
只是在以前三四十年前的社會，當時覺得父母管教小孩那是家務事。

02:18:19 - 02:18:20
我覺得是這樣啦，

02:18:20 - 02:18:24
就是很多時候，社會開始重視某些案件，

02:18:24 - 02:18:27
不代表說這個案件現代社會才有，

02:18:27 - 02:18:29
他可能只是現在才被受到重視。

02:18:29 - 02:18:30
我認為是這樣子。

02:18:30 - 02:18:38
那虐童的話呢，現在的條文很明顯，它採取的是一個繼續犯的立法模式。

02:18:39 - 02:18:42
這個286啊，最早以前，它是結果犯。

02:18:43 - 02:18:47
後來在2012年修法，它變成繼續犯。

02:18:47 - 02:18:48
變成是行為犯。

02:18:48 - 02:18:48
為什麼呢?

02:18:49 - 02:18:54
因為虐童這一條罪，如果你說他是結果犯的話，這一條超難成立。

02:18:54 - 02:18:59
你要怎麼證明虐童的行為跟那個兒童後來身心發展的創傷之間有因果關係?

02:19:00 - 02:19:02
比如說我們講身體的部分。

02:19:04 - 02:19:06
媽媽為了希望女兒的胸部發育的很大,

02:19:07 - 02:19:12
所以這個媽媽在女兒還在讀國小三年級的時候，就帶女兒去打荷爾蒙。

02:19:13 - 02:19:17
後來這個女兒呢，果然小三的時候啊，月經就來了，胸部就開始發育了。

02:19:18 - 02:19:19
所以你說媽媽犯286嗎？

02:19:20 - 02:19:25
如果你說286，如果以前啊，286是結果犯的年代，你怎麼論這個媽媽犯？

02:19:26 - 02:19:27
媽媽搞不好會說，

02:19:27 - 02:19:28
你去看我的就醫紀錄

02:19:29 - 02:19:30
我自己也是啊

02:19:30 - 02:19:32
我也發育得早啊，我也是小三的時候月經就來了。

02:19:33 - 02:19:33
你要怎麼說，對不對？

02:19:34 - 02:19:35
很難證明因果關係嘛。

02:19:35 - 02:19:38
或者是類似的問題。

02:19:39 - 02:19:41
媽媽希望女兒的腳小一點。

02:19:41 - 02:19:47
所以女兒在青春期的時候，每次說腳長大了，要媽媽買新的鞋子，媽媽都不給她買。

02:19:47 - 02:19:51
後來這個女兒最後身高170，但腳只有22公分。

02:19:52 - 02:19:54
所以你說媽媽犯286嗎？

02:19:54 - 02:19:56
在以前結果犯的年代,

02:19:56 - 02:19:59
媽媽會說，你看我也是身高170，腳22公分啊。

02:20:00 - 02:20:01
我小時候我們家族遺傳啊，跟我不給他買鞋有什麼關係？

02:20:03 - 02:20:04
很難證明，對不對？

02:20:04 - 02:20:10
所以後來2002年修法的時候，立法者把這個條文的模式改成一種叫做適性犯的模式。

02:20:11 - 02:20:12
你看現行法喔。

02:20:12 - 02:20:13
現行法只要怎麼樣？

02:20:14 - 02:20:15
足以，足以哈。

02:20:16 - 02:20:19
也就是這樣的行為，有可能

02:20:20 - 02:20:23
會讓幼童的身心發育，遭受到妨害。

02:20:23 - 02:20:24
這樣就夠了，知道嗎？

02:20:24 - 02:20:28
現行法採的是足以這樣的看法，有可能。

02:20:29 - 02:20:30
這個就夠了。

02:20:31 - 02:20:34
好，那我們來看，這一條罪的行為主體沒有限制。

02:20:35 - 02:20:36
任何人都成立。

02:20:37 - 02:20:41
雖然通常會犯286條的，往往是幼童的父母或他的照顧者。

02:20:41 - 02:20:45
但法律上沒有這個限制，任何人都可以成立。

02:20:45 - 02:20:52
然後他的行為啊，這邊說，凌虐或以他法足以妨害他的身心健全發育。

02:20:53 - 02:20:55
任何方法都算。

02:20:55 - 02:21:00
足以，一切足以妨害身心健全發育的方法呢。

02:21:01 - 02:21:02
通通都算。

02:21:04 - 02:21:06
而且他不見得是身體上喔。

02:21:06 - 02:21:08
心理層面的也算喔。

02:21:08 - 02:21:11
所以比如說以前很久十幾年前律師考試有考過。

02:21:12 - 02:21:15
這個有個小孩父母雙亡，有叔叔照顧。

02:21:15 - 02:21:18
叔叔為了訓練這個侄子的膽量。

02:21:18 - 02:21:22
所以從小就逼著這個侄子晚上帶去睡墳墓。

02:21:23 - 02:21:24
有沒有286？

02:21:24 - 02:21:24
有喔。

02:21:25 - 02:21:26
逼小孩去睡墳墓。

02:21:26 - 02:21:29
可能會有心理上面的創傷，這個會有286喔。

02:21:31 - 02:21:31
好。

02:21:31 - 02:21:33
那麼接下來會有一個問題。

02:21:34 - 02:21:37
這一條罪的行為，凌虐或類似的行為。

02:21:37 - 02:21:41
要不要具有所謂反覆性或持續性。

02:21:43 - 02:21:44
所以這個問題。

02:21:44 - 02:21:49
凌虐這種行為，要不要具有反覆性或是持續性？

02:21:49 - 02:21:54
也就是如果是這種單一的、偶一為之的凌虐，

02:21:54 - 02:21:55
會不會成立本罪？

02:21:56 - 02:21:57
先想過去。

02:21:57 - 02:21:59
舊的實務都說286。

02:22:00 - 02:22:02
虐童要有反覆或持續。

02:22:03 - 02:22:04
如果只是偶一為之的，

02:22:05 - 02:22:07
那個就回去論277。

02:22:08 - 02:22:09
這是過去的實務。

02:22:09 - 02:22:09
懂嗎？

02:22:09 - 02:22:12
過去認為說要反覆或持續才算。

02:22:12 - 02:22:13
偶一為之的，

02:22:13 - 02:22:15
就回歸277。

02:22:16 - 02:22:17
但現在的實務不採這說法了。

02:22:18 - 02:22:20
現在的實務認為呢，

02:22:22 - 02:22:24
就算是單次的也可以。

02:22:25 - 02:22:31
只要這個手段本身可以符合刑法第10條第七項所說的違反人道。

02:22:32 - 02:22:32
瞭解嗎？

02:22:32 - 02:22:34
現在的實務已經放棄這個持續性的要件了。

02:22:35 - 02:22:36
現在認為說就算單次也可以,

02:22:37 - 02:22:40
只要這個手段本身達到違反人道的程度,

02:22:40 - 02:22:43
他就可以算是我們這個條文所稱的凌虐。

02:22:45 - 02:22:47
所以我舉個例子來彰顯它的差異。

02:23:40 - 02:23:40
我有一次啊,

02:23:40 - 02:23:43
從臺中上完課搭高鐵要回來的時候，

02:23:43 - 02:23:44
那一次我搭得很生氣。

02:23:45 - 02:23:47
我後面是一個媽媽抱著他的小孩，

02:23:47 - 02:23:48
他的小孩大概三四歲。

02:23:48 - 02:23:51
那個小孩一直在玩我椅背上面的桌板。

02:23:52 - 02:23:53
就我上一整天的課已經很累了,

02:23:54 - 02:23:55
然後那個屁孩在那邊一直玩我的桌板,

02:23:55 - 02:23:56
我覺得很煩。

02:23:56 - 02:23:58
我就回頭去瞪那個媽媽。

02:23:58 - 02:24:00
媽媽有發現我的眼神

02:24:00 - 02:24:04
就同學們聽過，網路上有一些不能搜尋的關鍵字。

02:24:04 - 02:24:05
好，不能搜尋的關鍵字，我先告知各位。

02:24:06 - 02:24:09
這些東西很噁心，不要亂搜尋。

02:24:09 - 02:24:11
搜尋完之後你產生心理創傷，不干我的事。

02:24:11 - 02:24:13
我已經先行告知義務了，有些很噁心的東西。

02:24:14 - 02:24:17
比如說上個月有一個很紅的關鍵字叫越南屠夫，我們知道你們有沒有看過。

02:24:19 - 02:24:21
越南屠夫，我是沒有搜尋啊，我不喜歡看血腥的東西。

02:24:22 - 02:24:24
有人搜尋都很後悔，越南屠夫。

02:24:25 - 02:24:26
我我有點忘記那個是什麼東西。

02:24:27 - 02:24:27
越南屠夫。

02:24:27 - 02:24:28
然後。

02:24:30 - 02:24:31
還有什麼東西啊？

02:24:31 - 02:24:35
還有一些是流傳十幾年的不要搜尋的關鍵字。

02:24:36 - 02:24:37
還有那個什麼，尖銳。

02:24:38 - 02:24:39
對，尖銳。

02:24:39 - 02:24:42
你搜尋尖銳不會看到一堆尖尖的東西。

02:24:43 - 02:24:45
你會看到一堆長菜花的生殖器。

02:24:46 - 02:24:48
因為菜花的學名叫做尖銳濕疣。

02:24:49 - 02:24:52
還有下水道美人魚。

02:24:53 - 02:24:56
下水道美人魚是好像是日本拍的噁心電影。

02:24:56 - 02:24:57
他不是什麼夢幻的東西。

02:24:58 - 02:24:59
還有什麼東西啊。

02:25:01 - 02:25:03
還有那個少女浴室，對少女浴室。

02:25:05 - 02:25:06
少女浴室是不是聽起來色色的啊。

02:25:07 - 02:25:12
少女浴室是有個少女在浴室自殺之後，屍體浮腫潰爛。

02:25:12 - 02:25:14
好幾個禮拜之後才被發現。

02:25:14 - 02:25:15
少女浴室是這個東西。

02:25:16 - 02:25:17
然後還有什麼東西啊。

02:25:17 - 02:25:19
很多啦，有些我一下記不得了。

02:25:19 - 02:25:22
我永遠記得讓我印象最深刻的叫Bestgore。

02:25:22 - 02:25:24
Bestgore，那個東西我印象超深刻。

02:25:25 - 02:25:28
因為我搜尋過超後悔，Bestgore。

02:25:30 - 02:25:33
就是那種，有沒有看過那個被砂石車碾爆的頭顱？

02:25:33 - 02:25:36
Bestgore就是那樣的東西，高清無碼的版本，Bestgore。

02:25:38 - 02:25:39
我真的後悔去搜尋。

02:25:39 - 02:25:41
我看到馬上把它關掉。

02:25:41 - 02:25:41
我真的不喜歡看那種東西。

02:25:42 - 02:25:44
是不會怕啦，但就不喜歡啦。

02:25:45 - 02:25:46
不過話說還是這樣啊。

02:25:47 - 02:25:48
你們要敢看Bestgore喔。

02:25:49 - 02:25:52
你們當律師、當司法人員或當其他的司法人員，你們一定會看到相驗卷。

02:25:53 - 02:25:54
一定會。

02:25:54 - 02:25:55
你說我做民事總可以吧。

02:25:55 - 02:25:57
難道民事法庭不會有車禍案件嗎？

02:25:58 - 02:25:59
會啊，一定會啊。

02:25:59 - 02:26:00
所以要敢看Bestgore。

02:26:00 - 02:26:00
只是可能不是像要訓練，那個以後再說了。

02:26:03 - 02:26:06
當時那個屁孩一直在玩我椅背上的鎖板。

02:26:06 - 02:26:09
我當時腦中浮現出的邪惡幻想就是這樣子。

02:26:09 - 02:26:11
我就想說，那小孩好討厭。

02:26:11 - 02:26:12
那如果這樣做呢？

02:26:12 - 02:26:15
我就回頭問那個小朋友啦，所以小朋友，想不想看佩佩豬啊？

02:26:16 - 02:26:17
小朋友一定會說想，對不對？

02:26:17 - 02:26:19
那我給他看。

02:26:19 - 02:26:20
他是不是嚇到當場癱軟？

02:26:22 - 02:26:25
兩個眼發直，呆坐在位置上，就不敢玩我的椅背了。

02:26:25 - 02:26:26
搞不好有可能，對不對？

02:26:27 - 02:26:29
所以我腦中當時浮現出這樣邪惡的幻想。

02:26:29 - 02:26:29
各位。

02:26:30 - 02:26:32
假設我真的付諸實行，那我這樣的行為會成立286嗎？

02:26:36 - 02:26:39
過去的實務認為是不會，偶一為之，對不對？偶一為之。

02:26:40 - 02:26:43
所以你知道嗎，照過去的實務，要怎樣才會變286？

02:26:45 - 02:26:46
除非我鄰居的小孩很吵。

02:26:47 - 02:26:55
所以我在手機裡面存的一個相簿叫，裡面好幾百張，每天遇到鄰居的小孩呢，就拿著手機逼他看，你不準閉眼睛，你要看完才可以走。

02:26:56 - 02:26:57
要反覆為之才算，過去的實務是才這樣的說法。

02:26:59 - 02:27:01
但現在的實務不踩這一說了。

02:27:02 - 02:27:04
現在的[redacted] 務會認為說呢，就算是偶一為之也算。

02:27:08 - 02:27:14
只要這個手段本身有達到所謂殘忍不人道的程度，這樣就算，知道嗎？

02:27:15 - 02:27:19
所以，騙小孩看血腥的照片或影片，我認為應該是有機會的啦。

02:27:22 - 02:27:24
對要騙小朋友看佩佩豬，他原本滿心期待。

02:27:24 - 02:27:25
結果怎麼是這種東西？

02:27:26 - 02:27:27
我認為確實有機會。

02:27:27 - 02:27:30
所以現在的話呢，單次的也算喔，只要手段本身有達到違反人道的程度，這個就算。

02:27:33 - 02:27:33
好。

02:27:33 - 02:27:33
所以那個。

02:27:36 - 02:27:37
所以這樣有些同學會問。

02:27:37 - 02:27:39
那如果照現在這樣的說法啊。

02:27:40 - 02:27:41
照現在這樣的說法。

02:27:41 - 02:27:47
那會不會造成說所有對兒少的277都升級變286？對，有人會這樣問嗎？

02:27:49 - 02:27:51
因為現在已經放寬了吧，偶一為之也算。

02:27:51 - 02:27:58
所以照這個說法，會不會叫，會不會讓所有對兒少的277全部都升級變286？

02:27:58 - 02:27:59
答案是不會，為什麼？

02:27:59 - 02:28:00
因為。

02:28:00 - 02:28:00
因為286的零容忍也必須要怎麼樣？

02:28:02 - 02:28:03
殘忍，要違反人道，要違反人道。

02:28:06 - 02:28:09
不見得所有對兒少的虐待都會達到違反人道的程度喔，不見得喔，我舉個例子。

02:28:11 - 02:28:15
假設我搭高鐵的時候旁邊那個小孩一直在叫，有夠吵的，我揍他一拳，造成他右臉頰瘀青。

02:28:19 - 02:28:19
這個有個案例。

02:28:20 - 02:28:21
嗯，還好，對不對？

02:28:22 - 02:28:24
那如果是那小孩很吵，我很火大，於是我拿打火機去燒他的小雞雞。

02:28:26 - 02:28:27
這樣會不會有286?

02:28:28 - 02:28:29
超殘忍、超不忍，到有沒有，這種

02:28:29 - 02:28:30
才會知道吧。所以照這樣的說法，並不會讓所有對兒少的277都升級變286，當然不會。

02:28:37 - 02:28:41
只有那種真的有不人道的程度的，才會喔。

02:28:42 - 02:28:42
好。

02:28:43 - 02:28:49
然後本罪的行為程度，我們說要足以妨害幼童的身心健全發育。

02:28:50 - 02:28:51
足以是什麼意思？

02:28:52 - 02:28:56
有可能，它就是一種適性犯的地方，有可能。

02:28:58 - 02:28:58
所以要不要真的有妨害？

02:28:59 - 02:28:59
不用。

02:29:00 - 02:29:05
只要這個手段有可能會對幼童的身心健全發育造成妨害的話，這就算了，不需要有真正的實害，不需要，也不需要具體威脅的結果，不用，只要有可能就會成立。

02:29:14 - 02:29:15
所以有。

02:29:15 - 02:29:18
這個做叔叔的人為了要訓練侄子的膽量，從小時候就把他關在墳墓當中，每天晚上逼他在墳墓裡面睡睡袋。

02:29:26 - 02:29:27
這就已經成立本罪了。

02:29:28 - 02:29:31
就算這個小孩長大之後，並沒有明顯的心理創傷。

02:29:32 - 02:29:37
反而啊，這個小孩從小因為睡墳墓的關係，跟阿飄變成了好朋友，培養出了靈異體質，長大之後啊，成為一名非常有名通靈少年。

02:29:42 - 02:29:44
出了書又經常上節目，年收好幾百萬。

02:29:45 - 02:29:46
這個叔叔會不會286？

02:29:47 - 02:29:50
會有，還是會，因為我們講足以嘛，他不用真的有實害或危險，知道嗎？

02:29:50 - 02:29:51
有可能，這個就算。

02:29:52 - 02:29:53
好。

02:29:54 - 02:29:57
那本罪的行為客體是未滿18歲之人。

02:29:57 - 02:29:59
那這個條文有修法，今年

02:30:00 - 02:30:00
有修法，但那個都是刑度，那個影響還好。

02:30:03 - 02:30:06
講義我上禮拜也忘了做，沒關係，反正課程結束前我再發給各位，就是修法有做一些整理。

02:30:09 - 02:30:10
最後，競合的部分。

02:30:12 - 02:30:13
那我們看一下，競合的部分。

02:30:14 - 02:30:17
本罪跟傷害罪要怎麼競合？

02:30:17 - 02:30:25
因為你要想哦，行為人對幼童的凌虐行為，如果有形成具體可見的傷害結果的話，我們要怎麼競合？

02:30:27 - 02:30:29
那這時候同時有277，也有286嘛。

02:30:29 - 02:30:35
277跟286，如果兩條同時成立的話，我們要怎麼去競合呢？

02:30:37 - 02:30:39
這時候會有幾種不同的說法。

02:30:39 - 02:30:41
我先講，先講最早以前。

02:30:42 - 02:30:50
最早以前的實務會理所當然的覺得286叫特別規定，277叫普通規定。

02:30:50 - 02:30:53
所以兩條同時成立，我們用什麼較好，286嘛，對不對？

02:30:53 - 02:30:54
一個很直觀的看法。

02:30:54 - 02:30:57
可是後來實務冒出另外一種見解。

02:30:58 - 02:31:02
因為你們也知道，實務總覺得重罪丟掉不斷很可惜。

02:31:02 - 02:31:04
實務是不是常講重法優於輕法。

02:31:04 - 02:31:05
有印象吧。

02:31:05 - 02:31:09
那我是不是也跟各位強調，重罰優於輕罰，那只是實務自認為的法力而已。

02:31:09 - 02:31:10
學理上沒有這種東西，這我講過。

02:31:11 - 02:31:11
好。

02:31:12 - 02:31:14
這裡會牽涉到一個條文。

02:31:14 - 02:31:15
而《少事法》112條。

02:31:17 - 02:31:21
這個條文考試不會直接出現，但它是我們實務上會用到的條文。

02:31:22 - 02:31:24
而少事法112這個條文是說啊，

02:31:25 - 02:31:30
如果成年人故意對兒童少年犯罪的話，

02:31:30 - 02:31:32
加重其刑至二分之一。

02:31:33 - 02:31:33
可是他有但書喔。

02:31:34 - 02:31:39
但書講說，但該罪就被害人是兒童或少年而特別規定其刑的話，不在此限，這個叫兒童及少年福利與權益保障法112條。

02:31:41 - 02:31:41
好。

02:31:41 - 02:31:44
我帶各位操作一次這個條文。

02:31:44 - 02:31:47
因為你要先懂這個條文，我們才能講得下去後面的爭議。

02:31:47 - 02:31:48
來，我們先來看到性犯罪的部分。

02:31:49 - 02:31:52
來，先看到221、222，還有227這幾個條文。

02:32:09 - 02:32:10
212還有27號

02:32:10 - 02:32:11
我再講一次兒少法12條什麼意思喔。

02:32:12 - 02:32:15
成年人故意對兒少犯罪，

02:32:15 - 02:32:17
加重其刑至二分之一。

02:32:18 - 02:32:21
但如果該罪就被害人是兒少已有特別規定的話，

02:32:21 - 02:32:22
那就不加重。

02:32:22 - 02:32:23
好。

02:32:24 - 02:32:25
舉個例子喔，

02:32:25 - 02:32:26
我們再講陸伯言。

02:32:27 - 02:32:32
如果陸伯言跟15歲的國中女生合意性交，

02:32:32 - 02:32:33
他犯227，

02:32:33 - 02:32:33
對不對？

02:32:34 - 02:32:35
那要不要再用兒少112加重？

02:32:36 - 02:32:36
不加。

02:32:36 - 02:32:37
為什麼？

02:32:37 - 02:32:39
因為227這個條文它本來就是一個保護兒少的規定，

02:32:39 - 02:32:40
知道嗎？

02:32:40 - 02:32:41
好，那再來喔。

02:32:41 - 02:32:45
那如果陸伯言去性侵害一個13歲的女國中生，

02:32:46 - 02:32:47
對他強制性交,

02:32:48 - 02:32:49
這時候路伯彥要不要加重?

02:32:50 - 02:32:50
欸,

02:32:50 - 02:32:51
一樣不加重,

02:32:51 - 02:32:51
為什麼?

02:32:51 - 02:32:55
因為違反13歲女國中生的意願對她強制性交的話,

02:32:55 - 02:32:57
這時候的法律規定在哪裡?

02:32:57 - 02:32:59
222條第一項第二款。

02:32:59 - 02:33:01
而222條第一項第二款,

02:33:01 - 02:33:05
它也是一個針對被害人是兒少的特別加重規定。

02:33:05 - 02:33:06
所以這個時候呢,也不會再加重

02:33:06 - 02:33:07
知道嗎?

02:33:07 - 02:33:08
也不會再加重。

02:33:08 - 02:33:09
好。

02:33:09 - 02:33:13
那如果是陸伯言對一個17歲的女高中生強制性交,

02:33:14 - 02:33:15
這時候要不要依照兒少12加重？

02:33:16 - 02:33:16
要。

02:33:16 - 02:33:17
為什麼？

02:33:17 - 02:33:19
因為對17歲強制性交的話，

02:33:20 - 02:33:21
他論的就是一般的221嘛。

02:33:21 - 02:33:22
這時候就沒有被害人，

02:33:22 - 02:33:25
就沒有因為被害人是兒少而有特別加重的規定，

02:33:25 - 02:33:27
所以這個時候呢，就要依照

02:33:28 - 02:33:29
兒少112條的規定

02:33:29 - 02:33:31
去做加重，瞭解喔？

02:33:31 - 02:33:33
好，那我們回來傷害罪喔。

02:33:34 - 02:33:37
被害人凌虐兒少的情況，

02:33:38 - 02:33:41
如果同時也造成了具體可見的肉體傷害，

02:33:41 - 02:33:43
那是不是同時有277跟286？

02:33:43 - 02:33:44
對啊，沒有錯啊。

02:33:45 - 02:33:46
那各位再想喔,

02:33:47 - 02:33:50
286要不要用兒少12加重?

02:33:50 - 02:33:50
不加,

02:33:50 - 02:33:52
為什麼?因為286本來就保護兒少嘛,

02:33:52 - 02:33:53
聽得懂吧?

02:33:53 - 02:33:55
那277要不要加重？

02:33:55 - 02:33:55
要,

02:33:56 - 02:33:57
277要加重,

02:33:57 - 02:33:59
因為277它並沒有就被害人是兒少有特別規定。

02:34:00 - 02:34:01
一起行。

02:34:01 - 02:34:02
好，所以問題就來了。

02:34:03 - 02:34:06
286跟277，原本是286比較重，

02:34:06 - 02:34:07
沒有錯。

02:34:07 - 02:34:10
可是277用兒少12加重啊。

02:34:10 - 02:34:16
所以277用兒少12加重之後，它的法定刑上限會來到多重？

02:34:18 - 02:34:19
七年六個月以下。

02:34:19 - 02:34:20
欸，這時候變誰重的？

02:34:21 - 02:34:22
變277重的。

02:34:22 - 02:34:28
所以過去實務有另外一派的看法認為說呢，277因為它要依照兒少法加重的關係，

02:34:28 - 02:34:31
所以加重後的結果，反而是二七七比較重。

02:34:31 - 02:34:33
所以這個時候呢,我們要優先論277。

02:34:34 - 02:34:36
理由這個說法,跟兒少法12條有關。

02:34:37 - 02:34:39
過去的實務原本這兩說僵持不下,

02:34:39 - 02:34:41
後來跑出了第三說變成結論。

02:34:42 - 02:34:43
第三說說呢,

02:34:44 - 02:34:47
286跟277要想像競合。

02:34:48 - 02:34:53
這個是高等法院法律座談會最後的結論,說286跟277要想像競合。

02:34:53 - 02:34:54
欸,為什麼?

02:34:56 - 02:35:01
我一開始看到這個結論覺得莫名其妙,想說這都身體法益,這為什麼要想像競合的,

02:35:01 - 02:35:02
但後來想通了。

02:35:03 - 02:35:08
這兩罪之所以要想像競合，是因為這兩條罪它評價的對象根本就不一樣。

02:35:09 - 02:35:11
277是實害犯，286是危險犯。

02:35:11 - 02:35:12
你們想一件事喔。

02:35:13 - 02:35:17
如果有個幼童，他玩壞了爸爸的模型，

02:35:17 - 02:35:22
爸爸當場失去理智，把這個幼童打成熊貓眼，就一個這樣的事實喔。

02:35:23 - 02:35:29
爸爸無故，也不能說無故啦，反正就爸爸基於這種個人的情緒問題，而把他的小孩打成熊貓眼。

02:35:30 - 02:35:31
277評價哪個部分？

02:35:32 - 02:35:35
眼睛變成熊貓，已然形成的身體傷害，

02:35:36 - 02:35:37
這是277評價的。

02:35:38 - 02:35:39
那286評價什麼呢？

02:35:40 - 02:35:45
小孩被爸爸打成熊貓眼，是不是可能形成他心理上的創傷？

02:35:45 - 02:35:49
對這個小孩將來的人格發展，會形成一些不可知的影響。

02:35:50 - 02:35:53
就像你想嘛，小孩被爸爸打成這個樣子，

02:35:54 - 02:35:56
你說對這個小孩將來的心裡會產生什麼影響？

02:35:56 - 02:35:57
嗯，我們也不知道。

02:35:58 - 02:36:00
也許這個小孩因此而學會了

02:36:00 - 02:36:02
的暴力，長大之後也變成一個家暴者，有可能，或者這個小孩呢，從此無法對親密的人產生信任。

02:36:07 - 02:36:11
從此之後呢，遇到一些親密關係都產生這種逃避的心態，進而呢，無法建立起親密關係，有沒有可能？也有可能，對不對？

02:36:16 - 02:36:20
或者是這個小孩會不會因此而長大之後罹患什麼憂鬱症啊，或者是一些精神疾病。

02:36:21 - 02:36:23
嗯，不是不可能，但我們不知道嘛，對不對？

02:36:23 - 02:36:27
所以286所評價的就是什麼呢？

02:36:27 - 02:36:30
凌虐行為對這個幼童的心理發展，

02:36:30 - 02:36:34
將來的層面所形成的不可測的影響。

02:36:35 - 02:36:42
瞭解吧，所以其實一樣的虐童行為，277跟286所評價的根本是不同的兩件事。

02:36:42 - 02:36:45
277評價的是過去已經造成的實害。

02:36:46 - 02:36:54
而286所評價的是虐童行為對這個幼童將來的心理發展所可能形成的不確定的危險。

02:36:55 - 02:36:57
這兩者所評價的對象根本就不一樣。

02:36:57 - 02:36:59
所以呢,要想像競合,聽得懂吧?

02:37:00 - 02:37:02
所以許目的想像競合說,其實也合理,知道嗎?

02:37:02 - 02:37:05
所以目前的話,大概有這三種不同的看法。

02:37:07 - 02:37:10
好,所以這個是我們講到虐童的犯罪。

02:37:10 - 02:37:12
這裡這幾年來我覺得還蠻重要的問題。

02:37:13 - 02:37:15
這幾年來考到虐童，幾乎就是考這兩件事。

02:37:16 - 02:37:19
第一個就是凌虐行為，要不要具有反覆性、持續性。

02:37:19 - 02:37:22
第二個就是虐童跟傷害要怎麼去競合。

02:37:22 - 02:37:24
這個虐童跟傷害的競合。

02:37:25 - 02:37:29
當初在實務放棄的凌虐行為的反覆性的見解之後。

02:37:29 - 02:37:30
我就預言說。

02:37:30 - 02:37:31
這個以後一定會吵。

02:37:31 - 02:37:34
我2021年那個時候就有在集訓班出，結果沒有人會寫。

02:37:34 - 02:37:38
結果真的啊，兩三年之後真的就做法律會了啦。

02:37:38 - 02:37:39
所以那個時候我的預測沒有錯。

02:37:39 - 02:37:41
後來真的是一個問題。

02:37:42 - 02:37:43
這裡的話，我們上午的課啊，就先上到這邊。

02:37:43 - 02:37:47
然後有一個題目你們先回去看，你們等一下中場休息先來看68頁的第五題。

02:37:53 - 02:37:55
這一題我記得我在刑總的階段有講過。

02:37:56 - 02:37:57
那個時候在講教唆犯，68頁第五題。

02:37:58 - 02:37:59
這一題很重要。

02:38:00 - 02:38:03
這一題是近幾年來關於虐童我覺得出的最棒的一個題目，這一題你們先看哦。

02:38:04 - 02:38:08
等一下我們先休息一個小時，那下午兩點的時候呢，我們再來講這一題的解答方向。

02:38:09 - 02:38:10
好，我們先在那邊下課哦。